

目錄

壹、刑事政策之定義與沿革	3
一、刑事政策之定義	3
二、刑事政策之變革	4
貳、刑罰論	10
一、刑罰的目的	10
二、刑罰的種類	11
三、特別議題：死刑	11
【試題演練】	19
四、特別議題：被告子女與量刑	21
【試題演練】	29
參、保安處分	31
一、保安處分之定義	31
二、性犯罪強制治療處分	31
【試題演練】	43
三、精神障礙者與監護處分	44
肆、機構內處遇：強制工作	51
一、制度背景	51
二、舊法條文規範	51
三、釋字第 812 號解釋	52
伍、社會處遇：緩刑與假釋	60
一、緩刑	60

【試題演練】	69
二、假釋	70
【試題演練】	82
陸、慢性習慣犯與累犯之處遇	85
一、慢性習慣犯之概念與疑慮.....	85
二、我國針對累犯之處遇	85
【試題演練】	91
柒、毒品法庭與治療式司法	94
一、毒品法庭概念的提出與背景.....	94
二、毒品法庭的疑慮.....	97
三、我國毒品施用者處遇現狀.....	99
四、毒品法庭的省思與建議	104
捌、修復式司法與少年法.....	107
一、修復式司法.....	107
【試題演練】	114
二、少年修復式司法.....	116
玖、被害人參與與少年法.....	123
一、被害人參與.....	123
二、少年事件中的被害人參與.....	131
【試題演練】	137

壹、刑事政策之定義與沿革

一、刑事政策之定義：

（一）李斯特：

認為刑事政策是「以有關犯罪原因論之研究與關於刑罰效果的考察作為基礎之一切犯罪鬥爭政策」¹。

（二）張甘妹老師²：

認為刑事政策可以區分為廣義說及狹義說二者。

1. 廣義說：係指國家以預防及鎮壓犯罪為目的所為一切之手段及方法。

依照此說，刑事政策防止犯罪之目的並不必要是直接、積極或主要的，凡與犯罪防止有間接或從屬之目的方法，均屬之。此定義下的刑事政策學，並不以限於直接的以防止犯罪為目的之刑罰諸制度，而係包涵與間接防止犯罪相關的社會政策，例如居住、教育、勞動（失業）政策等。

2. 狹義說（現今通說）：係指「國家以預防及鎮壓犯罪為目的，運用刑罰以及具有與刑罰類似作用之制度，對於犯罪人及有犯罪危險人所作用之刑事上之對策」。依照狹義說見解，刑事政策之範圍即不包括各種間接的社會政策在內，而僅限於直接的對策，並包含刑罰以外之其他具有類似刑罰作用之制度在內，如保安處分、緩刑、假釋、更生保護等。

（三）林山田老師（狹義說）³：

認為刑事政策乃指使用刑事法的手段以抗制與預防犯罪的法律政策，包括刑事立法政策、刑事司法政策與刑事矯治政策。

¹ 武內謙治、本庄 武著，洪維德、黃士軒、林宛珊、洪士軒譯，刑事政策學，新學林出版股份有限公司，2024年初版，頁15。

² 張甘妹，刑事政策，三民書局，1997年增訂版，頁2-3。

³ 林山田，刑法改革與刑事立法政策，元照出版，二零零五年刑法修正總評，2005年，頁73-98；謝如媛，刑事政策研究成果回顧，刑事法：10. 刑事政策研究成果回顧，法律研究成果回顧與社會影響性2001-2020，2024年11月（下期），頁186。

二、刑事政策之變革：

（一）概說：寬嚴並進的刑事政策⁴

1. 背景：2005 年，法務部提出刑法修正草案，以刑法修正為主軸。法務部稱該次修法是採取「寬嚴並進的刑事政策」作為立法指標，該次修法並於 2006 年 7 月 1 日開始施行。
2. 謝煜偉老師指出，本次修法將「二分政策」引進了我國。所謂二分政策，是指當犯罪者進入刑事司法系統時，區分嚴厲或和緩兩種截然不同的處理態度以及相對應的處遇流程，並將犯罪者區分為兩類：一類是需要集中打擊火力予以嚴厲制裁的類型，另一類則是盡量由轉介或自由刑替代方案，盡可能的將犯罪者排除在刑事審判體制或監獄之外。
3. 在二分政策的架構下，嚴厲刑罰的目的其實並不是在預防或降低犯罪行為的出現，也不是要培養國民的規範意識，而是肯認「高犯罪社會是無可避免的」一事，並作為主權者有能力解決犯罪問題之象徵。其造成的效果有以下二點：
 - (1) 法秩序與安全感之堆疊。
 - (2) 棄民的製造與掩飾：在二分政策架構下，監獄的機能不是矯治、教化場所，更不是贖罪或懺悔場所，而是單純剝奪這些犯罪者在社會生活裡的資格，棄絕任何溝通的可能。
4. 反之，於二分政策架構下，和緩政策的社會機能，則體現在以下幾點：
 - (1) 新種規訓場域的開展。
 - (2) 理性人身分的回流：和緩政策肩負著積極篩選與重新定位國家人口資源的作用，並成為培養國民自我決定與自律的新場域。

⁴ 謝煜偉，寬嚴並進刑事政策之省思，月旦法學雜誌第 126 期，2005 年 10 月 15 日，頁 131-157。

(3) 邪惡人標籤的循環貼附：若屬於下階層級的微罪犯罪者，和緩政策的處理態度是，節省訴訟與矯治資源，放棄以司法處理，而改由更高更嚴密的監控技術將其鎖定在社會內的其他角落，以作為消極的監管。由此點觀之，針對無挽救餘地的社會邊緣人，「讓它們腐爛」根本是緩和面（監控）與嚴厲面（隔離）二者共通的語言。

5. 二分政策對我國的影響與衝擊：

(1) 批判力道的解消：二分政策在寬嚴二面都有自己的論證機制，透過嚴厲的懲罰措施來宣示國家捍衛民眾決心，以換取可以推動轉型措施的腳步。然而，謝煜偉老師指出，此種二分政策將諸種學理選擇性地加以切割適用，顯然會造成體制上的嚴重矛盾與混亂。其一，在於刑法謙抑性原則從來就不應該被選擇性適用，也不該只適用在輕微犯罪者身上。然而，針對那些被國家選擇性是用嚴厲刑罰的犯罪者，謙抑性原則卻如同突然消失一般。再者，所謂「和緩政策是謙抑性原則的體現」，根本就是個美麗的幻想。藉由回流社會後，一些新控制技術的發展（如以撤銷緩處分作為威嚇和控制的手法），讓刑罰的威嚇殘影複製到每個人心中，刑罰反而更「驕傲」的使用著了。而後這些嚴密處罰監管的力道，卻會因為前段的轉介政策被評價為和緩的，也就連帶被忽視了。

(2) 恣意的寬嚴區分標準間接強化人口集團分類的操作：我國所推動的二分政策，雖然宣示上是以「犯罪輕重」或「可否矯治」作為篩選機制，但其實從法條來看，我們連判定「矯治可能性」，都是透過犯罪輕重來決定的。此外，觀察我國的微罪轉介機制也可以發現，幾乎都是以法定刑的高低來決定轉介的門檻。而該次修法更在總則部分提高有期徒刑與數罪併罰的上限，全面的調高量刑

範圍，卻不論實際適用的案件類型為何，造成恣意認定、胡亂打擊的結果。而這也將導致二分政策成為極端恣意性的產物，這個恣意性的縫隙可能會滲入其他潛在的因素，如被告言談可理解性、社經地位、身分階級等，而左右了司法人員寬嚴適用的決定。

- (3) 廣泛入罪化的微罪轉介措施：我國發展緩和政策，總以「如何減輕案件負擔」作為首要（甚至唯一）考量。這樣的運作結果，不但除罪化、去烙印化的目標越來越不可能達成，更會造成更全面的法化現象。也就是說，欠缺對刑罰手段深切反省下所訂出的微罪轉介措施，不但與去刑罰化、除罪化的潮流不符，反而還會讓廣泛入罪化的活動更為名正言順。舉例而言，於刑事程序中，檢察官的裁量空間增加後，不光是起訴與否擁有更多選擇（起訴、絕對不起訴、相對不起訴、緩起訴），就連起訴的管道也更為廣泛（通常審判程序、簡易判決處刑、簡式審判程序）。這些努力縱是希望提升辦案品質，但背後反而隱藏著更容許草率處理其他輕微案件的意味。由此可知，我國的和緩政策根本與「維護多元價值」無關，而是更反覆重申主權者所秉持的單一道德秩序。當我們不斷延伸刑法規制觸角的同時，也正因為在程序上的微罪轉介與替代方案的「和緩性」、「多元性」，讓我們能更順理成章地接受實體法上不當的條文或不當的認定標準，同時更在事實認定的過程中讓司法人員有更多浮濫認定為有罪的空間。

6. 可能的解決方案：

- (1) 由於我國向來欠缺矯治主義之傳統，只是利用二分政策的名義徹底放棄矯治的工作，並一味的僅以「紓解訴訟或監獄負擔」為由來思考緩和政策的機能，那麼二分政策在我國就只剩下粗糙猛烈

的拘禁、隔離與監視。那麼，我國社會將更加迅速的被推向「失序、壓制、再失序、再壓制」的恐怖危險平衡關係。

- (2) 或許目前比較可行的解決方式，是在實體法上堅守現行刑法的底線，不應貿然通過更加重刑化的刑法修正草案，同時應避免以「死刑的替代方案」的姿態來正當化更加野蠻的重型化立法。另外，應儘速將泛道德性的立法修正或刪除，並應力拒諸如量刑指導綱領等相關剝奪法官量刑自主權，而有令其淪為機械性審判之虞的修法建議。更重要的，是透過不斷對話的過程，保有對「犯罪」概念反省論述的可能性，以發現整體刑事司法體系的極限。

（二）刑事政策趨向：犯罪被害人⁵

1. 背景：歐美國家於 1960 年代以「被遺忘的人們（forgotten persons）」來稱呼被害人，並研發了被害人補償制度（victim compensation）⁶。此外，被害人或支援團體亦透過草根性的社會運動向國家要求尊重與資源，影響所及，乃允許被害人在量刑前發表被害人影響陳述（victim impact statement），並賦予更多訴訟參與的成效⁷。
2. 而學者有指出，這股潮流也影響了臺灣。我國於 1990 年代後半發生的數起重大事件影響之下，官民間建立起了「被害人想像共同體」，並與社會中既有的嚴刑峻罰相結合，形塑了 2005 年重刑化導向的刑事政策⁸。據此，我國輿論往往傾向將被害人與被告間視為零和關係，此種論述方式使得對被告權利保障的主張容易被視同對被害人及其家人的漠視甚至污辱。於此種情況下，以保護被害人作為名義來加

⁵ 謝如媛，刑事政策研究成果回顧，刑事法：10. 刑事政策研究成果回顧，法律研究成果回顧與社會影響性 2001-2020，2024 年 11 月（下期），頁 189；陳慈幸，刑事政策：概念的形塑，元照出版，2023 年 9 月，四版一刷，頁 5-11。

⁶ 陳慈幸，刑事政策：概念的形塑，元照出版，2023 年 9 月，四版一刷，頁 5-6。

⁷ 謝如媛，犯罪被害人陳述制度之成效——從英國實證研究成果出發，法學新論 30 期，2011 年，頁 15。

⁸ 李佳玟，被害人認同與刑事政策，成大法學 11 期，2006 年，頁 113-164。

重刑罰，不僅影響立法，也延伸到量刑與假釋的實務運作。

3. 於法律面，我國於 2000 年起實施了多樣被害人保護政策，例如推動犯罪被害人保護法等（於 2023 年改稱為犯罪被害人權益保障法）。而學界則有自比較法觀點出發，建議引進被害人參與（參加）訴訟程序之權益⁹，希望藉此使被害人擺脫「被遺忘的人」之地位，重拾程序主體性。相較於此，亦有學者分析國外犯罪被害人影響陳述的實證研究，發現該制度未必較有利於被害人，並指出「提升被害人訴訟上地位等於提升被害人權益」的思考模式過於簡化，在相關議題上應盡量避免以想像的、刻板的被害人印象來概括被害人的實際需求¹⁰。是以，政策考量上固然應重視、加強各種實質上可減輕被害人痛苦與負擔的方式；但需避免被害下與加害人在訴訟上的權力消長成為零和遊戲，削弱被告受正當法律程序保障的權利。

（三）刑事政策趨向：修復式司法¹¹

1. 北美於 1970 年代開始掀起修復式司法的風潮，試圖鬆綁「罪」與「罰」的堅固連結、社區對解決紛爭的關心與參與，以及事件之當事人及重要關係人的賦權。修復式司法關係著司法（正義）的典範轉移（paradigm shift），而不僅是促進對話與和解的方式與技巧¹²。
2. 在我國，法務部自 2010 年起推動修復式司法試行方案，2012 年將方案推展到全國地檢，政府舉相關研習與訓練，並進而帶動民間團體與個人的參與、茁壯。在學術研究與實務發展的帶動下，2019 年刑事訴訟法與少年事件處理法、2020 年監獄行刑法修正通過，臺灣成為

⁹ 盧映潔，犯罪被害人在德國刑事訴訟程序中的地位與保護之介紹，刑事法雜誌，53 卷第 2 期，2009 年，頁 103-105。

¹⁰ 謝如媛，犯罪被害人陳述制度之成效—從英國實證研究成果出發，法學新論第 30 期，2011 年，頁 13-34。

¹¹ 謝如媛，刑事政策研究成果回顧，刑事法：10. 刑事政策研究成果回顧，法律研究成果回顧與社會影響性 2001-2020，2024 年 11 月（下期），頁 192-194。

¹² 謝如媛，修復式司法的現狀與未來，月旦法學雜誌第 118 期，2005 年，頁 41-51。

亞洲第一個將修復式司法文明化的國家。從起訴前到起訴後、審判及刑之執行階段，從成人刑事案件到少年事件，當事人都有自願參與修復對話的機會。

貳、刑罰論

一、刑罰的目的¹³

（一）絕對理論：

認為使用刑罰是為了達到公平正義之目的，採用刑罰是針對犯罪所造成之惡害，所實施之公正報應手段，故又稱之為「正義理論」。

（二）相對理論：

本理論首重預防犯罪思想，故又稱為「預防理論」。且因其預防犯罪之思想是為了達到預防犯罪之目的，故又有稱為「目的理論」者。其並可再區分為「一般預防理論」與「特別預防理論」二者：

1. 一般預防理論：主要內涵在於以威嚇之方式達到防衛社會之效果。而刑罰所採取之威嚇思維，大多是以「心理強制」為論理，即採用刑罰之最大目的是為了對人民的心裡產生一種制約，使社會大眾能明瞭犯罪所帶來的痛苦後果遠大於慾望之滿足，因而不從事犯罪行為。
2. 特別預防理論：相對於心理強制論，特別預防理論採取較為科學之方法發現犯罪之原因，並採用「個別之預防」，內涵主要在說明刑罰之目的在於教化或矯治犯罪行為人，使其能夠在未來重新融入社會生活中，而不再從事犯罪。亦有學者指出¹⁴，特別預防理論是以刑罰對行為人之作用為重點，使犯罪行為人改過遷善，以利日後能重新踏入社會。

（三）綜合理論（現今通說）：

本說認為，刑罰之目的應綜合絕對理論與相對理論，並應以絕對理論為主，相對理論為輔。據此，刑罰之主要目的，在於公正的報應行為人的罪責。而輔助目的，則係藉此達到威嚇或教育社會大眾，進而產生嚇阻

¹³ 陳慈幸，刑事政策：概念的形塑，元照出版，2023年9月，四版一刷，頁43-46；林山田，刑法通論第七版（下冊），元照出版，2000年，頁375-376。

¹⁴ 李惠宗，憲法要義，元照，2008年，頁213。

犯罪之一般預防功能，並善用刑罰執行的機會，從事受刑人矯治與再社會化之工作，以期能夠達到教化之個別預防功能。

二、刑罰的種類¹⁵

（一）主刑：依照刑法第 33 條，可分為以下五種

1. 死刑：現行法下僅存有相對死刑（除死刑外可宣判無期徒刑等之罪）。
2. 無期徒刑：目前無期徒刑並非終身監禁，而仍存有假釋之規定（刑法第 77 條第 1 項前段參照）。
3. 有期徒刑：2 月以上，15 年以下，得減至 2 月未滿或加至 20 年（刑法第 33 條第 3 款參照）。
4. 拘役：1 日以上，2 月未滿，得加至 120 日（刑法第 33 條第 4 款參照）。
5. 罰金：最少額為新台幣 1,000 元以上，以百元計算之（刑法第 33 條第 5 款參照）。

（二）從刑：褫奪公權

1. 褫奪之權利，以公權利為限，即剝奪犯人享有公權能力之刑罰。依照刑法第 36 條規定，可褫奪擔任公務員之資格、為公職候選人之資格。
2. 褫奪公權可區分為終身及定期二種；宣告死刑或無期徒刑者，褫奪公權終身（刑法第 37 條第 1 項參照）；宣告 1 年以上有期徒刑，依犯罪性質認為有褫奪公權之必要者，則宣告 1 年以上 10 年以下之褫奪公權（刑法第 37 條第 2 項參照）。

三、特別議題：死刑

（一）死刑相關法規範

¹⁵ 陳慈幸，刑事政策：概念的形塑，元照出版，2023 年 9 月，四版一刷，頁 42-43。

1. 公民與政治權利國際公約第 6 條：

一、人人皆有天賦之生存權。此種權利應受法律保障。任何人之生命不得無理剝奪。

二、凡未廢除死刑之國家，非犯情節最重大之罪，且依照犯罪時有效並與本公約規定及防止及懲治殘害人群罪公約不牴觸之法律，不得科處死刑。死刑非依管轄法院終局判決，不得執行。

三、生命之剝奪構成殘害人群罪時，本公約締約國公認本條不得認為授權任何締約國以任何方式減免其依防止及懲治殘害人群罪公約規定所負之任何義務。

四、受死刑宣告者，有請求特赦或減刑之權。一切判處死刑之案件均得邀大赦、特赦或減刑。

五、未滿十八歲之人犯罪，不得判處死刑；懷胎婦女被判死刑，不得執行其刑。

六、本公約締約國不得援引本條，而延緩或阻止死刑之廢除。

2. 聯合國人權事務委員會第 36 號一般性意見第 35 段：「情節最嚴重之罪」一詞必須作嚴格解讀，僅限於涉及故意殺人的極嚴重罪行。在第六條的架構內，未直接和故意導致死亡的罪行，如謀殺未遂、貪腐及其他經濟和政治罪行、武裝搶劫、海盜行為、綁架以及毒品和性犯罪儘管具有嚴重性質，但絕不能作為判處死刑的理由。同樣地，有限度地參與或共犯即便情節最重大之罪，例如為謀殺提供實際工具，也不能作為判處死刑的理由。締約國有義務審查其刑事法律，以確保不對未構成情節最重大之罪的罪名判處死刑。締約國還應撤銷對未構成情節最重大之罪的死刑判決，並採取必要的法律程序，對此類罪行已被定罪的人重新判決。

(二) 死刑之釋憲實務：113 憲判 8¹⁶

1. 立法者就違反「禁止殺人」誡命之犯罪行為，選擇死刑為其最重本刑，其目的在使行為人就其故意侵害他人生命之犯罪行為，承擔相對應之罪責，並期發揮刑罰之嚇阻功能，以減少犯罪，維持社會秩序。此等功能亦為我國多數人民之法感情所支持，進而為有關機關據以為立法目的。就被宣告死刑之刑事被告而言，雖然系爭規定一至四所定死刑並無特別預防功能，然於我國歷史及社會脈絡下，得認公正應報及嚇阻侵害生命法益之重大犯罪，於目前仍為特別重要之公共利益。是系爭規定一至四有關以死刑為最重本刑之規定部分，其目的尚屬合憲。
2. 就手段而言，系爭規定一至四所定死刑之制裁手段，其效果不僅會剝奪被告之生命，從而根本終結被告之生物及法律人格，更會進而剝奪被告之其他權利，且均無法回復，其所致不利益之範圍及程度極為鉅大。是得適用死刑予以制裁之犯罪，應僅限於最嚴重之犯罪類型，亦即其所侵害法益之類型及程度，依審判當時之我國社會通念，堪認與被告受剝奪之生命法益至少相當，例如侵害他人生命法益之殺人既遂罪，始足認屬最嚴重之犯罪類型。按系爭規定一至四所處罰之犯罪，均涉及故意殺人，而屬侵害生命法益之最嚴重犯罪類型。是系爭規定一至四有關死刑部分之規定，其所追求之公益（保障被害人之生命法益）仍與其所剝奪之被告生命法益相當，從而符合憲法罪刑相當原則。
3. 於我國有法律位階效力之公政公約第 6 條第 2 項規定，就尚未廢除死刑之國家，固要求其所定死刑僅得適用於「最嚴重之犯罪」（the most serious crimes），然該公約就何謂「最嚴重之犯罪」並無進一步之具

¹⁶ 僅針對與死刑制度本旨相關論理部分。

體規定。參照該公約之人權事務委員會（Human Rights Committee）於 2018 年就上開公約第 6 條所公布之第 36 號一般性意見（General Comment No. 36），其第 35 段雖強調「最嚴重之犯罪」應嚴格解釋，而應僅限於涉及故意殺人之極嚴重罪行（crimes of extreme gravity involving intentional killing）；且在公約第 6 條的架構下，「未直接且故意導致死亡的罪行」（crimes not resulting directly and intentionally in death），不得作為判處死刑的理由。然就得科處死刑之故意殺人罪是否僅限於直接故意之殺人罪，仍無明確之立場。

4. 有關刑事犯罪之故意，刑法第 13 條第 1 項規定：「行為人對於構成犯罪之事實，明知並有意使其發生者，為故意。」即實務及學說所稱之直接故意或確定故意。同條第 2 項規定：「行為人對於構成犯罪之事實，預見其發生而其發生並不違背其本意者，以故意論。」實務及學說上有稱為間接故意、不確定故意或未必故意。上開第 2 項規定所涵蓋之情形則可能包括客體不確定之故意（例如概括故意及擇一故意）及結果不確定之故意（即未必故意）。然就行為人對於構成犯罪事實認知及意欲而言，上開客體不確定之概括故意及擇一故意，與上開第 1 項所定之直接故意實無明顯差別。
5. 就系爭規定一至四所定之罪而言，不論行為人係基於上開第 1 項之確定故意或第 2 項之不確定故意而為之，在客觀上均發生被害人死亡結果，兩者間確無差別。然於上開第 2 項所定未必故意之情形（不包括客體不確定之概括故意或擇一故意），行為人對於構成要件事實（尤其是死亡結果）雖有預見之認知（knowledge），但並無積極促其發生之意欲（desire），而僅係容忍或放任其發生。是就未必故意之行為人而言，被害人死亡結果之發生僅是其預見的可能結果之一，仍有其不確定性，而非其積極追求或努力促其實現之目的。又未必故意之行

為人對於死亡結果與其行為間之因果關係，多半也未必有直接、實質的控制及影響，而只是放任其行為自然發展，致生不違背其本意之結果。亦即行為人之行為與結果之發生間固有因果關係，然其實際發展歷程則非必然是由行為人所形塑或掌控，甚至可能繫諸於其他偶然因素之發生或不發生。是就是否具有積極實現犯罪之惡性故意及對因果關係之實質控制程度而言，未必故意之不法內涵及主觀罪責內涵，相較於上開第 1 項之確定故意，通常較輕。

6. 系爭規定一至四所定死刑，應僅適用於行為人係基於直接故意、概括故意或擇一故意而殺人既遂之情形，始符合個案犯罪情節最嚴重之基本要求。反之，於行為人僅係基於未必故意而殺人既遂之情形，即不該當個案犯罪情節最嚴重之情形。

（三）死刑應該存在的理由：翦除論¹⁷

1. 許家馨老師指出，現行應報理論要證立死刑的存在，恐怕有些困難。然而，這並不代表支持死道德性的理論家已經走到盡頭。劍橋大學的法哲學家 Matthew Kramer 就在承認應報理論無法證立死刑之同時，參酌納粹大屠殺的歷史，提出了有別「應報論」的另一種刑罰說：「翦除論」。
2. 依照翦除論的見解，在「極端邪惡」(extravagantly evil) 的殺人犯罪中，一個政治社群為了維繫其與人性及人類社群的關係，有義務處決此極端邪惡的殺人罪犯，以「翦除」該邪惡犯罪對人性所造成的道德污點。而所謂「極端邪惡」，最無疑義的例子就是希特勒。Kramer 認為，希特勒及其同黨並不值得人類社會提供資源供其生存。該理論的特出之處，是因為他將被當代政治與道德哲學忽略已久的「邪惡」概念放回理論核心，許老師認為這是相當重要的發展。「邪惡」概念之

¹⁷ 許家馨，應報即復仇？--當代應報理論及其對死刑之意涵初探，中研院法學期刊第 15 期，2014 年，頁 207-282。

所以有可能值得發展之處，在於其對於極端惡行賦予特殊的非難，說明為什麼有少部分的極端犯罪，在性質上必須與其他犯罪區分出來，給予特殊的刑罰。

（四）死刑不應存在的理由¹⁸：

1. 李茂生老師則認為，在解嚴動盪結束後的二十餘年間，社會並沒有因減少或停止死刑的執行而在治安上動蕩不安，這證明了死刑沒有多大的威嚇力。相反的，國家在沒有能力帶來安全感，甚或本身就是製造不安全感的根源時，其必須尋找一個讓人民崇拜、相信其能力的契機，以掩飾自身的無能，透過死刑展現自己的魄力。廢除死刑，是一個沒有替代方案道德決斷。
2. 此外，李老師也指出，無論任何應報論都無法提供明確的量刑基準。應報理論通常只是進行比對，甚至欠缺節制這些比對以避免極刑的功能。其認為死刑最核心的問題是大眾要求嚴罰的心理機制，並且只有當人們反躬自省並發揮其潛力（亦即懸置自己的能力或潛能，避免自認全能），才能在懲罰上有所節制，進而孕育出寬容、憐憫與贖罪。
3. 值得思考的是，前開提及的「翦除論」，提到針對某些「極端邪惡」之情形，認為仍然有判處及執行死刑之必要。依照學者之意見，此種「極端邪惡」最具有象徵性的代表，正是希特勒。然而，希特勒是極端邪惡，是後人所給予的評價。而在希特勒掌權的那個年代，有多少人會認為他是極端邪惡呢？或許被害的猶太人會抱持這樣的想法，但那些支持希特勒的人，恐怕不這麼想。換言之，「極端邪惡」並沒有具體定義，更會隨著世界演變而產生不同。那麼，以此作為死刑存在的理由，是否合理，似值深思¹⁹。

¹⁸ 李茂生，死刑存廢論再考——分析反對廢除死刑論者的深層心理，台灣法學雜誌第 169 期，2011 年，頁 71-89；李茂生，應報、死刑與嚴厲的心理，中研院法學期刊第 17 期，2015 年，頁 295-311。

¹⁹ 來自筆者某次與謝老師在課堂上的討論。

4. 不僅如此，當大家都舉著「為被害人實現正義」的旗子，鼓吹不應廢除死刑時，被害人真的希望如此嗎？美國犯罪被害人家屬支持團體「希望之旅」就指出，與其以死刑來玩結犯罪者的生命，他們希望能讓犯罪者與受害者家屬盡可能進行和解，希望幫助受害者家屬以及犯罪者家屬面對傷痛，才能走出傷痛。他們也經常強調「國家請不要為我殺人」，體現了雖然無比悲痛，但不認同以暴制暴的精神。而另一個由犯罪被害者家屬所組成的團體「謀殺案受害者家屬人權促進會」的成員也曾指出，死刑並無法療癒被害者家屬的創傷，亦無法還給被害者正義；死刑也不會阻止暴力繼續發生²⁰。再再顯示，對於被害人而言，死刑並不是一個最好的解決方式。

（五）無假釋終身刑：死刑的替代方案？

1. 無期徒刑，是法官不定執行期間的上限，可以被理解為「有假釋的終身刑」，同時擁有不定期刑與幾乎終身刑的雙重本質。而究竟應著重哪一面的性質，將表現在假釋的運用上。若重視「有假釋之可能」，則在經過一定期間而可以達成更生，就應該予以假釋。反之，若著眼於刑罰應報理論，那麼則會認為終身監禁應該是原則，例外的才允許在社會內執行刑罰（假釋）。
2. 而在 113 憲判 8 做成後，立法委員有呼籲要進行修法，增訂無假釋終身刑，以取代死刑。然而，這究竟是要代替死刑的哪部分？又是否能真正減少死刑的出現？抑或僅是單純的將無期徒刑升格為終身刑呢？更何況，終身刑顯然不以社會復歸為目的（因為根本沒有假釋的可能），那麼其處遇目標究竟為何？是否符合人性尊嚴，又是否真正能使受刑人獲得悔悟呢？甚而，與傳統的無期徒刑相較，終身刑實際上剝奪了假釋的希望，而成為比無期徒刑更加嚴厲的刑罰。然而，剝奪

²⁰ 廢除死刑推動聯盟，<https://www.taedp.org.tw/story/10047>，最後瀏覽日期：2025 年 11 月 28 日。

希望，是否是合理的呢？

3. 無假釋終身刑可能的爭議，包括以下幾點：

- (1) 長期監禁導致難以改變的監獄化，更可能使受刑人失去維生能力、人際關係，以及受刑人與社會的連結，甚至產生對自我認識的崩壞。
- (2) 高齡犯罪者與身心疾病犯罪者被施以無假釋終身刑，應如何處遇？
- (3) 德國聯邦憲法法院於 1977 年的判決指出，無假釋終身刑是剝奪了人性尊嚴的核心。受刑人即使在人格上有所進展，也不得不再捨棄再度獲取自由的渴望，也失去了發展人格、接受國家照護與支援的權利，以及再社會化的機會。
- (4) 依照公民與政治權利國際公約第 7 條規定：「任何人不得施以酷刑，或予以殘忍、不人道或侮辱之處遇。」同法第 10 條規定：「自由被剝奪之人，應受合於人道及尊重其天賦人格尊嚴之處遇。」而比較法上，歐洲人權法院於 2013 年的 Vinter v. United Kingdom 判決中，認定終身監禁違反《歐洲人權公約》第 3 條，禁止酷刑及不人道或有辱人格待遇的規定；加拿大最高法院於 2022 年所作成的 R. v. Bissonnette 判決中，也認定沒有假釋機會的終身刑「在一個自由民主社會中不具正當性」，而違反《加拿大人權憲章》第 12 條關於保障人民不受殘酷而非常態刑罰的規定。
- (5) 而回到我國，依照監獄行刑法第 1 條規定，監獄行刑之目的，乃係透過矯正之處遇，促使受刑人悔改向上，並培養其適應社會生活之能力。公民與政治權利國際公約第 10 條第 3 項更明定，監獄制度所制定之犯人處遇，應以使其俊悔自新、重新適應社會為目標。無假釋的終身刑，既然完全拋棄社會復歸之制度目的，又如

何能要求受刑人確實後悔，甚至重新適應社會呢？

- (6) 甚而，在監獄的管理上，本來就仰賴受刑人與管理者（監獄機關）之間的互信與希望（也就是回歸社會的盼望）。一旦制度抽調了希望，互信就會消失，監獄管理也就會瓦解，監獄暴動的風險也會大幅增加。

【試題演練】

試論死刑正當性之有無？現今有立法委員提出修法草案，計劃提出「無假釋終身刑」之概念，您認為是否可行？（30%）

自擬

【擬答】

（一）死刑無正當性存在：

1. 就死刑之正當性基礎，學者有提出「翦除論」者，主張在「極端邪惡」的殺人犯罪中，一個政治社群為了維繫其與人性及人類社群的關係，有義務處決此極端邪惡的殺人罪犯，以「翦除」該邪惡犯罪對人性所造成的道德污點。
2. 然而，本文基於以下理由，認為上開理論並不可採：
 - (1) 於翦除論中，依照學者之意見，此種「極端邪惡」是應該自社會上翦除的對象。然而，所謂「極端邪惡」並沒有具體定義，更會隨著世界演變而產生不同；以此作為死刑存在的理由，是否能真正處罰到人民心中「極端邪惡」之人，顯非無疑。
 - (2) 再者，死刑之法理基礎為絕對之應報論；然而，無論任何應報論都無法提供明確的量刑基準。應報理論通常只是進行比對，甚至欠缺節制這些比對以避免極刑的功能，導致死刑單純成為大眾要求嚴罰下的產物。

- (3) 此外，於我國解嚴動盪結束後的二十餘年間，社會並沒有因減少或停止死刑的執行而在治安上動蕩不安，這證明了死刑沒有威嚇力存在。相反的，死刑的存在，恐怕是為了使國家在沒有能力帶來安全感，甚或本身就是製造不安全感的根源時，其尋找一個讓人民崇拜、相信其能力的契機，以展現自己的魄力罷了。
- (4) 最後，美國犯罪被害人家屬支持團體「希望之旅」曾指出，與其以死刑來完結犯罪者的生命，他們希望能讓犯罪者與受害者家屬盡可能進行和解，希望幫助受害者家屬以及犯罪者家屬面對傷痛，才能走出傷痛。他們也經常強調「國家請不要為我殺人」，體現了雖然無比悲痛，但不認同以暴制暴的精神。由此可見，死刑並無法療癒被害者家屬的創傷，亦無法還給被害者正義；死刑也不會阻止暴力繼續發生。
- (5) 綜上，本文認為，死刑不但無法達到威嚇之目的，更欠缺一般刑罰所應具備的預防功能，成為國家為了展現權力所使用的極端手段。而死刑的存在，亦無法如同大眾所想的，撫平被害者家屬的傷痛，甚至不被被害者家屬讚同。據此，本文認為死刑的存在並不具有正當性。

（二）基於以下幾點爭議，本文不支持無假釋終身刑制度：

1. 無假釋終身刑制度，將出現受刑人長期監禁之現象，近一步造成難以改變的監獄化，甚至使受刑人失去維生能力、人際關係，以及受刑人與社會的連結，最後產生對自我認識的崩壞。
2. 我國監獄行刑法第 1 條規定，監獄行刑之目的，乃係透過矯正之處遇，促使受刑人悔改向上，並培養其適應社會生活之能力。公民與政治權利國際公約第 10 條第 3 項更明定，監獄制度所制定之犯人處遇，應以使其悔悟自新、重新適應社會為目標。然而，無假釋的終身

刑，既然不允許受刑人有假釋之機會，顯然完全拋棄社會復歸之制度目的，並採取單純的應報理論。此種剝奪受刑人希望的刑罰，顯然無法要求受刑人「確實悛悔」，遑論「重新適應社會」，更已經侵害受刑人之人性尊嚴。

3. 此外，於監獄管理上，本來就仰賴受刑人與管理者（監獄機關）之間的互信與希望（也就是回歸社會的盼望）。一旦制度抽調了希望，互信就會消失，監獄管理也就會瓦解，監獄暴動的風險也會大幅增加。
4. 綜上，本文認為，無假釋終身刑制度全然禁止受刑人回歸社會，是剝奪了受刑人社會復歸的「希望」，更將教化之目的排除於刑罰目的外，而與現今刑罰體制不符。而無限期的剝奪受刑人的自由，將導致受刑人產生自我認識崩壞，進而侵害其人性尊嚴，而並不具有正當性存在。

四、特別議題：被告子女與量刑²¹

（一）問題意識

1. 有許多研究顯示，父母（或主要照顧者，以下皆同）受到監禁會對受撫養之子女造成多重負面影響，例如可能導致兒童反社會行為、犯罪、心理健康問題、藥物濫用、學業失敗和失業，以及其他創傷、污名或社會和經濟壓力等。除了關懷攜子入監（監獄行刑法第 12 條）相關議題外，實有必要針對量刑階段如何兼顧被告子女之最佳利益，進行更多的檢討與改善。最高法院 111 年度台上字第 700 號刑事判決，對量刑時應如何審酌被告子女的兒童最佳利益提出了明確的觀點。
2. 本判決主要涉及之兒童權利公約條文如下：

²¹ 謝如媛，被告子女最佳利益作為量刑之首要考慮因素—評最高法院 111 年度台上字第 700 號判決，月旦實務選評第 4 卷第 4 期，2024 年 4 月，頁 100-111。

- (1) 第 3 條第 1 項：「所有關係兒童之事務，無論是由公私社會福利機構、法院、行政機關或立法機關作為，均應以兒童最佳利益為優先考量。」
- (2) 第 12 條：「締約國應確保有形成其自己意見能力之兒童有權就影響其本身之所有事物自由表示其意見，其所表示之意見應依其年齡及成熟度予以權衡。(第一項) 據此，應特別給予兒童在對自己有影響之司法及行政程序中，能夠依照國家法律之程序規定，由其本人直接或透過代表或適當之組織，表達意見之機會。(第二項)」

(二) 判決摘要

1. 兒童權利公約（下稱公約）內國法後，兒童最佳利益原則於我國司法裁判已具有規範之普遍適用性，各級法院之裁判若對兒童產生影響者，均須恰如其分地納入且始終貫徹兒童最佳利益（公約第 3 條第 1 項、聯合國兒童權利委員會《下稱童權會》第 14 號一般性意見第 14 段（a）、第 19 段、第 27 段解釋參照）。司法院 111 年度憲判字第 8 號判決並指出：「維護未成年子女最佳利益，為憲法保障未成年子女人格權及人性尊嚴之重要內涵，凡涉及未成年子女之事件，因未成年子女為承受裁判結果之主體，無論法院所進行之程序或裁判之結果，均應以未成年子女最佳利益為最優先之考量。又父母與未成年子女間之親權關係，同受憲法之保障，維持父母與未成年子女間之親權關係，原則上亦符合未成年子女最佳利益。」
2. 於刑事案件，童權會第 14 號一般性意見第 28 段列明：1. 對於與法律產生衝突（即：被告或被確認為違法）的兒童，或 2.（作為受害者或證人）法律所觸及到的兒童，以及 3. 因家長觸法而受影響的兒童，均有兒童最佳利益原則之適用。於兒童為被害人而有公約第 19

條「兒童免遭一切形式暴力侵害之權利」規定之適用時，童權會第 13 號一般性意見第 3 段(f)解釋亦表明，必須尊重兒童使自己的最佳利益在一切涉及和影響兒童事務，以及一切預防措施中作為首要考慮的權利；該號意見第 54 段解釋並強調，司法介入之決策目的應為保護涉案兒童，擴展其最佳利益（如行為人可能再犯，則也包括其他兒童的最佳利益）。故法院之量刑結果，依個案情節，倘勢必影響兒童關於公約所保障之權利或利益者，恰如其份地將兒童最佳利益納入量刑審酌因子，並做出合義務性之裁量，即屬無可迴避。

3. 應予強調的是，法院於量刑時有義務留意到兒童最佳利益之意義與目的，並不表示允許犯錯的父母或家長等主要照顧者可無故逃避適當的懲罰，相反地，是要求法院在這類情況下，應盡可能地保護無辜兒童免於受到可避免的傷害，又於兒童最佳利益及其影響之調查、評估與回饋，即可檢視已弱化的親子關係、家庭功能得否有所修復、重建或提升，倘審酌結果認係朝正向發展，即可節省刑罰之懲罰份量，避免刑罰之過剩，畢竟較穩固、健全的親情依附、理解與支持，一直是通往刑罰預防目的之康莊大道，不論對加害成人或無辜兒童之未來均然。於審酌個案有關之一切量刑或緩刑因子時，考量兒童於系統中往往處於不能為自己發聲之地位，前述「優先考量」就意味著，兒童的最佳利益與所有其他審酌因子，並非處於同等的份量級別，而係應考慮到是否不突顯兒童的利益，兒童的利益就會遭到忽視之結果（童權會第 14 號一般性意見第 37 段解釋參照）。
4. 至於被告之罪責倘已達監禁而應使之與兒童分離之程度，依公約第 9 條第 1 項（父母與兒童不分離原則）、第 18 條（父母共同養育兒童原則）、第 20 條（剝奪家庭環境之兒童照護與安置）之規定，及童權會第 14 號一般性意見第 61 段、第 69 段之解釋，法院之量刑則應具有

維護兒童最佳利益之目的性，且必須合乎必要性及最後手段性，並充分考慮到不同刑期對單一兒童或若干兒童的最佳利益所造成的衝擊，復顧及家庭環境因此而受到剝奪的兒童，是否能獲有替代方式之照護。

5. 對於兒童最佳利益之評估判斷，應特別注意以下與案情或個別兒童有關之事項：（一）兒童之意見與溝通、（二）兒童的身分、（三）維護家庭環境與保持關係、（四）兒童的照顧、保護和安全、（五）弱勢境況、（六）兒童的健康權、（七）兒童的受教育權等要素，並依個案類型、情節等有利不利兒童之具體情況，賦予上開相關要素不同比重之評價，再予整體評判。（參照童權會第 14 號一般性意見第 52 段至第 80 段、第 89 段的解釋）

（三）裁判評析：

1. 被告子女之最佳利益應作為量刑因子：

（1）依照本判決及童權會第 14 號一般性意見第 28 段明白指出的，刑事案件中考量兒童之最佳利益，並不限於上述以兒童本身為主體或客體之案件，亦應包括「因家長觸法而受影響」之兒童。然而，實務上有採取不同見解者，認為從童權會第 12 號一般性意見第 32、33 段之舉例，以及第 34 段要求對兒童參與之程序及環境應該經過特別設計，可以得知仍「是以涉及兒童本身為主體之司法及行政程序賦予兒童發表意見權」，擔任兒童監護人之父母涉及之犯罪案件不包括在內，因此「上訴人之原審辯護人主張：應給予上訴人之未成年子女陳述意見之機會，及應為上訴人之未成年子女進行最佳利益鑑定，並透過鑑定陳述意見之機會等語，並非可採且無必要。」²²

²² 最高法院 109 年度台上字第 3696 號刑事判決。

- (2) 謝老師指出，此種見解的看法，或是因從童權會第 12 號一般性意見對於「(b) 關於司法和行政訴訟的特殊義務」的說明看來，除了民事訴訟中的義務之外，有關兒童在刑事司法訴訟中的表意權，從 57 段到 64 段的内容涉及的是「兒童罪犯」以及「兒童受害者和兒童證人」，並沒有明文提到因父母觸法而受影響的兒童。不過，沒有提到，是否就代表不須保障這個權利呢？恐怕不是如此。
- (3) 首先，童權會第 12 號一般性意見第 32、33 段，強調「在對自己有影響之司法及行政程序中」要特別提供機會讓兒童表達意見，且這一規定不受任何限制地適用於所有影響到兒童的相關司法訴訟。該意見雖舉出各種情況加以說明，應只是例示，而非限縮性的列舉。而第 34 段要求須特別設計兒童參與之程序及環境，並不必然導引出兒童本身必須為程序之主體，該項要求毋寧是為了透過符合兒童特質與需求的環境設計，讓兒童得以安心並充分表達自己意見，主旨並不在於限縮兒童的表意權。
- (4) 其次，進一步考量到兒童表意權與兒童最佳利益的關係，應可以得到更清楚的答案。正如最高法院 111 年度台上字第 700 號判決所示，根據童權公約第 14 號一般性意見，對於兒童最佳利益之考量也包括「因家長觸法而受影響」之兒童。由此衍生出的問題是，在承認童權公約第 3 條第 1 項的情況下，在具體個案中能否否定該被告子女表意權之存在？童權公約第 3 條最佳利益保障和第 12 條表意權之間的關係究竟為何？
- (5) 對此，謝老師指出，童權會認為這兩個條文之間並不存在緊張關係，而是兩項一般原則的互補：第 3 條第 1 項規定了實現兒童最佳利益的目標，而第 12 條則規定了以何種方法聽取兒童意見。事實上，只有遵循第 12 條才能正確適用第 3 條。同樣的，

第 3 條強化了第 12 條的功能，促進兒童在影響其生活的所有決策中發揮重要作用（童權會第 12 號一般性意見書第 74 段）。簡而言之，委員會將第 12 條和第 3 條解釋為相輔相成：在聽取和考慮兒童意見的情況下，將促進兒童的最大利益。相反地，剝奪兒童表達意見的機會似乎違反了第 3 條規定。

- (6) 從第 12 號一般性意見第 2 段來看：「所有兒童表達意見並得到認真對待的權利是《公約》的基本價值觀之一。兒童權利委員會（委員會）將第 12 條確定為《公約》的四項基本原則之一，其他三項原則分別是不受歧視的權利、生命權和發展權、以及首先考慮兒童最佳利益。這種強調該條款的做法不僅確定了一項權利，而且在解釋和行使所有其他權利時也必須加以考慮」。由上述各個因素看來，為衡酌被告子女之兒童最佳利益，聽取兒童之意見應屬必要，兩者缺一不可。

2. 兒童最佳利益應作為量刑之首要考慮因素（a primary consideration）：

- (1) 在現行法的架構下，或許只能妥適地運用刑法第 57 條作為調節。例如將被告子女所受之影響，作為刑法第 57 條第 4 款「犯罪行為人之生活狀況」加以考量。亦有判決主張，可透過刑法第 57 條關於科刑時並「審酌一切情狀」之樞紐，將涉及被告科刑之兒童權利公約規定，以及聯合國兒童權利委員會對公約之解釋等相關規範，涵納在整體量刑審酌之事由或情節之中，並授予事實審肆應個案具體情況而為刑罰之裁量²³。然而，無論是將被告子女所受影響納為第 57 條「被告之生活狀況」，或作為「審酌一切情狀」之對象，而未作為獨立事項來考量，是否足以符合童權公約第 3 條第 1 項規定的要求，亦即：所有關係兒童之事務，無

²³ 最高法院 110 年度台上字第 1610 號刑事判決。

論是由公私社會福利機構、法院、行政機關或立法機關作為，均應將兒童最佳利益列為首要考慮因素？

- (2) 根據第 14 號一般性意見第 IV 解釋兒權公約第 3 條第 1 項第 4 款，關於「應列為首要考慮因素」(shall be a primary consideration)，一方面，「應當」一詞對各國施加了強烈的法律義務，意味著各國不得對於是否評估兒童最佳利益行使裁量權，並賦予兒童最佳利益適當的權重，以在所採取的任何行動中將之作為首要考慮因素；另一方面也意味著兒童的最佳利益與所有其他考慮，並非處於同等的份量級別，兒童的具體境況：依賴、成熟程度、法律地位，以及往往無發言權的狀況，係成立此強勢地位的理由。與成人相比，兒童更難維護自身的利益，而那些參與作出影響兒童之決定的人們，必須明確了解兒童的利益。如果不突顯兒童的利益，他們很容易被忽視。謝老師指出，兒童利益的考量與父母承擔刑事責任之間，並不是一種零和關係。毋寧說，在考量兒童最佳利益的前提下，於適度的範圍內，應透過監禁的替代選項，以及教育、諮商等更為建設性的方式，以提升父母的能力。

3. 兒童最佳利益與家庭的聯繫：

- (1) 考量被告子女之最佳利益時，維護家庭的聯繫是核心要素。即使被告之罪責已達監禁之程度，但在可選擇的範圍內，仍須在有必要藉由與父母分離以確保兒童最佳利益的情況下，才應判處監禁。兒權公約第 9 條第 1 項規定：「締約國應確保不違背兒童父母的意願而使兒童與父母分離。但主管機關依據所適用之法律及程序，經司法審查後，判定兒童與其父母分離係屬維護兒童最佳利益所必要者，不在此限。於兒童受父母虐待、疏忽或因父母分居而必須決定兒童居所之特定情況下，前開判定即屬必要。」而 CRC 第 13 號

一般性意見中之第 56 段進一步闡釋，只有在符合兒童最佳利益的情況下，才能作出將兒童帶離其父母或家庭環境的決定（第 9 條和第 20 條第 1 項）；但如果暴力案件中犯罪者是主要照顧者，上述兒童權利保障措施中，視情節嚴重及其他因素，以社會和教育手段為主的干預措施，及恢復性質的方法，通常好於單純的懲罰性司法措施。

- (2) 從上述公約規定及 CRC 第 13 號一般性意見來看，確實如判決所言，並沒有排除與父母分離的選項。然而，這並不代表父母對於兒童為傷害、虐待時，直接將兒童與父母分離「即屬維護兒童最佳利益所必要」，也不是說只要在「制度上」已建立對受虐兒童之責任通報、保護安置機制及家庭處遇計畫、有替代性照顧之存在、及相關利於兒童措施之建立與介入，即能適時彌補兒童與父母分離造成之缺憾。重點仍在於必須從兒童最佳利益的觀點，深入了解該個別案件及具體情況，聽取兒童之意見（惟須注意表明意見是兒童的權利而非義務），並從較為長期的觀點來判斷：與父母分離對於該兒童在心理上、實際上、經濟上和其他方面有何負面影響？監禁是否不可避免？或是可採取「以社會和教育手段為主的干預措施，及修復性的方法」？

4. 結論：謝老師指出，本判決指示的方向應值參考。

- (1) 兒童最佳利益的考量不限於民事或家事案件，亦及於刑事案件；同時，不限於兒童本身為被告或確定觸法、或作為被害人或證人的情形，也包括因父母觸法而導致兒童之權利或利益受影響者。
- (2) 被告子女之兒童最佳利益，在刑罰之選擇時應作為首要考慮因素，而其核心部分乃兒童與其家庭之聯繫。
- (3) 只有在符合兒童最佳利益的情況下，才能違反父母之意願將兒童與

父母分離；並且應在適當範圍內優先採取教育、諮商或修復性質的措施，而非懲罰性的手段。監禁必須合乎必要性及最後手段性，並應充分考慮不同刑期對單一兒童或若干兒童的最佳利益所造成的衝擊，並顧及家庭環境因此而受到剝奪的兒童，是否能獲有替代方式之照護。

- (4) 在判斷兒童最佳利益時，每個案件都需要進行基於事實的詳細調查，以確保重點仍然放在監禁對兒童的影響上；光是替代照顧者的存在並不足夠，仍應兼顧其他面向，並確認替代照顧者所提供的照顧是否適當。
- (5) 此外，兒童表意權的確保是實現兒童最佳利益所不可或缺的一環，兩者相輔相成。對於兒童的意見，並不是單純的聽取，必須因應其年齡和成熟程度，對這些意見給予應有的重視。在做出涉及其父母自由的決定時，應直接或間接考慮兒童的意見，因為這一決定將不可避免地對兒童的生活產生重大影響。

【試題演練】

請論述法院於量刑時應否以及如何考量兒童之最佳利益？（30%）

自擬

【擬答】

- 一、被告之量刑，應考量兒童之最佳利益，並應給予兒童陳述意見之機會：
- （一）首先，依照童權會第 14 號一般性意見第 28 段指出，刑事案件中考量兒童之最佳利益，並不限於上述以兒童本身為主體或客體之案件，亦應包括「因家長觸法而受影響」之兒童。
- （二）再者，依照兒童權利公約第 3 條第 1 項規定，所有與兒童有關之事物，均應以兒童之最佳利益為目標；同法第 12 條則規定了應以何種方法聽取

兒童意見。而就此二條間之關係，童權會認為，這兩個條文之間並不存在緊張關係，而是兩項一般原則的互補，也就是，只有遵循第 12 條（聽取兒童意見）才能正確適用第 3 條（確保兒童最佳利益）。同樣的，第 3 條強化了第 12 條的功能，促進兒童在影響其生活的所有決策中發揮重要作用。反之，剝奪兒童表達意見的機會，則將違反第 3 條保障兒童最佳權益之意旨。

二、兒童最佳利益應作為量刑之首要考量因素：

（一）根據童權會第 14 號一般性意見，兒童的最佳利益與所有其他考慮，並非處於同等的份量級別，兒童的具體境況：依賴、成熟程度、法律地位，以及往往無發言權的狀況，係成立此強勢地位的理由。與成人相比，兒童更難維護自身的利益，而那些參與作出影響兒童之決定的人們，必須明確了解兒童的利益。如果不突顯兒童的利益，他們很容易被忽視。據此，兒童利益的考量與父母承擔刑事責任之間，並不是一種零和關係。毋寧說，在考量兒童最佳利益的前提下，於適度的範圍內，應透過監禁的替代選項，以及教育、諮商等更為建設性的方式，以提升父母的能力。

（二）由此以觀，於被告量刑過程中，重點仍在於必須從兒童最佳利益的觀點，深入了解該個別案件及具體情況，聽取兒童之意見（惟須注意表明意見是兒童的權利而非義務），並從較為長期的觀點來判斷與父母分離對於該兒童在心理上、實際上、經濟上和其他方面有何負面影響、監禁是否不可避免，以及可否採取「以社會和教育手段為主的干預措施，及修復性的方法」。僅當有在符合兒童最佳利益的情況下，才能違反父母之意願將兒童與父母分離；並且應在適當範圍內優先採取教育、諮商或修復性質的措施，而非懲罰性的手段，以確保監禁合乎必要性及最後手段性。

參、保安處分

一、保安處分之定義²⁴

(一) 國家以刑罰制度作為過去所產生之犯罪行為之報復（應報），若以這個角度看待刑罰的本質時，則無法允許對於超過犯罪行為責任之國家介入。反之，若不是對於犯罪行為，而特別是將目光聚焦至犯罪行為人時，並非僅對於過去的犯罪，而是對於將來犯罪之危險性是否有必要進行因應，此即成為問題。而後者，正是保安處分的定義。而我國亦採取刑罰及保安處分雙軌制，二者於「宣告基礎」、「性質」、「機能」及「適用原則上」均有所不同。

(二) 刑罰係以行為人過去的犯罪行為為基礎，且需要以行為人之責任相呼應，不得超過責任之上限；這是近代國家所採取的「責任主義」。而保安處分則是著眼於預防之觀點，並非著重行為人過去之責任，反而僅以行為人「未來可能產生之危險」為依據，且並不受到責任主義之制約。然而，在某些保安處分（如性犯罪強制治療），則可能與刑罰具有相同之效果；這使得保安處分與責任主義之間產生相當緊張之關係。

二、性犯罪強制治療處分

(一) 條文規定：

1. 刑法第 91 條之 1：「犯第二百二十一條至第二百二十七條、第二百二十八條、第二百二十九條、第二百三十條、第二百三十四條、第三百三十二條第二項第二款、第三百三十四條第二項第二款、第三百四十八條第二項第一款及其特別法之罪，而有下列情形之一者，得令入相當處所，施以強制治療：一、徒刑執行期滿前，於接受輔導或治療後，經鑑定、評估，認有再犯之危險者。二、依其他法律規定，於接

²⁴ 武內謙治、本庄 武著，洪維德、黃士軒、林宛珊、洪士軒譯，刑事政策學，新學林出版股份有限公司，2024 年初版，頁 141-144；謝如媛，刑事政策研究成果回顧，刑事法：10. 刑事政策研究成果回顧，法律研究成果回顧與社會影響性 2001-2020，2024 年 11 月（下期），頁 205。

受身心治療、輔導或教育後，經鑑定、評估，認有**再犯之危險**者。（第一項）前項處分期間為五年以下；其執行期間屆滿前，**檢察官認為有延長之必要者**，得聲請法院許可延長之，第一次延長期間為三年以下，第二次以後每次延長期間為一年以下。但執行中認無繼續執行之必要者，法院得停止治療之執行。（第二項）前三項執行或延長期間內，**應每年鑑定、評估有無繼續治療之必要**。（第五項）」

2. 性侵害犯罪防治法第 37 條：「加害人於徒刑執行期滿前，接受身心治療、輔導或教育後，經矯正機關評估小組評估認有再犯之風險，而不適用刑法第九十一條之一規定者，矯正機關得檢具相關評估報告，送請檢察官聲請法院裁定命其進入醫療機構或其他指定處所，施以強制治療。（第一項）加害人依第三十一條第一項及第四項接受身心治療、輔導或教育後，經評估認有再犯之風險，而不適用刑法第九十一條之一規定者，由檢察官或直轄市、縣（市）主管機關檢具相關評估報告聲請法院裁定命其進入醫療機構或其他指定處所，施以強制治療。（第二項）」。
3. 性侵害犯罪防治法第 38 條：「前條強制治療之執行期間為五年以下；其執行期間屆滿前，經評估認其**再犯風險未顯著降低**，而有繼續強制治療之必要者，檢察官或直轄市、縣（市）主管機關得向法院聲請許可延長之，第一次延長期間為三年以下，第二次以後每次延長期間為一年以下。但執行中，檢察官或直轄市、縣（市）主管機關認無繼續執行之必要者，得向法院聲請裁定停止強制治療。（第一項）前三項執行或延長期間內，**應每年至少評估一次有無繼續強制治療之必要**。（第四項）」
4. 刑法與性侵害犯罪防治法適用範圍之差異？

(1) 刑法第 91 條之 1，係於民國 95 年 7 月進行修正時，方加入刑後強

制治療制度。為避免產生處罰漏洞，立法者方於民國 100 年增訂性侵害犯罪防治法第 22 條之 1（即現今第 37 條以下）。

- (2) 現行法下，刑法第 91 條之 1，係針對民國 95 年 7 月後犯性侵害犯罪者；而性侵害犯罪防治法第 22 條之 1，則係適用民國 95 年 7 月（即刑法修正前）前犯下性侵害犯罪之人。

（二）適用罪名：

（加重）強制性交、（加重）強制猥褻、乘機性交猥褻、強制性交致死、權勢性交猥褻、幼年性交猥褻、詐術性交、血親性交、公然猥褻、強制性交之結合犯規定（強盜強制性交、海盜強制性交、擄人勒贖強制性交）

（三）進入及脫離強制治療程序之判斷標準：

「有再犯之危險者」及「再犯風險顯著降低」。

（四）治療處所：

1. 現行實務運作下，適用刑法第 91 條之 1 之性侵害犯罪者，係於法務部矯正署所屬「臺中監獄附設培德醫院」進行強制治療；而適用性侵害犯罪防治法第 37 條以下之性侵害犯罪者，則係於衛福部所負責之「大肚山莊」進行強制治療。二者之主管機關雖看似不同；惟依照性侵害犯罪防治法第二十二條之一加害人強制治療作業辦法第 2 條第 3 款規定，強制治療之處所仍係委託法務部或國防部指定處所辦理。
2. 雖然現行實務運作下，將受治療者依照適用法規之不同，而分別收治於大肚山莊及培德醫院；惟二者地點實均位於臺中監獄內。

（五）釋字第 799 號解釋：

1. 刑法第 91 條之 1 第 1 項及第 2 項前段規定，與法律明確性原則尚無違背；刑法第 91 條之 1 第 1 項規定未牴觸比例原則，與憲法保障人身自由之意旨尚屬無違：

(1) 審查標準：

A. 法律明確性部分：依憲法第 8 條之規定，國家公權力對人民身體自由之限制，若涉及嚴重拘束人民身體自由而與刑事處罰有類似效果之法律規定，其法定要件是否符合法律明確性原則，固應提高審查密度（本院釋字第 636 號及第 690 號解釋參照），惟強制治療雖拘束人身自由於一定處所，因其乃以保護人民生命安全與身體健康為目的，與刑事處罰之本質不同，且事涉醫療專業，故應適用中度標準予以審查。

B. 比例原則部分：對性犯罪者施以強制治療，不可避免對受治療者人身自由造成限制，其是否違反比例原則，應採嚴格標準予以審查。

(2) 「有再犯之危險」及「再犯危險顯著降低」，固應依性犯罪之原因，個案判斷，然非不能經由專家依其專業知識及社會通念加以認定及判斷，並可由司法審查予以確認，尚無不明確之情形（本院釋字第 545 號解釋參照）。因此，系爭規定一及四規定分別以「有再犯之危險」、「再犯危險顯著降低」作為對性犯罪者宣告及停止強制治療之要件，尚無違法律明確性原則。

(3) 治療者雖因接受強制治療，致使人身自由遭受限制，然限制受治療者人身自由之目的係為確保治療之有效實施，並避免其於治療期間發生再犯之行為，乃係基於防衛社會安全之考慮，其目的係為維護社會大眾人身安全、性自主權及人格權等特別重要公共利益，核屬正當。至目前實施強制治療之強制方法，係採限制受治療者於固定處所作為治療之方式，其是否屬達成目的之必要手段，雖亦有主張得於固定處所治療與社區治療，交互採用之模式者，或採用電子腳鐐監視作為強制住院之替代手段者，但尚未有被普遍公認，可達成與強制於固定處所治療相同之社會預防效果，又限制受治療者人身

自由較小之方法。故依系爭規定一施以強制治療，因而對受治療者人身自由造成限制，乃侵害最小之不得已方法，從而尚不違反憲法第 23 條比例原則。

2. 刑法第 91 條之 1 第 2 項前段規定及性侵害犯罪防治法第 22 條之 1 第 3

項規定關於強制治療期間至再犯危險顯著降低為止之部分，與憲法比例原則尚屬無違。惟若干特殊情形之長期強制治療仍有違憲之疑慮，有關機關應依本解釋意旨有效調整改善：

- (1) 系爭規定三及四均規定治療期間「至其再犯危險顯著降低為止」，係以受治療者「再犯危險顯著降低」為施以強制治療之期限，並未另設確定或最長治療期限。
- (2) 查性犯罪行為成因多元，高度取決於行為人個人身心狀況，具個案主觀差異性，難以脫離行為人個別脈絡而抽象歸納、提列共通性之性犯罪原因。因此，欲防範性犯罪行為人於刑罰執行完畢後再為性犯罪之行為，而對社會大眾造成危害，即須針對其個人具體情狀施以強制治療，並應依其具體性犯罪傾向與特徵，設計與規劃個案最適治療方法與程序，使其再犯之危險顯著降低，以保護社會大眾之安全，而就此所需治療期程，理應因人而異，難以齊一化設定。
- (3) 是立法者就強制治療之期間，不設確定期限或最長期限，而是以受治療者經治療後，其再犯危險顯著降低之個別化條件為停止治療之時點，應屬必要，於社會大眾安全需求之維護，與受治療者人身自由等自由權所蒙受之限制兩者間，尚難調有失均衡。另強制治療係以降低被治療者再犯危險為治療目標，此目標應為受治療者所認知，因此，以治療目標之有效達成作為強制治療之期限，在通常情形下，尚屬可合理期待受治療者得以承受者。綜上，於此範圍內，系爭規定三及四與憲法比例原則尚屬無違。

- (4) 惟性犯罪者之犯罪成因複雜多變，對此類犯罪者之治療效果，亦因人而異，因此不無可能發生受治療者因其異常人格或身心狀況，致使其雖經相當長期之強制治療，仍未達到或無法達到其再犯危險顯著降低之治療目標之狀況。此等情形下，若仍毫無區別地持續對該等受治療者施以強制治療，將形同無限期施以強制治療，從而使受治療者變相遭無限期剝奪人身自由，甚至形同終身監禁，就受治療者而言，已逾越可合理期待其得以承受之限度。於此範圍內，現行規定即有因社會大眾安全需求之公共利益與受治療者所承受之人身自由遭受限制兩者間嚴重失衡，致使有違反比例原則之損益相稱性要求而牴觸憲法之疑慮。
- (5) 從而，為避免牴觸憲法之疑慮，縱依個案具體情形而確有必要對受治療者長期持續施以強制治療，立法者亦應於制度上建立更能促進其得以停止強制治療而重獲自由、復歸社會之配套機制或措施。受治療者接受強制治療之時間愈長，協助或促進其得以停止強制治療之配套機制或措施即應更加多元、細緻。唯有如此，方能確保為維護社會大眾人身安全、性自主權及人格權等特別重要公共利益，而限制受治療者之人身自由之強制治療制度，得以持續地合於憲法比例原則之要求。就實體面而言，立法者對於經長期治療仍未達到或無法達到其再犯危險顯著降低治療目標之受治療者，尤應檢討引進多元處遇措施，以輔助或補充常態治療程序，以作為受治療者復歸社會之準備。就程序面而言，鑑於對受治療者長期於固定處所施以強制治療可能產生治療或療效疲乏效應，甚至使長期受治療者逐漸為社會所遺忘或甚至自我遺棄，進而難以積極護衛其自身之權利，故施以強制治療達一定年限時，是否繼續施以治療，應由法官重為審查決定。至法官審查之頻率，應依強制治療期間之長短而定；強

制治療期間愈長，由法官定期審查之頻率即應愈高。

3. 性侵害犯罪防治法第 22 條之 1 第 1 項規定，尚不違反法律不溯及既往原則及信賴保護原則：

(1) 查依系爭規定二施以強制治療者，雖係針對 95 年 6 月 30 日即刑法第 91 條之 1 規定修正施行前曾犯性侵害犯罪之加害人，然仍以該等加害人於該法施行後尚在服刑中，且於裁定時經鑑定、評估仍有再犯之危險，為其適用之條件，並非僅因加害人過去曾犯性侵害犯罪行為，即一律依此規定施以強制治療。究其目的，乃為更正確鑑定、評估加害人未來有無再犯之危險，觀察性犯罪者過去之犯罪情形及鑑定、評估其接受治療、輔導後，於裁定時之狀況，決定是否應採取強制治療措施，以避免該等性侵害犯罪加害人再犯性侵害行為，而嚴重妨害社會安全。易言之，上開規定之意旨，係以再犯之危險仍繼續存在為接受強制治療之前提；反之，如經鑑定、評估已無再犯之危險，即無適用上開規定之餘地，是尚難謂上開規定牴觸法律不溯及既往原則。

(2) 整體而言，性侵害犯罪行為完成於 95 年 7 月 1 日刑法第 91 條之 1 規定修正施行前之性侵害犯罪加害人，對其於服刑期滿後不受固定處所強制治療處遇，而得以逐漸回歸正常社會生活之經營，尚可認是正當且非不值得保護之信賴利益。

(3) 然而，系爭規定二既係針對經鑑定、評估程序而認有再犯性犯罪危險之受刑人所為，其目的即仍在藉由強制治療而使該等受刑人重獲自由後再犯危險顯著降低，以維護社會大眾之安全，係著眼於憲法上之特別重要公共利益，應優先於受治療者不受強制治療之信賴利益。因此，基於保護社會大眾安全憲法上特別重要公共利益，對有再犯性犯罪危險之受刑人，即有接續其徒刑之執行完畢後施以強制

治療之正當性與必要性，性犯罪受刑人個人之信賴利益應行退讓。

綜上，系爭規定二與信賴保護原則尚無牴觸。

4. 刑事訴訟法及性侵害犯罪防治法均未規定應賦予受處分人於法院就聲請宣告或停止強制治療程序，得親自或委任辯護人到庭陳述意見之機會，以及如受治療者為精神障礙或其他心智缺陷無法為完全之陳述者，應有辯護人為其辯護，於此範圍內，均不符憲法正當法律程序原則之意旨。有關機關應自本解釋公布之日起 2 年內檢討修正。完成修正前，有關強制治療之宣告及停止程序，法院應依本解釋意旨辦理。
5. 現行強制治療制度長年運作結果有趨近於刑罰之可能，而悖離與刑罰之執行應明顯區隔之憲法要求，有關機關應自本解釋公布之日起 3 年內為有效之調整改善，以確保強制治療制度運作之結果，符合憲法明顯區隔要求之意旨：

- (1) 按對性犯罪者於刑罰執行完畢後，再施以強制治療，旨在使具高再犯危險之性犯罪者，經由強制治療程序而降低其再犯危險，以保護社會大眾安全，並協助受治療者復歸社會。是強制治療本質上應為一種由專業人員主導實施之治療程序，受強制治療者係立於「病人」之地位接受治療，並以使受治療者有效降低其再犯危險為目的，而非對受治療者之刑事處罰。因此，強制治療制度之建構，自應以使受治療者得受有效治療，俾利日後重獲自由為核心指標，截然不同於犯罪之處罰。從而，強制治療制度之具體形成，包括規範強制治療之制度與其實際執行，無論涉及者為強制治療之治療處所（包含空間規劃及設施）、施以治療之程序、管理及專業人員之配置、參與等，整體觀察，須與刑罰之執行有明顯區隔，始為憲法所許。強制治療制度如符合憲法明顯區隔之要求，即不生牴觸以犯罪之處罰為前提之罪刑法定或一事不二罰原則之問題。

- (2) 強制治療制度於憲法上應符合明顯區隔之要求，就治療處所（包含空間規劃及設施）而言，強制治療應於與執行刑罰之監獄有明顯區隔之處所為之，且一般人可從外觀清楚辨識其非監獄。次就受治療者生活管理方面而言，受治療者之生活起居與行為活動之紀律要求，均應以達成治療目標之必要範圍為其限度，於不妨礙實施治療之前提下，應盡可能使受治療者享有正常生活，以作為復歸社會生活之準備，並與監獄受刑人之矯治處遇明顯有別。再就如何治療方面而言，治療應由專業人員本於專業性、個別性原則，依據受治療者之具體情狀而主導實施，並應以有效降低其再犯危險，從而使其得以復歸社會為貫串整體治療程序之目標。
- (3) 刑法第 91 條之 1 所建立之強制治療制度，就強制治療對受治療者人身自由之限制而言，無論是實施要件或期限，在法規範面雖尚無牴觸憲法之虞，然就強制治療之具體實施而言，由於法律規範密度相當低，其實際運作情形高度取決於執行機關之指揮與決定，除受限於行政資源外，亦因強制治療執行機關與刑罰執行機關同一，長年運作結果，已有趨近於刑罰執行之可能，從而悖離憲法明顯區隔之要求。基此，為避免強制治療制度未來受違憲之指摘，有關機關應自本解釋公布之日起 3 年內就下列三點事項為有效之調整改善，以確保強制治療制度運作之結果，符合憲法明顯區隔要求之意旨。
- (4) 首先，鑑於強制治療之治療本質與目的，與其他種類保安處分之性質與運作模式存有相當大之差異，因此，其具體實施所應遵循之規範，例如得為治療處所之條件、施以治療之程序、內部管理與紀律要求及專業人員之資格與配置等事項，應有符合治療本質與目的之更詳盡法律明文規範。
- (5) 其次，刑法第 91 條之 1 僅規定令人相當處所，施以強制治療，保

安處分執行法則進一步指明強制治療處所為公私立醫療機構，目前強制治療處所設於監獄中主供受刑人醫療服務之附設醫院，並與監獄附設醫院共用同一建築設施。影響所及，除外觀上難以區辨究為刑罰執行處所，抑或強制治療處所外，也因該建築設施對外須有一致之管制、警衛措施，致使受治療者對外亦一律受到有如受刑人般之管制；甚至亦可能因共用內部警衛設施，而使受治療者於內部管制部分，亦受到有如受刑人般之處遇。因此，強制治療處所設於監獄附屬設施內時，長期以往，易使處於同一空間內之受治療者與受刑人受到趨同之處遇；至少不易使強制治療之實施，明顯有別於刑罰之執行。此外，於該處接受醫療服務者，究屬受強制治療者，抑或受刑人，亦非明顯可辨，極易因監獄附屬設施之外觀而產生標籤效應，使受治療者蒙受誤解。凡此均有違反憲法明顯區隔之要求。是強制治療處所應於管理上、空間上與監獄及其附屬設施有足以辨識其不同之明顯區隔，不應設於監獄或監獄附屬醫療院所。

- (6) 再者，為落實憲法明顯區隔之要求，配合未來強制治療之相關執行性法律規範之制定，執行機關除本於個別性與專業性原則，針對受治療者具體情狀進行鑑定、評估，並擬定個別治療計畫，施以適當之治療外，尚應致力於協助與促成受治療者達成再犯危險顯著降低，因而得以重獲自由、復歸社會之治療目標。其中，應包括藉由共通適用之累進性處遇指標之建立，使受治療者得以預期其接受治療之各階段指標及相應之鬆綁措施，以正向期待停止治療之日。與此同時，治療機構對受治療者於治療期間之人身自由與諸如個人隱私、自由通訊與會客等相關自由權之限制，亦僅得於個案適當且必要之範圍內為之，與刑罰之執行應有明顯不同，俾便於保護社會大眾之安全利益之同時，亦適切維護受治療者受憲法所保障之人身自

由與其他自由權。

（六）強制治療制度之疑慮與檢討²⁵：

1. 明確性原則：

(1) 審查標準：本號解釋稱因涉及醫療專業，而降低審查密度，或許是受到釋字第 690 號解釋的影響（Sars 案）。然而，學者有指出，當時的背景是科學家無法確認疾病的種類及來源，亦無法得知該用何等方式有效預防，故立法者有必要使用例示及概括文字，授權行政部門作出必要處理。相對的，性犯罪強制治療並不具備此種急迫壓力，大法官貿然降低審查標準，並不妥適。

(2) 而強制治療制度以「再犯危險」作為判斷標準，其實並不能讓一般人知悉究竟「危險性多高的性犯罪者」需要進入強制治療程序。再者，所有可能會被系爭規定規範到的人，都不知道自己要多配合監獄與社區中的輔導治療，或是多配合治療，才能避免自己被送入監禁式治療中。且當立法者並未明確在條文中載明需要被強制治療的再犯危險程度，將會使得性犯罪者需不需要接受強制治療，以及能否停止，取決於治療團隊、檢察官與法院對法條的詮釋方式，此處的詮釋很難不受到輿論氛圍的影響。

2. 比例原則：

(1) 目的：強制治療的目的，兼具有治療與隔離。

(2) 手段適合性：學者指出，強制治療若係以「有些性侵害犯罪的發生，是因犯人的精神或心理異常所導致，因此有治療的必要與可能」，那麼這個議題在精神醫學界的爭議相當大。以美國精神醫學會（APA）為例，其就指出，精神醫學並無能力能可靠的預測人類

²⁵ 李佳玟，性犯罪者刑後強制治療制度的法律明確性審查，台灣法律人第 4 期，2021 年 10 月，頁 122-144；李佳玟，性犯罪者刑後強制治療制度的比例原則審查，台灣法律人第 5 期，2021 年 11 月，頁 115-137；謝如媛，刑事政策研究成果回顧，刑事法：10. 刑事政策研究成果回顧，法律研究成果回顧與社會影響性 2001-2020，2024 年 11 月（下期），頁 210-212。

的未來危險性。據此，於我國採取嚴格審查標準之前提下，大法官似應作出強制治療不符手段適合性之結論。

- (3) 必要性：學者指出，現行法下僅以「有再犯危險」作為判斷標準，不僅與明確性原則相違，亦無法通過必要性的審查。於修法方向上，宜參考美國性暴力犯罪者法，加上「加害人有精神異常及/或人格障礙，致其對己之性暴力行為欠缺有效控制能力」之要件，或直接於條文中明定「高再犯風險」之文字。就罪名部分，如血親性交罪、公然猥褻罪等並未實質侵害他人性自主決定權之犯罪類型，不應動用到剝奪人身自由的手段，強制其接受治療。
- (4) 手段衡平性：現行制度下，強制治療並未設有最長期限之規定，僅要求法官應定期審查。學者指出，依照公民與政治權利國際公約第35號一般性意見第15點來看，其要求「可能的總拘禁時間是有限度的」。聯合國人權事務委員會顯然認為，即便是為了處理對社會具有高度威脅的人，都不能對這個進行無限期的拘禁。據此，我國強制治療制度，仍然應該設有最長期限之規定，以合乎比例原則之要求。
3. 明顯區隔原則：誠如釋字第799號解釋所言，現行實務運作下，強制治療之受處分人與受刑人活動範圍幾乎完全重疊，且從外觀上亦看不出差異。釋字第799號解釋聲請人盧恩本也曾強調，其生活作息、基本權利受限制之程度等，均與監獄受刑人完全相同。然而，大法官卻並未於此宣告違憲，恐怕給了立法機關偷懶的空間。
4. 保安處分再思考：由前述可知，由於保安處分著眼於行為人的「未來危險性」，並非基於行為人過去的犯罪行為，故並不受到責任原則之規制，卻也隨之產生許多過度侵害人權的疑慮。面對此問題，或許可以思考的是：我們為何一定要將刑罰之執行與保安處分相區分？以性犯

罪強制治療為例，相關的治療方法，為何不能在受處分人受刑之執行時一併進行呢？若能將二者完整整合，那麼於服刑結束後，也就沒有再施以保安處分的必要，更無需再透過「明顯區隔原則」來強調二者的不同。由此以觀，我國所採取之刑罰與保安處分雙軌制，究竟是否妥當？恐怕值得深思²⁶。

【試題演練】

試問現行強制治療採取「定期延長、無最長期限限制」之模式，有無違反比例原則之疑慮？（30%）

自擬

【擬答】

一、系爭制度可能違反比例原則：

- （一）按比例原則之審查，共可分為目的正當性、適當性、必要性與衡平性四階段。而強制治療之目的係，係在治療受處分人之同時，保障社會大眾之安全，其目的固然正當。
- （二）惟，針對適合性部分之審查，需判斷強制治療制度是否能有效達成所稱治療及預防之目的。而鑑於強制治療之手段對於人民之人身自由限制甚鉅，而應採取嚴格標準審查。而美國精神醫學會（APA）曾指出，精神醫學並無能力能可靠的預測人類的未來危險性。據此，所稱「治療」，究竟能否達成「避免受處分人再犯」之目的，顯非無疑。據此，本文認為於嚴格之檢驗下，現行強制治療制度應無法通過適合性之審查。
- （三）次查，針對手段必要性，現行法下僅以「有再犯危險」作為判斷標準，不僅標準流於恣意，更有過度侵害人權之疑慮。系爭制度既以無最長期限之

²⁶ 來自筆者與謝老師某次上課時的討論。謝老師亦提及，比較法上，日本並沒有保安處分制度的設計，且嚴格審視所有以特別預防為出發點的刑罰處分，避免產生過度侵害人權之疑慮。這樣的想法，似乎值得我國參考。

人身自由侵害作為手段，則於實行客體上，至少應以「具有精神異常及/或人格障礙，致其對己之性暴力行為欠缺有效控制能力」之要件，或直接於條文中明定「高再犯風險」之文字進行限縮；對於其餘之受處分人，則應透過電子腳鐐、定期回報等侵害較小之手段。再者，現行法下將血親性交罪、強制猥褻罪等根本並未實際侵害他人性自主法益之犯罪納入適用，使犯下此類犯罪之行為人面臨無限期人身自由之限制，顯然非屬最小侵害手段，而不合必要性甚明。

（四）又就衡平性而言，依照公民與政治權利國際公約第 35 號一般性意見第 15 點來看，其要求「可能的總拘禁時間是有限度的」。聯合國人權事務委員會顯然認為，即便是為了處理對社會具有高度威脅的人，都不能對這個進行無限期的拘禁。據此，我國強制治療制度，仍然應該設有最長期限之規定，否則即無從通過衡平性之審查。再者，系爭制度所欲達成的目的，是在「防止潛在的社會安全危害」；且在此之潛在性社會安全危害，更可能有預測困難、甚至失準之問題，此觀前開美國精神醫學會（APA）之意見甚明。然而，系爭制度卻採取「顯在人身自由侵害」作為手段，本文認為，此種手段所侵害之權利甚鉅，卻在防止「不見得會發生」的法益侵害結果，顯然不具衡平性。

三、精神障礙者與監護處分²⁷

（一）現行規範：

1. 刑法第 19 條：「行為時因精神障礙或其他心智缺陷，致不能辨識其行

²⁷ 洪士軒，簡評台灣司法精神鑑定與監護處遇制度——以日本法為比較中心，法官協會雜誌第 23 卷，2021 年 12 月，頁 112-126；張麗卿，精神病犯的鑑定與監護處分——兼談殺警案與弑母案，月旦法學雜誌第 309 期，2021 年 2 月，頁 57-79；張麗卿，2022 年精神障礙觸法者新制之法規範與實務，月旦法學雜誌第 328 期，2022 年 9 月，頁 87-101；黃士軒，日本「醫療觀察法」審判制度之探討——兼與我國刑法監護處分制度的比較，高大法學論叢，第 19 卷第 2 期，2024 年 3 月，頁 123-190；謝如媛，刑事政策研究成果回顧，刑事法：10. 刑事政策研究成果回顧，法律研究成果回顧與社會影響性 2001-2020，2024 年 11 月（下期），頁 206-210。

為違法或欠缺依其辨識而行為之能力者，不罰。(第一項)行為時因前項之原因，致其辨識行為違法或依其辨識而行為之能力，顯著減低者，得減輕其刑。(第二項)」

2. 刑法第 87 條：「因第十九條第一項之原因而不罰者，其情狀足認有再犯或有危害公共安全之虞時，令入相當處所或以適當方式，施以監護。(第一項)有第十九條第二項及第二十條之原因，其情狀足認有再犯或有危害公共安全之虞時，於刑之執行完畢或赦免後，令入相當處所或以適當方式，施以監護。但必要時，得於刑之執行前為之。

(第二項)前二項之期間為五年以下；其執行期間屆滿前，檢察官認為有延長之必要者，得聲請法院許可延長之，第一次延長期間為三年以下，第二次以後每次延長期間為一年以下。但執行中認無繼續執行之必要者，法院得免其處分之執行。(第三項)前項執行或延長期間內，應每年評估有無繼續執行之必要。(第四項)」

3. 保安處分執行法第 46 條規定：「因有刑法第十九條第一項、第二項或第二十條之情形，而受監護處分者，檢察官應按其情形，指定下列一款或數款方式執行之：一、令入司法精神醫院、醫院或其他精神醫療機構接受治療。二、令入精神復健機構、精神護理機構接受精神照護或復健。三、令入身心障礙福利機構或其他適當處所接受照顧或輔導。四、交由法定代理人或最近親屬照顧。五、接受特定門診治療。六、其他適當之處遇措施。(第一項)檢察官為執行前項規定，得請各級衛生、警政、社會福利主管機關指定人員協助或辦理協調事項。(第二項)」

4. 刑法第 98 條：「依第八十六條第二項、第八十七條第二項、第三項規定宣告之保安處分，其先執行徒刑者，於刑之執行完畢或赦免後，認為無執行之必要者，法院得免其處分之執行；其先執行保安處分者，

於處分執行完畢或一部執行而免除後，認為無執行刑之必要者，法院得免其刑之全部或一部執行。(第一項)依第八十八條第一項、第八十九條第一項規定宣告之保安處分，於處分執行完畢或一部執行而免除後，認為無執行刑之必要者，法院得免其刑之全部或一部執行。

(第二項)依刑事訴訟法第一百二十一條之一第一項或第三項前段宣告之暫行安置執行後，認為無執行刑之必要者，法院得免其刑之全部或一部執行。(第三項)」

(二) 制度設計：

1. 多元處遇性質：

(1) 依照現行規定，監護處分並不全然屬於拘束人身自由之保安處分；檢察官可參酌專家之評估意見，進行最為妥適之判斷，並據此施以保安處分執行法第 46 條第 1 項各款內容之監護處分。

(2) 然而，刑法第 87 條第 2 項則規定，針對限制責任能力人，原則上刑後執行監護處分，僅例外於必要時方得於刑之執行前為之。學者指出，對於精神障礙處者而言，先執行刑罰，不僅無助於病情之改善，反而可能使之加劇，且若精神障礙處法者並無接受良好治療，對刑罰感受亦弱，並不利於實現刑罰之矯正或再社會化之功能。

2. 不定期暨定期延長制度：隨著釋字第 799 號解釋針對不定期之性犯罪強制治療制度宣告合憲後，立法者遂於 2022 年針對精神監護處分進行修正，並與性犯罪強制治療採取相同模式。

3. 免予執行之規定：

(1) 先執行刑罰，而免予執行監護處分：依照刑法第 98 條第 1 項前段規定，監護處分之執行，可能於徒刑執行後方為之，且可能被減免。但學者對此有指出，對於精神障礙觸法者，宜以治療為優先，而不宜先執行刑罰，若先執行徒刑，後執行保安處分，可能使監護

處分之效益大打折扣。何況監護處分之發動，係精神障礙觸法者處於「情狀足認有再犯或有危害公共安全之虞」的狀態，在此情境下，似乎宜全面先行監護處分，提供精神障礙觸法者良好的治療，自難有先執行刑罰之必要。

- (2) 先執行監護處分，而免予執行刑罰：學者指出，此規定應屬良法。屬於限制罪責能力之人的精神障礙觸法者，接受監護處分後，病情控制得宜而「無繼續執行之必要」，可認為其辨識能力或控制能力已經大有改善，對社會已經無危害之虞，個案上可能已無執行刑罰的必要，自得免除刑罰執行之一部或全部，幫助其早日回歸社會，並適度節約有限之司法資源。

(三) 增訂暫行安置新制：

1. 制度目的：刑事訴訟法增訂暫時安置，起因於近年我國發生數件精神障礙觸法者攻擊事件，造成民眾恐慌，基於社會安全網的需求，避免這些觸法者可能在訴訟期間危害他人。
2. 要件：
 - (1) 形式要件：暫行安置屬於強制處分之一，於形式上應合乎法官保留原則。
 - (2) 實質要件：法官需要判斷以下幾點要件：1. 犯罪嫌疑重大，且 2. 有事實足認有刑法第 19 條第 1、2 項原因存在，3. 有危害公共安全的可能，以及 4. 緊急必要性。而此部分與監護處分不同；監護處分之判決宣告，是於審程序經過嚴格證據法則，調查被告罪責能力之有無，以及有無「再犯或有危害公共安全之虞」，法院做成的慎重判斷。相形之下，暫行安置的裁定，則可能在偵查或審判中做成，並無需達到嚴格證明程度。
3. 延長：暫行安置之期間為六個月以內，但若需要延長，每次不得超過

六月，最長期間累計不得超過五年。

4. 撤銷：暫行安置之撤銷分為「裁定撤銷」與「視為撤銷」二者。前者係指暫行安置之原因或必要性消滅或不存在，後者則係指暫行安置後，法院判決並未宣告監護。

（四）制度改革方向：

1. 洪士軒律師：

- (1) 現行法下，認定有無責任能力及認定監護處分之必要性、期間時，均需藉由精神科醫師所做成之鑑定報告加以判斷。然而，責任能力有無之認定與治療必要性、期間是否得於同一鑑定中進行，值得檢討。責任能力之判斷，是針對「過去」行為時對象之狀態，故需要搜集當時證據。反之，監護處分之必要性與期間之判斷，則是「預測」將來是否會有再犯可能性並依此決定，這需要相當時間進行觀察。據此，責任能力之鑑定與監護處分必要性與期間之鑑定，最好是分開進行較佳。
- (2) 此外，若將二鑑定程序分開進行，考量避免證據滅失與距離事件發生時越近，責任能力之鑑定越準確等因素，責任能力之鑑定應該在偵查階段進行。洪律師參考日本法之規定，建議可將鑑定重點移致偵查階段，以解決將急需治療之對象可以受到妥善醫療外，也不至於對精神障礙犯罪者之人身自由造成過度侵害。
- (3) 針對暫行安置部分，固然可補足現今監護制度之不足；然而，就暫行安置之期間最長可達 5 年部分，究竟是如何決定的，又是否過長，可能產生疑慮，且立法過程亦未見相關說明。

2. 張麗卿老師：

- (1) 執行監護宜有專設的機構、執行的方式宜適當：張老師指出，監護處分的場所應該是成效的關鍵，若有專業的司法精神病院，有充足

的專業醫師與設備，監護處分的理想才能實踐。因此，除戒護安全的能力外，專業的司法精神醫院，也要有能處理臨時內外科急症的能力。此外，心智缺陷的行為人比較不具有攻擊性，可能帶來的社會危險是比較低的，所以不需要社會防衛，此時應以輔導或其他適當方式，如令入適當精神護理機構、精神復健機構或身心障礙福利機構接受照護或輔導，或接受門診治療、最近親屬照護。是以，監護之處所及方式應基於受監護處分人之需求差異，分流至司法精神病院，或至其他適當之處所，且應接受監護者之需求提供相應之處遇階段計劃。

- (2) 執行監護應先於執行刑罰：有第 19 條第 2 項及第 20 條原因之限制責任能力的精神疾病犯罪人，可能同時被宣告刑罰與監護處分，如果與刑罰同時宣告，理論上應當先執行監護處分，然後刑罰。理由是，先把行為人的精神狀態改善，才能夠在監獄裡接受教誨，參加作業，並與其他受刑人相處，徒刑的執行才會有意義。

- (3) 監護的期限不宜改為絕對無定期：

A. 張老師指出，監護處分的目的是為了改善病患的精神狀態；但我們必須接受一個事實：「生理上的病相對容易治療，精神上的病則是相對困難」。所以，希望一次的監護處分就能解決精神病患的問題，是一種不切實際的想法。換言之，不能為了迎合輿論，為了弭平社會大眾的恐慌，對於精神病患採取太長久的監護處分，至於無限期的監護處分則更不應該使用。據此，依照我國刑法規定，監護處分期限第一次最長期應以 5 年為限，此部分符合精神疾病治療的黃金期間。但若成效不足，雖可考慮是否繼續監護，但繼續的期限不能太久。修法若改為 5 年加上兩次 3 年延期監護，最長 11 年，已經足夠。超過 11 年，如病

情仍然無法治癒或好轉，只得另闢蹊徑，以其他方式替代予以對付此類精神病犯。刑法畢竟有其規範功能的不完整性，無法負擔所有的社會任務。

- B. 此外，張老師並指出，健全社會安全網的最後一哩路是增訂「社區矯治法」，在該法中研議推動「社區矯正之科技監控制度」，因為無論從精神病犯的協助社會復歸、預防再犯，都有其功能與意義。監護一定期間後，必須讓病犯回歸社會。回歸社會時的處遇，社區矯治法就可以發揮作用。司法精神醫院的受監護者，在一定期間後，可將其納入社區矯治對象，這樣也能彌補社會安全網的漏洞。

肆、機構內處遇：強制工作²⁸

一、制度背景：

強制工作制度之立法目的，乃係自特別預防之觀點出發，旨在使「有犯罪之習慣或因遊蕩或懶惰成習而犯罪者」，透過強制工作之方式培養其勤勉工作，並學習一技之長。而具體做法，係採取令受處分者於受刑之執行前，拘束其人身自由於特定勞動場所場所先行施以強制工作。

二、舊法條文規範：

- (一) 刑法第 90 條規定：「有犯罪之習慣或因遊蕩或懶惰成習而犯罪者，於刑之執行前，令入勞動場所，強制工作。(第一項) 前項之處分期間為三年。但執行滿一年六月後，認無繼續執行之必要者，法院得免其處分之執行。(第二項) 執行期間屆滿前，認為有延長之必要者，法院得許可延長之，其延長之期間不得逾一年六月，並以一次為限。(第三項)」
- (二) 竊盜犯贓物犯保安處分條例第 3 條第 1 項規定：「十八歲以上之竊盜犯、贓物犯，有犯罪之習慣者，得於刑之執行前，令入勞動場所強制工作。」、第 5 條第 1 項前段規定：「依本條例宣告之強制工作處分，其執行以三年為期。但執行已滿一年六個月，而執行機關認為無繼續執行之必要者，得檢具事證，報請檢察官聲請法院免予繼續執行。」(現已廢止)
- (三) 組織犯罪防制條例第 3 條規定：「發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處三年以上十年以下有期徒刑，得併科新臺幣一億元以下罰金；參與者，處六月以上五年以下有期徒刑，得併科新臺幣一千萬元以下罰金。但參與情節輕微者，得減輕或免除其刑。(第一項) 犯第一項之罪者，應於刑之執行前，令入勞動場所，強制工作，其期間為三年。(第三項)」(現已刪除)

²⁸ 謝如媛，釋字第 812 號解釋鑑定意見書。

三、釋字第 812 號解釋：

（一）主文（節錄）：

1. 刑法第 90 條第 1 項及第 2 項前段規定、竊盜犯贓物犯保安處分條例第 3 條第 1 項規定，就受處分人之人身自由所為限制，均違反憲法第 23 條比例原則，與憲法第 8 條保障人身自由之意旨不符，均應自本解釋公布之日起失其效力。
2. 組織犯罪防制條例第 3 條第 3 項規定：「犯第 1 項之罪者，應於刑之執行前，令入勞動場所，強制工作，其期間為 3 年。」（嗣 107 年 1 月 3 日修正公布第 3 條，但本項並未修正）就受處分人之人身自由所為限制，違反憲法比例原則及憲法明顯區隔原則之要求，與憲法第 8 條保障人身自由之意旨不符，應自本解釋公布之日起失其效力。

（二）解釋文（節錄）：

1. 強制工作制度違反比例原則及憲法第 8 條人身自由之保障：
 - (1) 適當性：為實現上開目的所採之強制工作手段，係於受處分人受刑之執行前，拘束其人身自由於特定勞動場所，然而是否有助於矯正受處分人之犯罪習慣、遊蕩或懶惰習性，並預防其日後再犯，固非毫無疑問，不過能得以學習謀生之一技之長，依常理而言，具有一定程度助於受處分人出獄後經營正常社會生活，並進而預防其日後再犯，應認為尚無違反適當性原則。
 - (2) 必要性：
 - A. 立法者雖自特別預防之角度制定該條強制工作之規定，然而犯罪特別預防為刑罰重要目的之一，包括徒刑在內之各種刑罰之科處與執行均係為了貫徹特別預防目的之設計，犯罪特別預防並非須藉由獨立於刑罰手段之外，另以對人身自由之限制程度不下於刑罰之強制工作手段始得為之。

B. 依照目前監獄行刑實務，各監獄亦多已開辦各種技能訓練課程，受刑人於刑罰執行期間即得以接受適當之技能訓練，並無為此另施以強制工作之必要。況本條第 1 項係規定受處分人於「刑前」為強制工作，強制工作期滿後，仍應入監執行有期徒刑，並非直接回歸社會，從而受處分人於強制工作期間內所習得之技能，於刑滿出獄時極可能已生疏，致復歸社會之功能大為降低甚或難以發揮。

C. 本條係為矯正有犯罪習慣或因遊蕩、懶惰成性者預防其再犯而設，卻不問受處分人犯罪行為之型態與情節輕重，一律令強制工作 3 年，就其所欲達成之目的而言，顯非對受處分人侵害最小之必要手段，基此，本條規定實非對受處分人侵害最小且為達成目的所無可替代之必要手段，而與必要性原則有違。

2. 強制工作之執行，違反憲法明顯區隔原則之要求：

(1) 我國採取刑罰及保安處分雙軌制，因此依照釋字第 799 號之旨，二者之區別要符合明顯區隔原則之憲法誠命，使其評價上能茲以區別，否則即生重複評價，實質上違反一罪不二罰原則。就強制工作而言，其目的既在於改善、矯治有社會危險性之犯罪行為人之偏差性格，以預防其再犯，是強制工作本質上應為一種由專業人員主導實施之處遇程序，而非對受處分人之刑事處罰。制度之建構，自應以使受處分人得受有效處遇，俾利其學習技能及協助改善其偏差性格為核心內容，截然不同於犯罪之處罰，始合於憲法之誠命。

(2) 具體而言，如何形成明顯之區隔，應可透過自強制工作之處所（包含空間規劃及設施），施以強制工作之程序、管理及專業人員之配置、參與等不同面向整體觀察，而與刑罰之執行有明顯區

隔，始為憲法所許。

- (3) 就目前現行強制工作之執行相關部分，其對受處分人戒護之規定與監獄行刑法對受刑人戒護之規定類似；對於受處分人得使用戒具或收容於鎮靜室之條件及方法之規定，亦與監獄行刑法對受刑人施用戒具或收容於保護室之規定類似；又受處分人固得與其家屬及親友接見及通信，惟其接見頻率、時間及通信內容均受到管制，與監獄受刑人之接見與通信規定，並無二致，二者對人身自由之限制無實質上之差異。
- (4) 考其實務部分，針對強制工作之受處分人區分男性與女性，集中於同一處所執行，同時該處所亦與其他為數更多之受刑人為伍。又囿於場地與師資不足，強制工作實施處所所能提供之技能訓練課程有限，受處分人於強制工作期間未必均有接受技能訓練之機會，而是與其他受刑人同樣從事短期技能訓練或一般性作業，受處分人於日常包括管理、作業、課程及技能訓練與受刑人並無差別，實務上亦未見專門用以矯正受處分人犯罪習慣之評估與矯正機制，是現行強制工作之執行亦不符憲法明顯區隔原則之要求。

（三）謝如媛老師鑑定意見：

1. 強制工作制度違反人性尊嚴之保障：

- (1) 現今我國受強制工作處分者，其執行方式係依照保安處分執行法第 52 條以下有關強制工作之規定為之，其中第 54 條、54-1 條分別規定「每日應工作六至八小時，而受處分者不能任意停止作業，除非有 54-1 條規定之事由。」此外，受處分人每日工作之勞動成果，並不能由受處分人自行享有，而是透過給予「勞作金」的方式，使其獲得非常微薄的收入，以供自己在受處分場所之日常所需，而該勞作金只能在二分之一的範圍內使用，其於部分必

須交由強制工作處所保管。不僅如此，此作業金尚得扣除作業支出費用、提撥受處分人飲食費用、獎勵費用、犯罪被害人補償費用，實際上之勞作金比例，甚至低於監獄之受刑人。

(2) 公民與政治權利國際公約（下稱公政公約）第 8 條第 3 項規定：

（一）任何人不得使服強迫或強制之勞役；（二）凡犯罪刑罰得科苦役刑之國家，如經管轄法院判處此刑，不得根據第 3 項（一）款規定，而不服苦役；（三）本項所稱「強迫或強制勞役」不包括下列各項：（1）經法院依法命令拘禁之人，或在此種拘禁之附條件釋放期間之人，通常必須擔任而不屬於（二）款範圍之工作或服役。形式上，單依照公政公約之角度而言，似乎只要符合第

（三）款依照法院合法判決之刑罰，自能解釋為有正當理由而對受處分人強制其受勞動。不過實質上尚有待討論之餘地，不能先一概只依照單一國際公約觀察，應整合其他同樣內國內法化之國際法解釋較為妥適。

(3) 因工作權是一項受國際承認的基本權利，故應可從同樣具內國法效力之經濟社會文化權利國際公約（下稱經社文公約）以及我國已批准之廢除強迫勞動公約（下稱 ILO 公約）一併觀察之。經社文公約第六條第 1 項規定：「本公約締約國確認人人有工作之權利，包括人人應有機會憑本人自由選擇或接受之工作謀生之權利，並將採取適當步驟保障之。」就其實際之意義，乃在於將勞動作為刑罰而加以強制進行時，將伴隨著不可避免的痛苦，進而剝奪了人們從勞動可能獲得之意義與喜悅，等於實質上侵害了勞動權利。

(4) 而該經社文委員會於第 35 屆會議中對經社文公約第 6 條工作權之第 18 號一般性意見更具體指出：「工作權是實現其他人權的根本

所在，並構成人的尊嚴的不可分割和固有的一部分。每一個人均有能夠工作，使其生活地有尊嚴的權利。工作權同時有助於個人及其家庭的生存，從能夠自由選擇和接受工作的角度出發，這一權利有助於個人的發展和獲得所在群體的承認。」

(5) 再者，該第 18 號意見中之第 7 點指出強迫勞動之界定，係以個人本身並未自願從事而是在脅迫施以某種懲罰的條件下，受迫所為的工作或勞務，而締約國應致力於廢除、禁止並打擊各種形式的強迫勞動。另外，該號意見中之第 23 點則聲明：「締約國有義務尊重工作權，尤其是透過禁止強迫或強制勞動和避免否定或限制所有人平等取得體面的工作，尤其是不利和被邊緣化的個人和團體，其中包括受刑人或受拘禁人。」

(6) 據此，謝老師認為，勞動之意義應該被解讀為一種權利，係一種能夠使人感受到喜悅並有尊嚴之自我實現的手段，又可稱有尊嚴的勞動，雖然上述之國際法係在針對以強制勞動作為刑罰執行內容的部分，但考其實際意義，對於「強制勞動」本身的質疑甚至是否定，更應適用在以剝奪人身自由為前提的強制工作處分上。雖然強制工作係在強調對於犯罪未來之預防與受處分者之矯治與教育，惟其本身仍無法脫離具有刑事色彩之對人身自由干預的剝奪，其實際處遇上與受刑人相差不遠。又我國已明定「公民與政治權利國際公約及經濟社會文化權利國際公約施行法」（下稱兩公約施行法），此際兩公約具有內國法效力，且批准 ILO 公約，鑑於各種層面之解釋，應可認為透過保安處分剝奪受處分人的身體自由及其他生活上的基本權利，進而以強制勞動為刑事處分的主要內容，恐有損人性尊嚴之虞。

2. 刑法第 90 條規定違反明確性原則：

- (1) 審查標準：因保安處分涉及重大人身自由之剝奪，與刑罰無異，且是否宣告保安處分又仰賴法官個人主觀的判斷，對於該條文之用語自應依採取嚴格審查標準。
 - (2) 如何認定本條所稱之遊蕩或懶惰成習，實與個人與個人間之觀念有差異，涉及主觀上的不同，無法有一客觀標準明定。此外，有犯罪習慣雖可以量的方式觀察，某程度上有客觀性存在，然而當論及「習慣」此種用語時，某程度及意味著具有「傾向和習性」之要素，而此要素亦因人而異，而無法透過法條明確得知之規範，往往於不同法官審酌時，存在質的差異，且與大法官歷來謂「法條是否明確，應以其意義依法條文義及立法目的，如非受規範者難以理解，並可經由司法審查加以確認，即與法律明確性原則無為。」此種對於法律明確性之認定有違背，此應認本條規定不符合法律明確性原則。
3. 強制工作制度違反比例原則：
- (1) 於適當性之審查，需探究系爭條項所使用的手段是否有助於公益目的之達成，而依照司法院歷來解釋，對於強制工作之最終目標係改善、矯治行為人之偏差性格，使其能復歸社會，達到特別預防之目的。其階段性目標則是以透過受處分人能夠習得一技之長、養成勤勉的習慣及正確觀念之謀生觀念，手段則是強制其勞動及參與相關職業訓練。
 - (2) 依照上開見解，謝老師認為應從最終目標以及階段目標兩個面向分別觀察。首先針對階段性目標而言，強制工作之手段係課以受處分人每天六至八小時的工作義務，其外觀上似乎可以養成勤勞的習慣，然而該種勤勞僅僅是一種表徵而已，是在國家權力的行使下才得以展現，實質層面上應探討的是離開封閉的國家權力機

構後，行為人能否繼續維持該種「勤勞」，以及是否有反效果。然而，實際上之效果均未得而知。

- (3) 而觀察現行強制工作之執行層面，受處分人能接受技能訓練的比例有限，所從事最多的就是折蓮花、紙袋、漁網加工、灑掃等基本勞動，該些勞動本身並不需要達到每日天六至八小時甚至持續至少一年半的執行期間學習，甚而可以說是違反前開對於人性尊嚴的檢討，僅係一種虛度時光、浪費人生的折磨，而更遑論與民間資源的結合，使受處分人得到充足的技術教育。現實層面下受處分人其所從事之勞務無法與現實社會接軌，而又得到的勞作金極其微薄，原本就無資力的受處分人連基本的日常生活都無法滿足，必須透過家人支援，此等皆與影響自尊甚鉅。最後，教導正確的謀生觀念，實際上也僅流於條文的空泛宣稱，實際上如何執行不得而知，況且處於自由被剝奪而封閉的環境中，非自願的學習能夠發揮多少成效難以預期。據此，階段性目標的實現顯然相當困難。
- (4) 而最終目標雖係在改善、矯治行為人之偏差性格，然而此種透過強制工作之手段用以達到最終目的，僅不過是一種刻板印象，不堪檢驗。考其犯罪的原因其來自有，無論是有犯罪的習慣、或是因遊蕩或懶惰成習而犯罪，僅係一個犯罪現象表面的觀察。真正應深究者，行為人養成犯罪之過程為何？哪些個人特質與生活環境相互影響塑造出犯罪之結果？倘若忽略前揭複雜性的成因，而冀透過單一強制工作的手段解決犯罪習慣之問題，只能謂係緣木求魚，其成本便係受處分人的人身自由。

4. 強制治療制度違反一事不二罰原則：

- (1) 刑罰與強制工作是否係針對同一行為？雖於前開刑罰與保安處分

認為其係採雙軌制，前者係針對過去犯罪的回應，後者係針對預防未來再犯之措施，似為不同行為。然而，保安處分雖係謂預防未來犯罪之發生，但其仍為刑法上的法律效果，其發動必須以行為人有觸犯刑罰法律的行為顯露於外時，國家刑罰才有介入之際契機。因此科處保安處分，仍然係以本次觸犯刑罰法律之行為為國家刑罰權力判斷的對象，應認與科處刑罰的對象為同一行為。

- (2) 自外觀上而言，強制工作處分實際上之情形與刑罰執行的內容毫無二致，行為人毫無疑義係被剝奪兩次人身自由，且法律執行上也無法期待強制工作可補充刑罰之不足。而如前揭意見所言，蓋因於立法層面、執行層面及實際運作層面皆存在巨大之落差，其與執行刑罰無明顯之差異，此種強制工作之處分實為徒刑的變相延長，當實然面無法達到要求時，而受處分者被剝奪人身自由之情況亦形同刑罰時，不能僅因立法之宣稱不同，即否定二者併科沒有重複處罰的問題。

- (3) 況且，即便我國刑法有規定刑前強制工作，後續可由法院審酌免除處分之繼續執行，或是免除刑之一部或全部執行（刑法第 90 條第 2 項、98 條第 2 項參照），然而此種處分之免除以及刑之免除有賴法官之裁量，二者間未必有相同執行期間，二者間更不是擇一執行的條件關係，並且我國並不採用保安處分執行期間得抵免刑期的規定，因此制度上違反一罪不二罰的問題仍然存在而無法解消，故應認為刑法第 90 條第 1 項強制工作的規定違反一罪不而罰。

伍、社會處遇：緩刑與假釋

一、緩刑²⁹：

（一）條文規定：

1. 刑法第 74 條第 1 項規定：「受二年以下有期徒刑、拘役或罰金之宣告，而有下列情形之一，認以暫不執行為適當者，得宣告二年以上五年以下之緩刑，其期間自裁判確定之日起算：一、未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告者。二、前因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告，執行完畢或赦免後，五年以內未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告者。」
2. 刑法第 74 條第 2 項規定：「緩刑宣告，得斟酌情形，命犯罪行為人為下列各款事項：一、向被害人道歉。二、立悔過書。三、向被害人支付相當數額之財產或非財產上之損害賠償。四、向公庫支付一定之金額。五、向指定之政府機關、政府機構、行政法人、社區或其他符合公益目的之機構或團體，提供四十小時以上二百四十小時以下之義務勞務。六、完成戒癮治療、精神治療、心理輔導或其他適當之處遇措施。七、保護被害人安全之必要命令。八、預防再犯所為之必要命令。」
3. 刑法第 93 條第 1 項規定：「受緩刑之宣告者，除有下列情形之一，應於緩刑期間付保護管束外，得於緩刑期間付保護管束：一、犯第九十一條之一所列之罪者。二、執行第七十四條第二項第五款至第八款所定之事項者。」

（二）緩刑之目的與爭議：

1. 我國早期學者談論緩刑時，主要著重於刑事政策上之意義，認為可以

²⁹ 謝如媛，緩刑的刑事政策意涵：嚴罰趨勢下的寬典？國立臺灣大學法學論叢第 43 卷第 4 期，2014 年 12 月，頁 1609-1664；謝如媛，刑事政策研究成果回顧，刑事法：10. 刑事政策研究成果回顧，法律研究成果回顧與社會影響性 2001-2020，2024 年 11 月（下期），頁 201-202。

避免短期自由刑的弊害，另一方面可以保全犯罪人之廉恥，以促進其悔改向上。亦有學者指出，緩刑可使犯罪者多方檢點，謹慎做人，可達使人改過遷善的積極效果，符合刑期無期的精神。然而，早期亦有反對緩刑者，自應報思想與罪行均衡論出發，並認為緩刑制度因為有罪而暫不宣告、或科罰而不執行，將有害於刑罰的威嚇力，無以撫慰被害人。

2. 由此以觀，反對緩刑制度者，強調有罪必罰之重要性，並從絕對應報刑的觀點要求對犯罪人科處的刑罰與應執行的刑罰必須一致，較重視一般預防的機能。反之，贊成緩刑制度者則著重特別預防機能，要求區分犯罪行為的可罰性與刑罰為人現實上有無處罰必要性，並允許依據犯罪行為以外的事項（如犯後態度）進行個別化刑罰判斷。
3. 然而，謝老師指出，從犯罪預防的角度而言，贊成設立緩刑的主張，雖說含有個別預防考量，但基本上仍著重在緩刑的消極功能，也就是對於欠缺處罰必要性之人，以暫緩刑罰之執行來避免刑罰惡害。若說其中有何積極作用，主要是著重在透過緩刑可能被撤銷的心理壓力，促進犯罪者謹慎行事並在社會環境中改善其身，以防止其在緩刑期間內再度犯罪。我國實務見解發展亦同，認為緩刑與否要考慮的僅單純是有無再犯可能性，以及刑罰之宣告是否即足以使犯罪者警戒而不再犯，看不出有社會內處遇的觀點或有其他積極處遇的連結或期待。

（三）緩刑制度與保護管束：

1. 我國於緩刑制度建立之初，緩刑與犯罪預防的連結，大多僅止於消極的避免刑罰弊害或透過執行可能性加以威嚇，並無太多正面處遇的積極期待。過去學者亦有指出，這與我國保護管束制度不完備有重要關係，往往有合於緩刑條件之案件，卻缺乏執行保護管束之適當機關，導致法院因事實上之困難而不輕易宣告緩刑，更可能導致緩刑成為縱

容犯罪的寬恕措施，使得法官規避此制度之運用。

2. 而依照現行法，我國對於緩刑保護管束，除了刑法第 74 條第 2 項第 5 至 8 款係「應」付保護管束外，其他仍是由法院自由裁量。這點，可說是前述緩刑初期特徵所遺留下來的痕跡。而依照立法理由，由於第 5 至 8 款的執行期間較長，為收其成效，宜配合保安處分之執行，方能發揮效果。由此可知，保護管束在此只是為了監督各種事項的執行。
3. 然而，謝老師指出，這種將保護管束作為一種監督工具加以規定的方式是值得質疑的。蓋因保護管束本身原本預設的是透過觀護人的專業來對行為人進行處遇，具有處遇科學化、處遇個別化的重要意義，即使觀護的資源以及保護管束的發展在我國實質上並不充分，但在法制上，保護管束確實已經成為一種獨立的處遇措施（作為保安處分之一種、作為少年保護處分之一種），然而立法者卻將「保護管束」的實質意義架空，僅強調其監控其他條件執行的工具性的作用，實有檢討、修正的空間。在我國的制度中，可以說保護管束的專業與處遇的內涵，在尚未充分發展時，就已因為立法等各種因素而不斷遭到破壞。

（四）附條件緩刑修正之檢討：

1. 刑法於 2005 年進行修正時，針對第 74 條，擴大了緩刑適用對象；並新增了「附條件緩刑」制度，仿照刑事訴訟法第 253 條之 2 緩起訴應遵守事項之體例，明定法官宣告緩刑時，得斟酌情形，命犯罪行為人向被害人道歉、立悔過書、向被害人支付相當數額、向公庫支付一定之金額、提供 40 小時以上 240 小時以下之義務勞務、完成戒癮治療、精神治療、心理輔導等處遇措施、其他保護被害人安全或預防再犯之必要命令，以相呼應。
2. 謝老師指出，依照當時法務部長的說明，似乎其理由與當初引進緩刑

制度的思考並沒有太大的差異。附條件緩刑制度同樣是為了避免短期自由刑的弊害，希望透過緩刑來促使犯輕罪者改過自新，並兼顧個別預防的精神。不過，有別於初期的說法是，在法務部長的說明中，已明確指出「社區處遇」之方式，並可窺見「減少超收」應該是此次修法最主要的背景。從政策制定者的角度來看，附條件緩刑的相關修訂，主要目的還是出於減少監獄超收，並避免短期自由刑的弊病。其方法是藉由多樣化的條件，一方面鼓勵法官選擇所附條件，不會因為顧慮到緩刑有太「輕縱」犯罪者之虞，進而充分運用緩刑制度；另一方面又可以顧及公益、教化、被害人保護等目前社會重視的問題，一舉數得，何樂而不為。

3. 然而，謝老師認為，上述政策制定的思考，也正是附條件緩刑制度最值得重新檢討之處。一方面，緩刑既是為了避免刑罰之弊害，並且施以不必要的刑罰，則即使按照修法前之規定而作成單純的緩刑決定，或僅付保護管束，又何來「輕縱」之說？而透過義務勞務來教化犯罪者、要求犯罪者接受適當的治療、向被害人道歉或加以賠償等，即使該措施本身有其意義，但是否適合作為緩刑的附帶條件，並且在該些條件未履行時進而作為得撤銷緩刑的理由？與緩刑制度設立之初相較，現行法中如此富有彈性的附條件緩刑制度，在更廣闊的刑事政策視野中，應如何加以定位？對於犯罪控制的真正作用何在？均非無疑問。

4. 包山包海的「預防再犯所為之必要命令」：

- (1) 第 74 條第 2 項第 8 款「預防再犯所為之必要命令」，有規定不夠明確、過於概括之問題，因此學者也指出，本款在適用上必須謹守緩刑的目的，並且遵守比例原則、維護受刑人的尊嚴。而針對這條款命令事項，實務上曾經出現過各式各樣的內容，包括「接受觀護

人定期輔導、接受認知、法治教育課程、抄寫法條、立法理由或宣導文宣若干次、針對犯行之違法性、危害性閱讀指定教材後撰寫若干字以上心得、閱讀觀護人指定有益身心靈書籍或影片並繳交一定字數之報告、協助參與地檢署舉辦之反賄選、反毒宣導活動一定場次、於網站或部落格張貼觸法之經過作為法治宣導之真實教材」等。甚至，有檢察官除了在緩起訴時用刑事訴訟法第 253 條之 2 第 1 項第 8 款（內容與本款相同）命被告抄寫靜思語、聖經或論語外，也有地檢署建請法院將上述抄寫作業作為緩刑所附條件之內容。

- (2) 謝老師指出，姑且不論有些內容可能涉及侵害宗教自由與思想自由的問題，上述這些內容看似非常有彈性，似乎可以根據犯罪者的情況給予個別的最適當的處理，但如果仔細思考裡面所呈現的對犯罪者及其處遇的觀點，會發現包含許多懲罰要素，且反映出司法者對受執行者的成見。例如，要求抄寫法條或立法理由或宣導文宣若干次，其意義在哪裡？若是一個有完全責任能力的行為人，照理說，經過偵查審判程序，還被判有罪，很難想像他還會需要在刑罰的威嚇底下反覆抄寫法條、立法理由或宣導文宣才能理解行為錯在哪裡（何況法官自己都說經此偵審程序，應知所教訓，而無再犯之虞）？一方面，這樣的作法是否會有「教育效果」？從既有的研究成果來看，實須進一步加以檢討；另一方面，罰寫罰抄的方式，與其說是為了透過「教育」方式來達到避免再犯的目的，不如說其本身就是一種懲罰。又如，在網站或部落格張貼觸法之經過以作為法治宣導之真實教材，不知實際上進行的方式為何？有沒有「遊街示眾」的意義或期待發生此種效果？抄寫宗教書籍或論語的目的何在？是要行為人好好修身養性以避免犯罪？反過來說，也就是法院認為被

告犯罪的原因在於修養不好？這些附條件緩刑的內容真的有助於犯罪者的更生？或是有其他真正的目的？有無違背社會內處遇的目的與原則？其實是相當有疑問的。

5. 附條件緩刑的異化：

- (1) 謝老師據此指出，在我國緩刑制度創立之始，原本並沒有一定要付保護管束的規定，而是交由法官裁量（得付保護管束）。這是因為緩刑對象之中有些犯罪行為人並不需要接受任何刑罰的執行就可以復歸社會。時至今日，不僅原本作為社會內處遇與處遇個別化的重要手段與象徵的保護管束，反而變成為了確保（監視）所附條件有被確實履行的工具，讓原本人力物力已嚴重不足的觀護官淪為單純的監視者，等於是把保護管束的個案工作精神破壞殆盡，更不用提不付保護管束也沒有附條件的單純緩刑判決，彷彿是有勇氣的法官才能作的有勇氣的判決、或沒有明顯來自被害人或社會壓力下才能做成的判決，單純緩刑似乎已經成為例外。
- (2) 實際上，緩刑所附的條件，若不能積極發揮協助被告復歸社會的作用（例如透過義務勞務增進被告工作技能或增加就職機會），至少要能確保行為人有履行之可能，更應避免影響其日常生活，以免本末倒置，使行為人為了履行所附條件而疲於奔命，反而使其日常生活無法安定，也沒有餘力改善再犯因素。例如因為經濟極為困窘而犯罪的行為人，若必須履行過於漫長或過於頻繁的義務勞務，若無助於其改善基本生活，反而會提高其復歸社會的難度，並徒然增加緩刑被撤銷的機率。則此種過長或過於頻繁的義務勞務的賦科，恐怕只是反映了我們對處罰的依賴，只是這個處罰的形式從監禁換成身體勞動甚至某些屈辱的義務，並且以刑罰之執行可能性來作為恐嚇其履行的手段。

- (3) 緩刑制度原本應該是以認識到國家刑罰權力的極限為出發點，透過緩刑制度來進行刑罰的節制而避免濫用。然而，附條件緩刑制度的運用，卻逐漸與此前提以及該制度的目的產生微妙的差異；一方面，將「避免刑罰弊害」限縮到形式上「入監」與否，彷彿只要不進監獄就不會產生刑罰的負面效應，而不考慮國家強制力的行使本身應該就是要小心控制的對象；另一方面，則對緩刑這個節制刑罰的手段賦予一個新的目的，就是改造犯罪人。這一點，不僅使向來法官的角色發生改變，從因應行為人的罪責決定適當刑罰，轉變成選擇適當的負擔或指示來改善行為人，成為一個人性工程師。
- (4) 在附條件緩刑制度當中，法官的裁量空間極為擴大，即使有些法官將執行的實際內容交由檢察官來決定（例如決定義務勞務的內容或地點），但這種執行層面的問題卻不影響這個規定本身的性質，且不可否認的是法官也有可能自行決定這些類似刑罰的內容，並且除了所謂量刑的內在限制或比例原則等抽象的原則之外，並沒有關於各個條件的適用標準或具體限制。在這裡，問題並不只是法官能不能適當裁量的疑慮而已，而是緩刑的各式條件已承載了眾多目標，卻又欠缺發動刑事制裁應有的具體標準或規範，該制度恐怕已成為超越緩刑本體的變形獸。

（五）對我國緩刑制度的省思與建議：

1. 如前所述，緩刑制度基本的出發點是希望能夠節制刑罰的使用，對於不須處以刑罰者即應避免發動刑罰，使犯罪人不至於因刑罰之副作用而難以復歸社會，甚至波及整個家庭。精確的來說，緩刑不能夠被認為是一種寬典或對被告的輕縱，而是在認清刑罰的本質與侷限之下，提升刑罰之合理性的一種制度，也是對「有罪必罰」的絕對應報刑論的一種反省。

2. 然而在緩刑實務上，所謂的略施薄懲，似乎已成為法官的魔咒，即使在緩刑這種刑罰的節制措施裡，都還要透過所附的條件加以懲罰、要被告付出代價，深恐人民會（僅）因為欠缺刑罰的制裁而再犯。在這樣的心態裡，所謂的刑罰是必要之「惡」的看法，實質上對於我國刑事政策的制定與司法實務的運作未必有太大影響，相反地，無論犯罪輕重，「以處罰為原則」可能比較接近現實狀況。這恐怕也因為緩刑向來容易被視為是一種「恩惠」，因此，附加各種條件（即使性質等同處罰）也是理所當然，甚至認為這樣也還「便宜了」被告。而被告在可以避免刑罰之執行的情況下，也很少會對附條件的緩刑判決有何怨言，使得附條件緩刑的運用很少遭遇什麼困難。且依照統計資料，緩刑整體的比例並未增加，但附條件緩刑的運用卻增加了。也就是說，刑罰權力的運用並未減少，反而在擴張。
3. 綜合來看，在思考自由刑的替代措施或所謂社會內處遇時，在我國的主要出發點其實都來自於監獄超收極度嚴重，這些提案主要為了解決這個迫在眉睫的問題，至於刑罰的節制或所謂社會內處遇的功效，比較像是一個工具，便於用來合理化上述的立法提案。在這種情況下，附條件緩刑這種好像可用來減少監禁人口的措施，看似美好，但在不予輕縱、有罪必罰或期待刑罰發揮多重功能的心態下，附條件緩刑是否真的能夠達到刑罰節制或社會內處遇的目的，恐怕一開始就埋下了自相矛盾的種子。
4. 緩刑的基本出發點，乃是避免刑罰的避害，讓沒有必要受到刑罰制裁的犯罪人得以緩免。而所謂的刑罰，並不是只有監所收容才叫刑罰，所有以國家強制力為手段而賦予犯罪人痛苦的制裁，都必須要戒慎使用。而謝老師認為，在附條件緩刑的領域裡，刑罰目的不明確的問題變得更明顯。現行刑法緩刑的多樣化指示或負擔，往往容易賦予過多

的期待，希望藉由這些措施積極地矯正犯罪人，甚至不惜透過以刑罰強制力作後盾以要求犯罪人賠償或道歉的方式，來達到保護被害人的目的。但如此一來，將忽略了緩刑的基本出發點，也就是回避刑罰的避害，而是想積極地其透過該負擔或指示來改造或監控犯罪人，達成多重目標，包括保護被害人利益、防衛社會（保安處分之戒癮治療等）、充實國庫（對犯罪人而言，被宣告罰金刑跟被緩刑但須向國庫支付一定金額，相同的都是金錢的制裁，不同的是或許司法人員及被告心理上會認為後者是讓被告逃脫「正式制裁」的一個「寬大處置」）、甚至第 74 條第 2 項第 8 款的概括條款可能有包山包海之虞。附條件緩刑甚至模糊了刑罰與道德教育、刑罰與保安處分的界限，但在我國受到的檢視卻不夠充分。

5. 就附條件緩刑來說，並不能僅因為它不是機構內的監禁就當然可以正當化，而必須整體判斷它實際上有無符合上述要求，或者是作為一種附加的、變相的懲罰，反而擴充了國家制裁的權力，而與非刑罰化的目標背道而馳。更何況我國在犯罪化、重罰化方面向來很積極，在非犯罪化或減輕法定刑方面卻異常消極，徒然在緩刑制度上引進各種類似中間制裁的措施，對於其適用目的欠缺充分的共識，又未能有明確的標準，使得個個制度很難真正地取代或減少監禁，也未必真能發揮社會內處遇的功能。
6. 如何避免緩刑制度反而成為監獄人口增加的因素，或是成為刑罰權力擴充的管道，必須從更整體的刑事政策角度來探討，確實掌握犯罪現象與政策執行狀況，並且回到制度初衷——緩刑是為了節制刑罰、透過社區處遇給與復歸社會的支援；更需建立明確的緩刑附條件的原則、細緻的標準與限制，避免緩刑相關制度成為 Cohen 所說的——用來取代監禁的各項措施往往猶如特洛伊的木馬——不僅無助於改善刑罰的運

用，反而帶來無法收拾的弊害。

【試題演練】

我國於 2005 年修正緩刑制度時，參考刑事訴訟法第 253 條之 2，明定法官宣告緩刑時，得斟酌情形，命犯罪行為人向被害人為一定之行為，並稱為「附條件緩刑制度」。依照當時修法理由，乃係為減少監獄超收，並避免短期自由刑的弊病，兼具有避免輕縱犯罪者及教育犯罪者之益處。試依現今附條件緩刑制度之運作結果評析之？（30%）

自擬

【擬答】

一、依照現行制度運作結果，附條件緩刑制度不禁無從達成「避免輕縱」、「教育」等目的，更可能導致刑罰權不當擴張：

（一）修正前的緩刑制度並無「輕縱」行為人之疑慮：

緩刑制度的出現，本旨是為了限縮刑罰權限，避免刑罰權過度擴張，進而防止國家施以不必要的刑罰。則由此以觀，緩刑制度的出現，並不是刻意的縱放犯罪者；相反的，是在減少國家不當刑罰權的實施。則由此以觀，縱使於 2005 年修法前並未有附條件緩刑制度，亦不會有過於輕縱犯罪者之疑慮。

（二）附條件緩刑制度，難以達成教育目的，反而可能過度擴張刑罰權限：

1. 依照現行制度，法官於宣告緩刑時，得參酌刑法第 74 條第 2 項規定，要求行為人負擔一定之行為義務。然而，若依照實務運作可知，該等條件中，實包含許多懲罰要素，且反映出司法者對受執行者的成見（例如要求抄寫法條或立法理由或宣導文宣若干次）。而此類條件，究竟能否達成「教育效果」，亦非無疑。以前開抄寫法條為例，此種做法對於已經經過偵查、起訴、法官告誡並宣告緩刑之行為人而言，顯然無太大

意義，遑論「教育」行為人不要再犯，甚至協助其復歸社會。這樣的作法，與其說是為了透過「教育」方式來達到避免再犯的目的，不如說其本身就是一種懲罰。

2. 由此可知，緩刑制度原本應該是以認識到國家刑罰權力的極限為出發點，透過緩刑制度來進行刑罰的節制而避免濫用；然而，附條件緩刑制度的運用，卻逐漸與此前提以及該制度的目的產生微妙的差異，不僅將「避免刑罰弊害」限縮到形式上「入監」與否，更賦予法官極大的裁量權限，對於行為人施以許多未必能達成緩刑制度本旨的手段。如此的運作下，附條件緩刑甚至被視為一種對行為人的「恩惠」，卻忽略了國家在此是否構成國家刑罰權力過度擴張的疑慮。

二、而於刑事政策之面向上，針對我國附條件緩刑制度，應回歸至節制刑罰、透過社區處遇給與復歸社會支援之制度本旨出發，並需建立明確的緩刑附條件的原則、細緻的標準與限制，以免該制度與原先設立緩刑所欲達到的非刑罰化目的背道而馳。

二、假釋³⁰：

（一）釋字第 796 號解釋：

1. 爭點：刑法第 78 條第 1 項本文規定，受假釋人於假釋中因故意更犯罪，受有期徒刑以上刑之宣告者，均一律撤銷其假釋，是否牴觸憲法第 23 條比例原則？
2. 解釋文：刑法第 78 條第 1 項本文規定：「假釋中因故意更犯罪，受有期徒刑以上刑之宣告者，於判決確定後 6 月以內，撤銷其假釋。」不

³⁰ 李茂生，從大寮監獄事件談獄政改革的未來，月旦法學教室第 154 期，2015 年 7 月，頁 61-67；柯耀程，似比例非比例—憲法法庭 113 年度憲判字第 2 號判決評釋，月旦裁判時報第 147 期，2024 年 9 月，頁 32-39；謝如媛、林俊儒，多元復合的假釋制度——美國假釋制度的考察與反思，政大法學評論第 170 期，2022 年 9 月，頁 1-53；謝如媛，刑事政策研究成果回顧，刑事法：10. 刑事政策研究成果回顧，法律研究成果回顧與社會影響性 2001-2020，2024 年 11 月（下期），頁 202-204。

分受假釋人是否受緩刑或 6 月以下有期徒刑之宣告，以及有無基於特別預防考量，使其再入監執行殘刑之必要之具體情狀，僅因該更犯罪受有期徒刑以上刑之宣告，即一律撤銷其假釋，致受緩刑或 6 月以下有期徒刑宣告且無特別預防考量必要之個案受假釋人，均再入監執行殘刑，於此範圍內，其所採取之手段，就目的之達成言，尚非必要，牴觸憲法第 23 條比例原則，與憲法第 8 條保障人身自由之意旨有違，應自本解釋公布之日起失其效力。

3. 解釋理由（節錄）：

- (1) 查監獄行刑，乃國家對於犯罪人執行刑罰之主要方式之一，監獄行刑除公正應報及一般預防目的外，主要在於矯正、教化受刑人，促使受刑人改悔向上，培養其適應社會生活之能力，協助其復歸社會生活。假釋之目的亦在於鼓勵受刑人改過自新，給予已適於社會生活之受刑人提前出獄，重返自由社會，以利其更生。是不論在監執行徒刑或假釋，均在協助受刑人得以重返自由社會。假釋僅係使受刑人由完全受監禁之監獄環境，邁入完全自由釋放之過程中，於符合一定條件，並受保護管束之公權力監督下，提前釋放之緩衝制度，亦即於刑罰執行過程中，由機構處遇轉為社會處遇之轉向機制。因此，法律乃規定於在監執行期間，如受刑人不適合提前回歸社會，則不予假釋，繼續在監執行，以實現國家刑罰權。於轉為社會處遇之假釋期間，如受假釋人有不適合回歸社會之事實發生者，則撤銷假釋使受假釋人回復至監獄之機構處遇。
- (2) 系爭規定之目的，在於使不適合社會處遇之受假釋人，回復至監獄之機構處遇，執行國家刑罰權，其固係為保護合乎憲法價值之特定重要法益。然受刑人是否適合假釋，使其提前出獄，回歸社會，本應參酌受刑人之犯行情節、在監行狀、犯罪紀錄、教化矯治處遇成

效、更生計畫及其他有關事項，綜合判斷其悔悟情形（監獄行刑法第 116 條第 1 項及受刑人假釋實施辦法第 3 條參照）。一旦准予假釋，表示受假釋人適宜在保護管束之公權力監督下，提前出獄重返社會。因此，受假釋人於假釋中因故意更犯罪，受有期徒刑以上刑之宣告者，是否撤銷其假釋，使其回復至監獄之機構處遇，自應依其是否仍適合社會生活，亦即是否已違背假釋之初衷而為判斷，方能平衡撤銷假釋目的與受假釋人之人身自由保障。於受假釋人故意更犯之罪係受緩刑或 6 月以下有期徒刑宣告之情形，就該更犯罪，或暫不執行，或得易科罰金或易服社會勞動（刑法第 41 條及第 74 條第 1 項參照），則是否應變更原受之社會處遇，改為入監執行之機構處遇，自應再個案審酌有無基於特別預防考量，而有必要使該受假釋人再入監執行殘刑之具體情狀（例如對社會危害程度、再犯可能性及悔悟情形等），不應僅因該更犯罪受有期徒刑以上刑之宣告，即一律撤銷其假釋，致受緩刑或 6 月以下有期徒刑宣告且無特別預防考量必要之個案，均再入監執行殘刑。

（二）現行規範：

1. 刑法第 77 條第 1 項：「受徒刑之執行而有悔悟實據者，無期徒刑逾二十五年，有期徒刑逾二分之一、累犯逾三分之二，由監獄報請法務部，得許假釋出獄。」
2. 刑法第 77 條第 2 項第 2 款：「前項關於有期徒刑假釋之規定，於下列情形，不適用之：二、犯最輕本刑五年以上有期徒刑之罪之累犯，於假釋期間，受徒刑之執行完畢，或一部之執行而赦免後，五年以內故意再犯最輕本刑為五年以上有期徒刑之罪者。」（三振條款）
3. 刑法第 78 條第 1、第 2 項規定：「假釋中因故意更犯罪，受逾六月有期徒刑之宣告確定者，撤銷其假釋。（第一項）假釋中因故意更犯罪，

受緩刑或六月以下有期徒刑之宣告確定，而有再入監執行刑罰之必要者，得撤銷其假釋。(第二項)」

4. 第 79 條之 1 第 5 項：「經撤銷假釋執行殘餘刑期者，無期徒刑於執行滿二十五年，有期徒刑於全部執行完畢後，再接續執行他刑，第一項有關合併計算執行期間之規定不適用之。」
5. 監獄行刑法第 18 條第 1 項本文規定：「對於刑期六月以上之受刑人，為促使其悔改向上，培養其適應社會生活之能力，其處遇應分為數個階段，以累進方法為之。」、第 115 條第 1 項規定：「監獄對於受刑人符合假釋要件者，應提報其假釋審查會決議後，報請法務部審查。」、第 116 條第 1 項規定：「假釋審查應參酌受刑人之犯行情節、在監行狀、犯罪紀錄、教化矯治處遇成效、更生計畫及其他有關事項，綜合判斷其悛悔情形。」、第 118 條規定：「法務部參酌監獄依第一百五條第一項陳報假釋之決議，應為許可假釋或不予許可假釋之處分；如認原決議所載理由或所憑資料未臻完備，得通知監獄再行補正，其不能補正者，得予退回。(第一項) 經法務部不予許可假釋之處分案，除進級者外，監獄應逾四月始得再行陳報。但該受刑人嗣後獲第八十四條第一項第五款至第七款所列之獎勵者，監獄得提前一個月陳報。(第二項)」
6. 行刑累進處遇條例第 75 條規定：「第一級受刑人合於法定假釋之規定者，應速報請假釋。」
7. 行刑處遇條例施行細則第 57 條規定：「依本條例第七十五條及七十六條之規定為受刑人辦理假釋時，一般受刑人最近三個月內教化、作業、操行各項分數，均應在三分以上，少年受刑人最近三個月內教化分數應在四分以上，操行分數在三分以上，作業分數應在二分以上。」

（三）假釋制度之反思：

1. 制度的前提：裁量假釋與法定假釋

（1）裁量假釋：

- A. 假釋起初被理解為透過裁量機制選擇適合假釋的受刑人，提早釋放並予以監督與支援的制度，同時藉此排除不適合提早釋放的受刑人，達到促進公眾安全及復歸社會的目的，故被稱為「裁量假釋」。
- B. 在美國，1970 年代以前指的假釋都是「裁量假釋」，具體內容為立法者先制定寬廣的量刑空間，且制定足夠長的刑期以便徹底改善犯罪人；法官判決較長的刑期作為上限，而沒有最低執行期間的要求，使矯正人員能夠擁有充分的時間及彈性來督促受刑人更生、復歸社會。而假釋審查委員會只受到法官判決之最長刑期拘束，並沒有假釋形式門檻的要求。這也意味著，實質上最終是由假釋委員會在此範圍內判斷受刑人是否改過遷善，以及何時釋放。在 20 世紀，社會復歸理念是矯正體制極為重要的刑罰哲學，而裁量假釋與相對不定期刑的結合制度，被當作體現此理念的重要工具。
- C. 然而，這樣的思潮在 1970 年代有明顯轉變，社會復歸理念的正當性開始受到質疑，裁量假釋也因此受到批評，包括：沒有證據顯示假釋能有效減少再犯、裁量假釋與相對不定期刑不公平且不人道、與相對不定期刑的結合讓假釋審查委員會等機關擁有過廣的裁量權，且裁量權往往不一致或有差別對待。也因此，美國各地開始廢除或減少裁量假釋之運用。

（2）法定假釋：

- A. 隨著裁量假釋的衰退，法定假釋盛行一時。一方面因應著嚴罰

化的要求，立法者縮減了裁量空間，以避免受到寬縱受刑人的批評；另一方面，對應著正當應報的理念，透過立法或量刑準則的規範具體反映在法官判決的刑度上，並且同時減少行政機關的裁量空間，使受刑人釋放時點明確化。

- B. 裁量假釋制度強調對受刑人改善程度及再犯危險等要素的審查，尤其在裁量空間極為寬廣的情況下，法官在判決時無法預測假釋時點。相較於此，法定假釋原則上在判決時即可確定受刑人的假釋時點，有著明確或至少可以在裁判之際即可計算出的服刑時間。美國自 1975 年緬因州廢除第一個裁量假釋後，各州陸續跟進，聯邦也接著正式廢除，並多改採法定假釋制度。

(3) 多重制度的併用

- A. 雖然法定假釋逐漸成為主流，但實際上，裁量假釋仍然以各種不同方式存在。舉例而言，有些州對於特定犯罪仍保留裁量假釋空間，或保留假釋審查委員會，以便決定法定監督事項，並在違反事項時撤銷假釋。謝老師及林老師指出，依照美國的發展，沒有任何單一模式取代了假釋。相反的，為了填補裁量假釋所能發揮的彈性釋放功能，有更多樣化的提早釋放模式被採用，裁量假釋與法定假釋可以在不同矯正功能及刑事政策目的下，根據不同罪名及行刑階段需求來與量刑制度配合，在釋放受刑人方面產生不同的政策組合。據此，裁量假釋與法定假釋並非二擇一的對立關係，而是多元併生的互動關係。

- B. 而在 2008 年後，美國採取法定假釋的佔比明顯下滑，相較於 1970 年代法定假釋的熱潮，法定假釋逐漸呈現衰退趨勢。批評者認為，法定假釋欠缺彈性釋放功能，刑之執行也偏離了個別化處遇理念。同時，再犯可能性高的受刑人，只要時間到了亦

可提早離開機構，也使假釋失去守門員的功能，無法確保公眾安全。這可能導致法官在量刑時先預設假釋時點而加重判刑，反而可能帶來不公平。在法定假釋受到批評的同時，廢除或減少運用裁量假釋的狀況也有所變化，2002 年至 2017 年間，全美並沒有假釋委員會再遭到廢除。重塑裁量假釋的主張開始出現，認為應改革現有假釋制度，包括假釋審查標準明確化、提供充足的假釋評估素材與審閱時間、準備良好的評估工具、尊重受刑人表意權，以及確保正當法律程序等，以有助於落實個別化處遇的精神。歷經裁量假釋與法定假釋的變遷，當代美國假釋制度呈現多元複合的面貌。

2. 臺灣假釋制度的省思及其建議：

(1) 於我國，假釋的准許與否，除法定要件外，尚需加上後悔實據的實質要件，並由假釋審查機關針對個案狀況加以審酌。由於審查機關對於實質要件的個別審查判斷有一定的裁量空間，因此，我國的假釋應該屬於「裁量假釋」。然而，自 2005 年推動寬嚴並進的刑事政策以來，我國假釋門檻不斷提高，不僅無期徒刑需要服刑滿 25 年才能假釋，更設立三犯不得假釋條款（三振條款），大幅限縮假釋審查之裁量空間。謝老師及林老師指出，此制度的運作結果，其實與美國所主張之法定假釋目標相當接近。

(2) 而長久以來，臺灣假釋制度時常受到批評，學者認為裁量假釋難以客觀化，容易有恣意空間，再加上其與累進處遇制度結合，使得假釋成為監獄賜予受刑人的恩典，用以確保受刑人順從。在輿情不安時，這樣的架構容易使矯正人員採取封閉態度，並反映在假釋審查結果的模糊及審查結果嚴格化，以盡量延後出獄時點，避免受刑人於假釋期間再犯，同時避免矯正無效的批評。於此脈絡下，學者有

提出法定假釋之倡議，認為應廢除累進處遇制度並以比較明確之善時制度取代，受刑人只要不犯錯，按行刑階段進展即可縮短固定刑期，可以讓受刑人明確知悉獲釋時點而及早準備，減少裁量恣意空間。

- (3) 然而，這樣的選擇可能伴隨許多風險，包括無法提供個案裁量空間（也就是經由選出最佳出獄時間以避免繼續施予受刑人不必要的刑罰，同時也難以篩選出再犯風險高者，透過延後其假釋時間來提升教化成效）。同時，於實質作用方面，受刑人也將失去積極參與處遇計劃之動機，矯正人員減少了管理監獄秩序的工具，法官甚至可能考量法定假釋時點而普遍提高量刑。
- (4) 對此，謝老師及林老師指出，裁量假釋與法定假釋始終並非二者擇一的關係；面對我國的困境，應探討能否透過裁量假釋及法定假釋的組合，考量多元矯正功能之達成，以強化受刑人回歸社會生活的能量。具體來說，裁量假釋在肩負起調整不必要刑罰之同時，也可以對個案狀況及其風險把關；而法定假釋則確保受刑人原則上皆有假釋機會，並可以預期明確的釋放時點，藉此敦促資源與協助及早到位。據此，我國假釋制度的調整，或可將法定假釋與裁量假釋分別適用於不同對象，亦即區分一般有期徒刑類型與其他較為嚴重的犯罪類型（包括：無期徒刑、一般累犯、累犯不得假釋類型），分別因應其特性而適用法定假釋與裁量假釋。其次，在要件上放寬無期徒刑、一般累犯的假釋門檻，並廢除三振法案，給予三犯之累犯假釋的機會。
- (5) 謝老師及林老師並強調，初步構想為：針對無期徒刑，應參酌假釋門檻合理上限為 15 年適度調降，並降低累犯假釋門檻，廢除不得假釋之規定，給予裁量假釋之機會。如此一來，一般有期徒刑類型

因為適用法定假釋之既有門檻（有期徒刑逾二分之一），原則上會比現有裁量假釋更能確保假釋機會與充分的假釋空間。另一方面，修改現行法下過苛甚至剝奪假釋機會的嚴重類型，給予假釋機會及裁量空間，確保社區處遇銜接機構內處遇的效果，並可充分考慮個案處遇情況，以使假釋審查委員會儘早觀察該受刑人的處遇表現與個案風險，促進矯正成效與鼓勵更生復歸，避免執行不必要之刑罰，以確保受刑人在監時仍能對於復歸社會保持想望。此外，並應將假釋資格從累進處遇脫鉤，使受刑人與相關矯正人員能更明確預期釋放時點，提早進行社區處遇所需的各項準備，以藉由在監處遇與社區處遇的結合來落實社會再統合理念。

3. 李茂生老師亦指出，我國假釋制度的真正問題點，在於此一制度仍然陳舊的與累進處遇制度環環相扣。假釋本來是設計成給予受刑人一線生機的制度，但到了我國卻成了旋渦，一步步將受刑人吸入滅頂的深淵。究其原因，不外是矯正當假釋制度當成介護手段，將已經沒有多少國家採用的累進處遇制度與假釋制度綁在一起，於入監的時候，即將受刑人作為人的基本需求予以剝奪，然後視其從順的程度逐漸恢復生活基本條件，最後還用恩准釋放的誘餌確保受刑人持續從順。在這種沒有尊嚴的待遇下，這樣的假釋制度只會使的受刑人花更多時間，以卑微身分待在監獄內，等到可以出獄時，又因為社會資源與聯繫都斷絕，而無法合法的生存，於是再度犯罪。

（四）113 憲判 2：

1. 主文（節錄）：刑法第 79 條之 1 第 5 項，規定無期徒刑假釋經撤銷者，一律執行固定殘餘刑期滿 20 年或 25 年，而不分撤銷假釋之原因係另犯罪或違反保安處分執行法之規定，復未區別另犯罪之情節暨所犯之罪應執行之刑之輕重，以及假釋期間更生計畫執行之成效等因

素，以分定不同之殘餘刑期，於此範圍內，不符比例原則，違反憲法第 8 條保障人身自由之意旨，至遲於本判決宣示之日起屆滿 2 年時，失其效力。

2. 理由書（節錄）：

(1) 監獄行刑，乃國家對於犯罪人執行刑罰之主要方式之一，監獄行刑除公正應報及一般預防目的外，主要在於矯正、教化受刑人，促使受刑人改悔向上，培養其適應社會生活之能力，協助其復歸社會生活（監獄行刑法第 1 條立法說明參照）。假釋之目的亦在於鼓勵受刑人改過自新，讓已適於社會生活之受刑人提前出獄，重返自由社會，以利其更生。是不論在監執行徒刑或假釋，其目的均在協助受刑人得以重返自由社會。

(2) 基此，如受刑人在監獄內執行已達相當期間而抵償相當程度之罪責後，悛悔有據而已適於社會生活，則得於合乎一定條件下予以假釋，可期待藉由此機構處遇轉為社會處遇之轉向機制，以協助其重返自由社會，利其更生，並避免人身自由之不必要剝奪。反之，如於轉為社會處遇之假釋期間，受假釋人有不適合回歸社會之事實發生者，則依法撤銷假釋，使其再入監執行殘餘刑期，以將不適合回歸社會之受假釋人回復至監獄之機構處遇，實現國家刑罰權。

(3) 按 86 年及 94 年修正刑法第 77 條同時修正刑法第 79 條之 1 第 5 項，乃立法者鑑於經假釋出獄者再犯之比率增加，為期適當發揮監獄教化功能，確實矯正受刑人，以及防衛社會安全之目的，而認為有整體檢視並修正包括許可假釋之條件、假釋期間、撤銷假釋與殘餘刑期等假釋相關規範之必要。又為防範曾犯重大犯罪而被處無期徒刑者於假釋期間再犯重大刑案，其首要之務應為嚴謹假釋要件，如有再犯之風險者，即不應輕易准其假釋，故於 86 年及 94 年修法

提高無期徒刑得假釋之服刑期間，尚屬合理；再立法者同時配合修正系爭規定一及三，使無期徒刑經撤銷假釋執行殘餘刑期得有明確標準，依系爭規定一於執行滿 20 年始得接續執行他刑，依系爭規定三於執行滿 25 年始得接續執行他刑，且均不適用刑法第 79 條之 1 第 1 項有關合併計算執行期間之規定，仍係為達成上揭矯治教化受刑人、防止再犯罪並防衛社會安全之重要公益目的，尚屬正當。

- (4) 刑罰既然係基於上述應報及特別預防、一般預防之目的所課處之不利處遇措施，則無論刑罰之宣告或執行，均應在達成刑罰目的之必要範圍為之；即使受刑人已受特定刑度之徒刑宣告，然倘於嗣後依據其執行情形、行狀等節，認為目前已執行之刑罰業已足以評價其所應負擔之罪責程度，且從促使其悔改更生之特別預防觀點，認為已無繼續執行自由刑之必要者，本即應停止以機構處遇之方式執行該刑罰，而易以更為和緩之處遇措施。
- (5) 假釋制度之主要目的，為藉由停止繼續在監所執行徒刑，並配合保護管束之監督、輔導機制，使已在監執行相當時日之受刑人得順利適應外部社會生活，以期受刑人真正復歸社會並預防再犯，其相對於在監所內執行之機構性處遇，為一種對受刑人行動自由等各項權利限制較為緩和之社會性處遇措施。因此，假釋中因故意更犯罪或違背保安處分執行法第 74 條之 2 規定而遭撤銷假釋者，基於前述刑罰之執行仍應具備達成刑罰目的之必要性原則，自應根據撤銷假釋當時之一切情狀，評估受刑人更生改善可能性，進而據以於假釋獲釋時所餘宣告刑之範圍內預測達成特別預防目的所需之時間，以算得其殘餘刑期。
- (6) 受無期徒刑宣告者，依刑法第 77 條於 94 年修改前後規定，於執行逾 15 年（累犯 20 年）或 25 年之後可獲得假釋。假釋審查應參酌

受刑人之犯行情節、在監行狀、犯罪紀錄、教化矯治處遇成效、更生計畫及其他有關事項，綜合判斷其後悔情形（監獄行刑法第 116 條第 1 項規定參照），故無期徒刑之受刑人於受許可假釋時，業經執行機關依法審查（監獄行刑法第 116 條至第 119 條規定參照），認為無論係從應報或特別預防之刑罰目的，均已透過一定期間之在監執行而獲得部分之實現。是以，無期徒刑之假釋遭撤銷時，其殘餘刑期期間之計算應使受刑人有機會依當時之一切情狀，受重新評估其應於監獄內完成矯正所需之時間，而非不分情節輕重程度，均須一律於監獄內執行固定之殘餘刑期。

- (7) 系爭規定一及三規定無期徒刑經撤銷假釋後執行殘餘刑期，其性質是接續執行前已受宣告之無期徒刑，以求刑罰目的之全部實現，固然此時受刑人因故意更犯罪或違反保護管束應遵守事項，而認有人監執行之必要。惟按保護管束之性質，係對於犯罪者或虞犯之社會性處遇措施，協助受保護管束之人在保護管束期間由專人負責監督、矯治與輔導，以期確實反省自新，並早日適應社會生活，其性質上屬於為達成上述保護管束目的，所進行之管制、監督、輔導措施。假釋受刑人單純違反上開保護管束應遵守事項，縱使可能影響對其更生可能性、再犯危險性之評價，惟其情節仍與直接侵害他人法益、破壞社會秩序之犯罪行為迥然有別，不應與假釋中故意更犯罪之行為同視。從而，撤銷假釋係因受刑人故意更犯罪，抑或因違反保護管束應遵守事項，其情節嚴重程度本不能相提並論，就其撤銷後之效果即殘餘刑期之執行，亦有必要分別不同程度之處理，始屬相當。
- (8) 又即使同屬故意更犯他罪，其具體個案之犯罪情節仍有不同，例如：因犯重大暴力之罪而被判處無期徒刑者，於執行期間有後悔實

據而得獲假釋，於假釋期間故意更犯他罪而被撤銷假釋，然其所更犯之罪，可能屬施用毒品等未直接侵害他人生命、身體法益之犯罪或其他非重大暴力之罪者，此時如仍一律執行 20 年或 25 年殘餘刑期，即有輕重失衡之虞。更有甚者，受假釋人已獲假釋期間之長短不一，受假釋人執行更生計畫之成果亦有別，可能有出獄後仍不思上進、故態復萌而犯法者；亦有可能於假釋期間內努力復歸家庭、社會，僅因一時失慮再觸法網而遭撤銷假釋者。故再次執行刑罰之必要程度本有差異，自應對應不同情形給予輕重有別之對待，方屬衡平。是於撤銷假釋並執行殘餘刑期時，仍不應忽略撤銷假釋之原因事實、該無期徒刑已受執行之期間、受假釋人曾因有悛悔實據而受假釋之事實、在假釋期間為回歸社會所為之努力以及再犯可能性等情事，而為全盤考慮，始符前述刑罰必要性之原則，否則即有違反比例原則之虞。

【試題演練】

請說明何為裁量假釋及法定假釋？並論述我國假釋制度應屬何者，於改革方向上又應朝何者邁進？（30%）

自擬

一、裁量假釋與法定假釋：

- （一）裁量假釋：指立法者制定較為寬廣之量刑空間，並制定足夠長的刑期以便徹底改善犯罪人；法官亦判決較長的刑期作為上限，而沒有最低執行期間的要求。至於假釋之裁準與否，則交由專門之假釋審查委員會進行判斷，其僅受到法官判決之最長刑期拘束，並沒有假釋形式門檻的要求。
- （二）法定假釋：指立法者縮減裁量空間，並透過量刑準則使法官的判決更為明確；並減少行政機關之裁量空間，使得受刑人釋放之時點明確化。據

此，於裁量假釋之制度下，原則上在判決時即可確定受刑人的假釋時點，有著明確或至少可以在裁判之際即可計算出的服刑時間。

二、我國現行制度似乎屬裁量假釋；然而實務上運作結果則偏向法定假釋：

（一）於我國，假釋的准許與否，除法定要件外，尚需加上悛悔實據的實質要件，並由假釋審查機關針對個案狀況加以審酌。由於審查機關對於實質要件的個別審查判斷有一定的裁量空間，因此，我國的假釋應該屬於「裁量假釋」。

（二）然而，自 2005 年推動寬嚴並進的刑事政策以來，我國假釋門檻不斷提高，不僅無期徒刑需要服刑滿 25 年才能假釋，更設立三犯不得假釋條款（三振條款），大幅限縮假釋審查之裁量空間。學者即有指出，我國現行假釋制度的運作結果，其實法定假釋目標相當接近。

三、於改革上，似乎得同時融合裁量假釋與法定假釋制度，以達成多元矯治之目的：

（一）我國採取裁量假釋之制度下，針對假釋之標準難以客觀化，容易有恣意空間，再加上其與累進處遇制度結合，使得假釋成為監獄賜予受刑人的恩典，用以確保受刑人順從。在輿情不安時，這樣的架構容易使矯正人員採取封閉態度，並反映在假釋審查結果的模糊及審查結果嚴格化，以盡量延後出獄時點。然而，若貿然廢除現行制度，並以法定假釋取代，雖能減少行政機關恣意認定之風險，但卻也可能導致無法提供個案裁量空間、受刑人失去積極參與處遇計劃之動機、矯正人員減少了管理監獄秩序的工具，法可能考量法定假釋時點而普遍提高量刑等弊病。

（二）本文認為，裁量假釋與法定假釋始終並非二者擇一的關係；面對我國的困境，應探討能否透過裁量假釋及法定假釋的組合，考量多元矯正功能之達成，以強化受刑人回歸社會生活的能量。具體來說，裁量假釋在肩負起調整不必要刑罰之同時，也可以對個案狀況及其風險把關；而法定假釋則確

保受刑人原則上皆有假釋機會，並可以預期明確的釋放時點，藉此敦促資源與協助及早到位。據此，我國假釋制度的調整，或可將法定假釋與裁量假釋分別適用於不同對象如下：

1. 首先，針對一般有期徒刑類型，應可採取法定假釋之方式，以既有門檻（有期徒刑逾二分之一）作為假釋標準，以使其相較於現有之裁量假釋更能確保假釋機會與充分之假釋空間。而針對無期徒刑、累犯及累犯不得假釋等類型，則應給予假釋之機會，並採取裁量假釋之方式。其中，針對無期徒刑，應參酌假釋門檻合理上限為 15 年適度調降，並降低累犯假釋門檻，廢除不得假釋之規定，給予裁量假釋之機會。
2. 再者，應修改現行法下過苛甚至剝奪假釋機會的嚴重類型，給予假釋機會及裁量空間，確保社區處遇銜接機構內處遇的效果，並可充分考慮個案處遇情況，以使假釋審查委員會儘早觀察該受刑人的處遇表現與個案風險，促進矯正成效與鼓勵更生復歸，避免執行不必要之刑罰。
3. 此外，並應將假釋資格從累進處遇脫鉤，使受刑人與相關矯正人員能更明確預期釋放時點，提早進行社區處遇所需的各項準備，以藉由在監處遇與社區處遇的結合來落實社會再統合理念。

陸、慢性習慣犯與累犯之處遇³¹

一、慢性習慣犯之概念與疑慮：

- (一) 慢性習慣犯為犯罪學概念；依照慢性習慣犯之實證研究，無論是偏差行為、犯罪、被害、或犯罪發生地，都有集中的現象，也就是「少部分的人犯下了大多數的罪」。依照美國學者 Wolfgang 等人所進行的同生群青少年犯罪研究，追蹤了 9,945 名男孩。研究結果顯示，其中 6% 的人，犯下了 51% 的犯罪行為，其中牽涉了極為嚴重的犯行，包括 71% 的謀殺罪、73% 的強姦罪、82% 的強盜搶奪罪及 69% 的嚴重傷害行為。也因此，此種現象引發了防治對策之研究；長久以來，犯罪學者及刑事司法工作實務者相當依賴犯罪人集中性原則來提供或引導犯罪預防策略，並針對此些慢性習慣犯設計出另一套程序，用以集中資源監控、追訴或監禁之。
- (二) 然而，此種基於犯罪人集中而建構之政策，卻不無存在著本質邏輯點問題與執行困境。蓋因究竟應如何正確的辨別集中犯罪人，乃牽涉預測之問題；若能準確預測，這樣的刑事政策方有實質意義。然而，現行技術是否可以成功預測未來犯罪行為？倘若未能有效預測，那麼長期的隔離監禁，不僅不符正義，也浪費了龐大的監禁資源。再者，一旦集中現象產生，這些長年之習慣犯大多已經處於犯罪力下降之人生階段，此時再予以長期監禁隔離，顯然已經缺乏實益。不禁如此，長期隔離對政府預算造成龐大負擔，甚或監獄擁擠之社會成本加重。也因此，慢性習慣犯於刑事政策上究竟應如何應對，以及是否需要針對慢性習慣犯施加隔離，均不無疑問。

二、我國針對累犯處遇

(三) 累犯與習慣犯之關係？

1. 我國針對慢性習慣犯的防治，主要反映在累犯制度中。不過需要注意

³¹ 許春金、呂宜芬、游伊君、黃富源、蔡德輝，慢性犯罪者概念及復歸問題之檢視——兼論美國近代社會復歸法案之借鏡，刑事政策與犯罪防治研究第 33 期，2022 年 12 月，頁 181-232；許福生，犯罪學上慢性習慣犯防治之省思與未來展望，刑事政策與犯罪研究論文集第 11 期，2008 年 12 月，頁 67-88。

的是，慢性習慣犯與累犯其實並不是完全相同之概念；前者為犯罪學上之用語，為經過統計後得出「少數人犯多數罪」之結論。而後者則是刑法上用以加重處罰的分類，並設有自身門檻。不過，由於慢性犯罪者有相當可能多次犯罪，故二者間確實具有一定的重複性。

（四）累犯加重條款：

刑法第 47 條規定：「受徒刑之執行完畢，或一部之執行而赦免後，五年以內故意再犯有期徒刑以上之罪者，為累犯，加重本刑至二分之一。」

（五）三振條款：

1. 刑法第 77 條第 2 項第 2 款規定：「前項關於有期徒刑假釋之規定，於下列情形，不適用之：二、犯最輕本刑五年以上有期徒刑之罪之累犯，於假釋期間，受徒刑之執行完畢，或一部之執行而赦免後，五年以內故意再犯最輕本刑為五年以上有期徒刑之罪者。」
2. 2005 年修正理由：「對於屢犯重罪之受刑人，因其對刑罰痛苦之感受度低，尤其犯最輕本刑五年以上重罪累犯之受刑人，其已依第一項規定（執行逾三分之二）獲假釋之待遇，猶不知悔悟，於 1. 假釋期間、2. 徒刑執行完畢或赦免後五年內再犯最輕本刑五年以上之罪，顯見刑罰教化功能對其已無效益，為社會之安全，酌採前開美國『三振法案』之精神，限制此類受刑人假釋之機會應有其必要性，爰於第二項第二款增訂之。」

（六）釋字 775 號解釋：

1. 主文（節錄）：刑法第 47 條第 1 項規定，有關累犯加重本刑部分，不生違反憲法一行為不二罰原則之問題。惟其不分情節，基於累犯者有其特別惡性及對刑罰反應力薄弱等立法理由，一律加重最低本刑，於不符合刑法第 59 條所定要件之情形下，致生行為人所受之刑罰超過其所應負擔罪責之個案，其人身自由因此遭受過苛之侵害部分，對人民

受憲法第 8 條保障之人身自由所為限制，不符憲法罪刑相當原則，牴觸憲法第 23 條比例原則。於此範圍內，有關機關應自本解釋公布之日起 2 年內，依本解釋意旨修正之。於修正前，為避免發生上述罪刑不相當之情形，法院就該個案應依本解釋意旨，裁量是否加重最低本刑。

2. 理由書（節錄）：

- (1) 立法者之所以在原違犯條款所規定之處罰外，再以系爭規定一加重本刑之處罰，理由在於行為人前因犯罪而經徒刑執行完畢或一部之執行而赦免後，理應產生警惕作用，返回社會後能因此自我控管，不再觸犯有期徒刑以上之罪。然而行為人卻故意再犯後罪，足見行為人有其特別惡性，且前罪之徒刑執行無成效，其對於刑罰之反應力顯然薄弱，故認有必要加重後罪本刑至二分之一處罰。
- (2) 依上開系爭規定一法律文義及立法理由觀之，立法者係認為行為人於前罪徒刑執行完畢或一部之執行而赦免後，5 年內又故意違犯後罪，因累犯者之主觀惡性較重，故所違犯之後罪應加重本刑至二分之一。是系爭規定一所加重處罰者，係後罪行為，而非前罪行為，自不生是否違反憲法一行為不二罰原則之問題。
- (3) 惟系爭規定一不分情節，一律加重最低本刑。因目前實務上有期徒刑加重係以月為計算單位，如最低法定本刑為 6 月有期徒刑，累犯加重結果，最低本刑為 7 月有期徒刑。本來法院認為諭知 6 月有期徒刑得易科罰金或易服社會勞動即可收矯正之效或足以維持法秩序（刑法第 41 條第 1 項及第 3 項規定參照），但因累犯加重最低本刑之結果，法院仍須宣告 7 月以上有期徒刑，致不得易科罰金或易服社會勞動。因此，系爭規定一不分情節，基於累犯者有其特別惡性及對刑罰反應力薄弱等立法理由，一律加重最低本刑，於不符合刑

法第 59 條所定要件之情形下，致生行為人所受之刑罰超過其所應負擔罪責之個案，其人身自由因此遭受過苛之侵害部分，對人民受憲法第 8 條保障之人身自由所為限制，不符憲法罪刑相當原則，牴觸憲法第 23 條比例原則。於此範圍內，有關機關應自本解釋公布之日起 2 年內，依本解釋意旨修正之。於修正前，為避免發生上述罪刑不相當之情形，法院就該個案應依本解釋意旨，裁量是否加重最低本刑。

（七）慢性習慣犯之可能疑慮：

1. 如前述，慢性習慣犯之認定主要源自於 Wolfgang 所進行的同生研究。然而，究竟什麼叫做慢性習慣犯呢？這取決於追蹤的期間、暴露於犯罪機會的時間、犯罪次數等等因素的影響。換言之，分析的資料性質將會嚴重影響研究結果。此外，由於群組分類是統計分析的人為產物，可以為了分析某些結果而製造出顯著特性的群體。據此，慢性習慣犯的概念其實源自於事後的統計分類，並欠缺事先的、統一的定性。此外，每一位犯罪人之盛行率、犯罪頻率、犯罪持續性、犯罪嚴重性、生涯期間及犯罪歷程終止等因素及原因可能皆不相同，需個別研究。
2. 也因此，針對慢性習慣犯的刑事政策也會變得難以捉摸。比較法上，美國學者 Wenk 等研究團隊曾利用前科紀錄及臨床評估資料等，個別分析加州當局的 4,146 名青少年樣本。然而，依照其分析結果，該預測工具只有 50% 準確，並漏未預測一半真正成為暴力犯罪者的青少年。此外，更有 404 人被錯誤預測成暴力犯，這種誤假為真結果，使得該預測工具只有 12% 的正確率，如此的現象，意味著正確辨識、監禁 1 位暴力犯，將會同時監禁 8 位非暴力犯。Wenk 以及研究團隊的研究成果顯示，即使有廣泛資料得以運用，預測人類行為仍然是困難

重重，且將產生大量的誤真為假及誤假為真。縱使許多人認為，當我們看到時便「知道」誰是慢性習慣犯，但現實上正確的去預測未來行為仍是非常困難的。而若由該預測工具來推論 Wolfgang 同生群研究，他們將會錯漏一半的慢性習慣犯，並且會監禁 2,504 位無需監禁的青少年。

3. 而於我國，犯罪年齡以 19-20 歲為高峰期，24-25 為次高峰，45 歲以後已經很少，50 歲以後各個年齡層的慢性犯罪者只有個位數。毒品犯罪也有很明顯的高峰期，到 30 歲後期會急劇下降。由此亦可發現，年齡對犯罪有很影響力，而與慢性犯罪者之假設不符。

（八）慢性習慣犯之處遇：

1. 保守派：認為若能成功的長期監禁那間少數慢性犯罪者使其無法在犯罪，應可對犯罪率產生相當大的影響而大幅降低犯罪。而這類的處遇方式，包括預防性羈押、加重的定期刑、不定期的保安拘禁（預防性拘禁）等。
2. 自由派：認為若能成功處遇那些少數的慢性犯罪者使其改過遷善，便可大幅降低犯罪。
3. 面對慢性習慣犯，各國以往的處理方式大多以保守派為主，並採取嚴罰化的態度，引入不定期刑、加重定期刑、保安處分、刑罰與保安處分併科等等制度。然而，對於習慣犯採取不定期刑，將產生不符罪責原則、長期化造成反效果（不禁無法達到改善效果，更可能使受刑人因處境不確定而自暴自棄）、釋放結果不明確等等缺陷。以美國為例，其於 1990 年代引進三振法案，起初規範兩次以上重罪前科者於第三次受有罪判決時，無論所犯之罪之種類如何，皆處以終身刑。理由是認為許多重大犯罪皆為常習犯，對常習犯人即使僅觸犯輕罪，也應終身監禁以防範未然。但有些個案僅因久遠的兩次前科及第三次的輕罪及

被判處終身刑，引發各種疑慮，因此三振法案也逐漸修改，限定為有兩次重罪前科，且第三度因重罪受有罪判決者才適用。然而，依據相關研究，該國採取三振法案的州，犯罪率下降效果並未顯著；根本的問題，正是因為實務上欠缺對於再犯的預測能力。而縱使經過長時間觀察得出正確的預測結果，犯罪集中者往往已經高齡，而失去長期監禁的實益，更使得監獄過於擁擠、增加不必要的社會成本負擔。而同樣採取類似三振法案效果的我國，也面臨著相同的困境。

4. 針對我國慢性習慣犯究竟應如何處遇，學者有認為，應採取自由派的見解，並參酌美國法，提出較可行的方式如下：

- (1) 第二次機會法案：針對受刑人復歸社會後的挑戰提供協助，鼓勵並贊助各級政府及非營利組織、原住民社區等，並提供各項創意方案，使受監禁之成年與青少年復歸社會。
- (2) 禁止詢問犯罪記錄：有鑒於犯罪記錄嚴重有害前科者找尋工作，夏威夷於 1998 年成為全美國第一個通過 BTB 法案的州，該法案禁止政府和私人雇主在提供有條件就業機會前進行犯罪記錄調查。依照政策評估研究，於該法案推行後，有效地降低了夏威夷 57%再犯率。
- (3) 前科紀錄自動消除制度：為避免雇主後續仍可因背景調查而影響一開始的篩選決定，美國至今已經有 40 個州採行消除和封緘犯罪記錄政策。當前科犯在一定的期間不犯罪後，其再犯風險與一般人幾乎無異，那麼他們的犯罪紀錄就不應該再是給予工作與否的考量因素之一。
- (4) 第一步法案：該法案內容要求司法部長發展一套聯邦受刑人再犯風險與復歸需求的工具，提供監獄矯治人員使用，以便合適的分類受刑人至不同團體以參與合適的再犯降低方案。此外，該法案並授權

讓監獄與各種社會機構或非營利組織合作，提供受刑人社會復歸之方案。

- (5) 被告認罪但法院暫緩定罪：有別於一般的檢察機關緩起訴，於此種特殊情形，法院會接受被告認罪，但保留是否定罪及判決，並命被告於一段期間內附帶條件的緩刑。若被告成功完成緩刑，法院便會駁回起訴並撤銷被告原先所為的有罪答辯，被告並不會被定罪。

【試題演練】

慢性習慣犯，描述著「少數人犯多數罪」之現象，並成為近年犯罪學上相當熱門的議題。請分析我國現行法下就慢性習慣犯之處遇概況，並提出可能的改革方向？（30%）

自擬

【擬答】

一、我國目前就慢性習慣犯，係採取保守派之處遇方法：

（一）針對慢性習慣犯之處遇，大致可區分為保守派及自由派二大類型：

1. 保守派：認為若能成功的長期監禁那間少數慢性犯罪者使其無法在犯罪，應可對犯罪率產生相當大的影響而大幅降低犯罪。而這類的處遇方式，包括預防性羈押、加重的定期刑、不定期的保安拘禁（預防性拘禁）等。
2. 自由派：認為若能成功處遇那些少數的慢性犯罪者使其改過遷善，便可大幅降低犯罪。

（二）而觀諸我國對於慢性習慣犯之處遇，主要反映在累犯制度中；依照刑法第77條第2項第2款規定，針對犯最輕本刑五年以上有期徒刑之罪之累犯，於假釋期間，受徒刑之執行完畢，或一部之執行而赦免後，五年以內故意再犯最輕本刑為五年以上有期徒刑之罪者，排除假釋制度之適用。學

理上稱此為類似於美國之「三振法案」，並剝奪此類犯罪行為人假釋之可能性。由此以觀，我國目前針對慢性習慣犯之處遇，顯然係採取保守派之處遇方式，透過「長期監禁」避免慢性犯罪者再次犯罪。

二、於改革上，宜參考自由派之處遇方式，提供慢性犯罪者回歸社會之機會：

（一）針對保守派之處遇方式，毋寧係希望透過長期監禁來達到再犯防止之效果。然而，此種處遇方式有效之前提，為「有能力精準的預測慢性犯罪者」。而依照比較法上之研究，正確的去預測未來行為仍是非常困難的；甚而，縱使經過長時間觀察得出正確的預測結果，犯罪集中者往往已經高齡，而失去長期監禁的實益，更使得監獄過於擁擠、增加不必要的社會成本負擔。據此，若對習慣犯採取不定期刑，將產生不符罪責原則、長期化造成反效果、釋放結果不明確等等缺陷。

（二）是以，於改革方向上，似得參考自由派之見解，提供慢性犯罪者復歸社會之機會。具體做法，或可參考美國法之相關制度如下：

1. 第二次機會法案：對受刑人復歸社會後的挑戰提供協助，鼓勵並贊助各級政府及非營利組織提供各項創意方案，使受監禁之成年與青少年復歸社會。
2. 禁止詢問犯罪記錄：有鑒於犯罪記錄嚴重有害前科者找尋工作，禁止政府和私人雇主在提供有條件就業機會前進行犯罪記錄調查。
3. 前科紀錄自動消除制度：為避免雇主後續仍可因背景調查而影響一開始的篩選決定，當前科犯在一定的期間不犯罪後，其再犯風險與一般人幾乎無異，自應不再允許雇主查詢相關的犯罪記錄，作為是否雇用之參考。
4. 第一步法案：可要求司法機關發展一套聯邦受刑人再犯風險與復歸需求的工具，提供監獄矯治人員使用，以便合適的分類受刑人至不同團體以參與合適的再犯降低方案。

5. 被告認罪但法院暫緩定罪：有別於一般的檢察機關緩起訴，於此種特殊情形，法院會接受被告認罪，但保留是否定罪及判決，並命被告於一段期間內附帶條件的緩刑。若被告成功完成緩刑，法院便會駁回起訴並撤銷被告原先所為的有罪答辯，被告並不會被定罪，藉此提升被告遷過向善之動機。

柒、毒品法庭與治療式司法³²

一、毒品法庭概念的提出與背景：

（一）毒品法庭與問題解決型法庭：

1. 毒品法庭被認為是一種問題解決型法庭，改變以往法官認事用法、定罪量刑的責任，並主張法官應解決當事人的問題，使其不再犯罪。此種問題解決型法庭，在 20 世紀尾聲開始於美國各地逐漸出現。
2. 毒品法庭透過轉向措施（diversion program）將人從傳統刑事司法中轉出，參與者必須接受常態性藥物檢測、治療處遇方案並參與多元的個人及團體諮詢。在多元處遇中，法官將藉由獎懲的誘因設計監督毒品施用者（常見的懲罰內容如：增加每週參與匿名戒癮會次數、社區服務、短期監禁處分），如果完成方案，即可撤銷刑事指控或消除犯案紀錄，同時參加畢業典禮，讓社區及家人知道他的努力。只要能確保公共安全，毒品法庭因為節省經費而深具吸引力，而這種以毒品施用者轉向措施為主的設計被稱為「第一代的問題解決型法庭」。

（二）毒品法庭提出的背景：

3. 施用毒品與旋轉門司法：

- (1) 美國刑事司法中，相同被告不斷往返法庭並進出監獄的現象，被批評為旋轉門司法。這樣的現象除了來自於刑事立法的犯罪化與刑事司法行政的執行問題，更切實的是，無論是基於物質使用疾患、精神疾病或其他原因，這些人並沒有受到社會安全網妥善照顧，犯罪行為其實只是被司法觀察的現象而已。

(2) 在前端社會福利機構感到束手無策、後端假釋及緩刑部門力有未逮

³² 林俊儒，毒品法庭的批判性考察，國立政治大學碩士論文，2018 年 3 月；林俊儒，毒品法庭的制度內涵與爭議探討，犯罪與刑事司法研究第 31 期，2019 年 3 月，頁 35-70；林俊儒，論施用毒品者處遇的病犯體制：大法庭與刑事政策相互形塑的啟示與檢討，臺大法學論叢第 53 卷 s 期，2024 年 11 月，頁 1021-1076；林俊儒，刑事司法減害的毒品政策——走出病犯體制的旋轉門，國立政治大學博士論文，113 年 11 月。

之際，問題解決型法庭便關注到這個現象，希望從犯罪行為根本原因著手，藉由「法官為中心的處遇方案設計」統合跨機關的資源進行合作，來降低再犯率、緩解旋轉門司法的問題。

- (3) 針對毒品施用者而言，他們因為物質使用疾患的關係，不斷往返法庭與監獄間，這便是旋轉門司法的典型現象。為了能夠減輕刑事司法的負擔，毒品法庭決定從造成施用毒品行為的根源著手。這樣的做法，在甫成立佛羅里達州邁阿密達德郡毒品法庭的四年之後，即有研究指出：毒品法庭參與者的監禁比率及再逮捕率均較低，遂引起關注，被認為可能是刑事司法處理毒品施用者的良策。

4. 從懲罰到治療的轉變：

- (1) 在受到物質使用疾患的病理特質影響之下，有時難以期待施用者不再施用，因此施用毒品行為在本質上即有難以控制且反覆違犯的特質，是物質使用疾患與施用毒品罪的衝突所在。在這樣的理解之下，若施用者施用毒品是受到物質使用疾患影響而難以控制，於處罰意義上，無論是首次施用還是再施用的懲罰基礎都將要面臨到嚴重的挑戰。
- (2) 面對挑戰，毒品法庭決定轉換懲罰基礎的內涵，對於第一次施用毒品行為採取轉向措施、透過社區處遇處理，並且不直接將處遇階段內再施用毒品的行為認定為另一次的犯罪行為。但是，這不代表毒品法庭對處遇結束後施用毒品的行為一再採取轉向措施，也不代表毒品法庭將在處遇之中不斷容忍參與者再施用的行為，這涉及處遇目的採取「完全戒癮」(total abstinence) 或「減害」(harm reduction)，前者希望物質使用患者能夠完全戒癮；後者認為處遇目的在於了解人與藥物的互動關係並在了解傷害後學習控制用藥 (controlled use)。即便毒品法庭的作法基本上肯定病人特質，迴

避監禁弊害、給予治療與協助，但是在施用毒品行為仍然屬於一種犯罪的情況之下，毒品法庭還是不免得劃定一定的施用次數，以作為逐出處遇方案的界線，而劃定界線本身便是物質使用疾患與施用毒品罪衝突的具體樣貌。

5. 毒品法庭之立論基礎：治療式司法

(1) 治療式司法可以被視為一個運動（movement）、一個觀點

（perspective），甚或是一個領域（field）。從運動的角度切入，它以批評精神衛生法律造成精神疾病患者負面效果為始，影響精神衛生法律及問題解決型法庭的出現；從觀點的角度切入，它在分析法律及司法程序後，認為「法律」、「司法程序」及「法庭人員」對參與程序者的心理健康產生影響（例如：法庭上的證人、律師私底下與當事人的互動），進而聚焦在「法律本身具有的治療效力」及「司法程序對參與者心理健康的影響」，希望以法律及司法程序為黏著點，連結其他學科知識處理社會問題，讓法庭能夠成為處理成癮、家庭暴力、精神疾病的心理社會學機構（psychosocial agencies），而此連結逐漸成為一個重要的研究領域。

(2) 相較於傳統司法追求解決紛爭以及給予制裁的判決結果，治療式司法更期待透過科學促成司法程序的治療效果，認為司法程序將影響參與者，在減少心理及社會不利益同時增進當事人的利益。近幾年被廣泛地運用在精神衛生法、家庭暴力法、家事事件以及刑事案件，甚至已經影響法學院的教學。

(3) 在治療式司法之中，司法程序面向強調改善人際互動技巧（身體語言及語調強調關心、同理、真誠及理解）、尊重主體性以避免獨斷專擅、使用說服與激發動機的技巧（表達同感、了解不同特質與需求、增加參與者的自我效能感）、促使參與者完成處遇方案（避免

法律行話、家人及其他重要他人的加入、對於公眾的承諾、行為契約的管理)，來降低參與者在法庭互動上可能的健康風險以避免影響治療成效；處遇程序面向則強調迴避監禁弊害，避免隔離式懲罰無法妥適因應特殊個案的情形，這也和當事人與法律互動（例如：精神疾病患者較易觸法）及當事人與處遇規則接觸（例如：精神疾病患者較容易違反規則、毒品施用者因其成癮特質容易再行施用）的特殊性有關。這些應用通常落實在單純轉向措施、附條件緩刑、假釋等規範，形成一個帶有積極司法參與色彩的新司法取徑。

二、毒品法庭的疑慮：

（一）病犯與犯人：

1. 「成癮是種疾病」影響著毒品法制，但是在施用毒品行為未能除罪化之下，戒癮機制仍以刑事司法為中心，僅將病人身分疊加進犯人身分，形成「病犯」概念，在刑罰朝向特別預防時有著侵害醫療人權的危機。毒品法庭承繼此概念，將病人與犯人身分在毒品法制史的衝突帶進刑事法庭，成為制度設計的關鍵。即便「成癮是種疾病」的觀點已漸為人所接受，但政策方針仍然以刑事司法系統為基礎，毒品施用者先是一名犯人，才會是一名病人，而在身分疊加之下被理解為一名「病犯」。
2. 犯罪學家早已指出刑事司法與治療結合的問題，這些作法不見得如它表面所宣稱的仁慈，也並非總是良善且正確。施用毒品行為與成癮問題的重合，使得犯罪化與疾病化的觀點在毒品法制產生衝突。從這個角度來觀察毒品法庭，它以「治療罪犯」（cure the offender）作為口號，在刑事司法與治療結合的體制兼採犯罪化與疾病化觀點，讓刑事司法的治療功能與施用毒品罪的疾病色彩結合，「病犯」概念遂在毒品法庭茁生，使得爭議顯得更為複雜。

3. 毒品施用者普遍具有成癮問題，於醫學上被歸類為物質使用疾患，進而被認為是「患有疾病的犯人」。在施用毒品行為犯罪化之下，施用毒品的行為既是犯罪行為，也極可能是疾病病癥，毒品施用者不僅是「患有疾病的犯人」，更是「因病徵顯現而遭致處罰的病人」，因病徵顯現而遭到處罰的背後，則意味著患有特定疾病成為一種刑事犯罪。施用毒品行為與疾病的高度連結，已經嚴重打擊施用毒品罪的處罰基礎，促使毒品法庭將「治療優先於懲罰」作為宗旨，並且以社區處遇替代自由刑監禁而避免核心刑罰的施加。但是，這並不代表毒品法庭已經完全接納毒品施用者的病人身分，舉例而言：法律壓力下的監督仍將影響參與治療的自願性、處遇期間仍得劃定一定的再施用次數。這些作法都再再顯現，毒品法庭僅是「治療在特定條件下優先於懲罰」、「有條件接納毒品施用者的病人身分」。在毒品法庭有條件接納病人身分同時，既決定「誰是病人」也決定「誰是犯人」。

（二）間接強制與自願治療：

1. 毒品法庭透過完成處遇方案的利益（例如：撤銷刑事指控）說服或鼓勵被告參與，被告的選擇備受限制且具有相當的誘導性而促使被告參與。其次，在法律的利益與壓力之下選擇進入毒品法庭接受治療的被告，並不一定意味著違反意願，但其環境確實使得該決定具有較高的非自發性。此外，由於毒品法庭提供的處遇方案是一種替代監禁措施，被告難以拒絕，是具有一定權力性的力量。基此，毒品法庭雖然表面要求參與者同意，並非直接強制毒品施用者進入處遇，但參與治療的選擇空間被外力擠壓，屬於一種「間接強制」，具有強制性的色彩，與「純粹自願」相去甚遠，而有必要檢討國家干涉個人選擇的正當性。
2. 未達認知能力與判斷能力減損的物質使用疾患者有權不去接受治療，

也沒有義務一定得尋求減輕疾病痛苦的方式，更遑論未患有物質使用疾患的毒品施用者。毒品法庭一律透過間接強制的手段強迫毒品施用者接受處遇及其治療，其干涉正當性並不夠堅實。追根究柢，毒品法庭真正問題在於透過犯罪化來管制施用毒品行為的立法問題，但此問題往往為政治情勢妥協，轉從處遇制度設計來緩和正當性缺失，試圖減少強制色彩而回歸自願性的本質。

3. 如果人的決定不具有自願性缺陷，國家即難以證立其干涉自願決定的基礎；如果人的決定具有自願性缺陷，則其認知與判斷能力必然已經嚴重減損而導致他無法承擔起治療義務，無論一個毒品施用者是否因為物質使用疾患喪失其自願性，在這樣兩相為難之間，已經難以找到「治療義務」得以存在的位置，使得治療義務的說令人懷疑，毒品法庭藉由等級制裁制度強化「治療義務」的作法也就更顯爭議。

三、我國毒品施用者處遇現狀：

（一）我國毒品施用者處遇內容：

1. 初犯或三年後再犯：

（1）觀察勒戒：

A. 毒品危害防制條例第 20 條第 1 項規定：「犯第十條之罪者，檢察官應聲請法院裁定，或少年法院（地方法院少年法庭）應先裁定，令被告或少年入勒戒處所觀察、勒戒，其期間不得逾二月。」

B. 觀察勒戒後之處置（釋放或強制戒治）：毒品危害防制條例第 20 條第 2 項規定：「觀察、勒戒後，檢察官或少年法院（地方法院少年法庭）依據勒戒處所之陳報，認受觀察、勒戒人無繼續施用毒品傾向者，應即釋放，並為不起訴之處分或不付審理之裁定；認受觀察、勒戒人有繼續施用毒品傾向者，檢察官應

聲請法院裁定或由少年法院（地方法院少年法庭）裁定令入戒治處所強制戒治，其期間為六個月以上，至無繼續強制戒治之必要為止。但最長不得逾一年。」

(2) 緩起訴並附命戒癮治療：

- A. 毒品危害防制條例第 24 條第 1 項規定：「第二十條第一項及第二十三條第二項之程序，於檢察官先依刑事訴訟法第二百五十三條之一第一項、第二百五十三條之二第一項第四款至第六款或第八款規定，為附條件之緩起訴處分時，或於少年法院（地方法院少年法庭）認以依少年事件處理法程序處理為適當時，不適用之。」
- B. 刑事訴訟法第 253 條之 2 第 1 項第 6 款規定：「檢察官為緩起訴處分者，得命被告於一定期間內遵守或履行下列各款事項：
六、完成戒癮治療、精神治療、心理治療、心理諮商、心理輔導或其他適當之處遇措施。」
- C. 若緩起訴處分遭撤銷者，依照該條例第 24 條第 2 項規定：「前項緩起訴處分，經撤銷者，檢察官應繼續偵查或起訴。」

2. 三年內再犯：

- (1) 緩起訴確定後三年內再犯：仍可依照該條例第 24 條 1 項做成緩起訴處分，或依照第 20 條第 1 項向法官聲請裁定，令被告入勒戒處所觀察勒戒。
- (2) 觀察、勒戒或強制戒治執行完畢釋放後三年內再犯：僅可依照該條例第 23 條第 1 項依法追訴或第 24 條第 1 項做成緩起訴，無法再次聲請觀察勒戒。

3. 三年後再犯之起算點：109 台上大字第 3826 號裁定

- (1) 毒品條例於 87 年修訂施行後，對於施用毒品者雖肯認具有「病患

性犯人」之特質，惟囿於當時戒治及醫療體系均不完整、專業人員欠缺且戒毒知識尚有不足，社會大眾仍視施用毒品者為「犯人」而非「病患」，暨相關戒毒及事後之追蹤、輔導配套措施亦不完備，其刑事政策明顯將施用毒品者偏向「犯人」身分處理，導致監獄人滿為患，且施用毒品人口不減反增。為此，戒毒政策不得不改弦易轍，開始正視施用毒品者實屬「病患」之特質，先於 97 年新增毒品條例第 24 條附命完成戒癮治療緩起訴制度，希望能藉由機構外之完整醫療體系，提供毒癮戒治者合法妥適之治療，再以事後密集之監控措施防止施用毒品者再犯，而確立「附命完成戒癮治療緩起訴處分」及「觀察、勒戒或強制戒治」雙軌治療模式。

- (2) 毒品戒除不易，須經長期且持續之治療，為醫療及司法界之共識，施用毒品者既被視為「病患性犯人」，最佳處遇方式即為治療，期能逐漸減少毒品施用之頻率及數量，進而達到戒除毒癮的完全治癒目標。對於施用毒品者之治療方式，有機構外之處遇（如自行赴醫院戒癮、附命完成戒癮治療緩起訴處分等），或機構內之觀察、勒戒或強制戒治；至對施用毒品者科以刑罰，無非在運用刑罰之一般預防功能以嚇阻毒品之施用。
- (3) 惟刑罰因涉及人身自由及基本權，故於施用毒品初犯時皆以傳統之機構外或機構內處遇方式治療，如再施用毒品時，始科以刑事責任，一則懲罰其未具悔悟之心，再則以刑罰方式形成施用者之心理強制，以減少其毒品之施用，遏止其一犯再犯。而當刑罰處遇仍不能有效幫助施用毒品者改善惡習時，即表示無法以此方式發揮治療效果，若繼續施以刑罰只具懲罰功能，不僅無法戒除其毒癮，更漸趨與社區隔離，有礙其復歸社會。

- (4) 基於憲法保障人民之生存權，及根據每個國民生存照顧需要提供基

本給付之理念，為協助施用毒品者戒除毒癮復歸社會，對於經監獄監禁處遇後仍再犯之施用毒品者，更應恢復以機構內、外之治療協助其戒除毒癮。此即本次修正毒品條例第 20 條第 3 項關於施用毒品者所謂「3 年後再犯」係何所指之立法真諦。換言之，除檢察官優先適用毒品條例第 24 條命附條件緩起訴處分處遇（不論幾犯，亦無年限）外，對於施用毒品初犯者，即應適用第 20 條第 1 項、第 2 項為機構內之觀察、勒戒或強制戒治；若於上開機構內處遇執行完畢釋放後，「3 年內再犯」者，依第 23 條第 2 項規定，應依法追訴；倘於「3 年後再犯」，自應再回歸到傳統醫療體系機構內重為觀察、勒戒或強制戒治之治療。是對於戒除毒癮不易者，唯有以機構內、外處遇及刑事制裁等方式交替運用，以期控制或改善其至完全戒除毒癮。

- (5) 綜上，現行毒品條例既認施用毒品者具有「病患性犯人」特質，強調「治療勝於處罰」、「醫療先於司法」，對於第 20 條第 3 項及第 23 條第 2 項所謂「3 年後（內）再犯」，自應跳脫以往窠臼，以「3 年」為期，建立「定期治療」之模式。準此，第 20 條第 3 項規定中所謂「3 年後再犯」，只要本次再犯（不論修正施行前、後）距最近 1 次觀察、勒戒或強制戒治執行完畢釋放，已逾 3 年者，即該當之，不因其間有無犯第 10 條之罪經起訴、判刑或執行而受影響。

（二）現行毒品施用者處遇制度之困境：

1. 針對緩起訴處分並附命完成戒癮治療：

- (1) 林老師指出，由實證數據可知，緩起訴適用情形始終徘徊在一成。其箇中原委在於：減害理念的推廣、減少監禁負擔固然值得追求，但是檢察官對於作成緩起訴處分附命完成戒癮治療有其裁量權，更

會考量監督受緩起訴處分者履行狀況的負擔，以及撤銷緩起訴處分的成本。這些程序過於繁複，將導致檢察官寧願選擇較無後續程序負擔的聲請簡易判決處刑程序，不見得會樂意作成緩起訴處分。因此，當檢察官在經驗上認為透過緩起訴處分附命完成戒癮治療的方法未見效果，且又須費心監督並撤銷該緩起訴處分（更可能與判決效力產生齟齬），便將使得檢察官受到挫折，即容易依循經濟考量，傾向於不給予緩起訴附命戒癮治療，而改採聲請簡易判決處刑。

- (2) 但是，從醫學的觀點來看，毒癮復發與再施用毒品很難避免，物質使用疾患本身就具有反覆施用而戒斷不易的特徵，並不能武斷地認為戒癮無效，有時候再施用毒品反而是處遇介入的契機。緩起訴戒癮治療聲稱以減害為處遇理念，那便不應視再施用毒品如敵人，這並不代表治療無效，治療目標也並非保證不再施用毒品。
 - (3) 現行戒癮治療內涵有很大的改善空間，囿於人力資源不足及制度設計，成癮者除前往醫療院所門診取得替代療法藥物以及接受少數的心理治療外，便難以受到其他橫向連結協助，且給藥等待時間過長、給藥地點過遠、無法配合成癮者生活安排（例如：工作時間外出時取藥不便）、藥頭在醫院門口等候等問題，在欠缺社會資源（例如：無穩定就業及租屋）、欠缺資源整合機制介入及對毒品施用者的污名下，便難以重新融入社會，也難以拒絕毒品的誘惑。
2. 針對觀察、勒戒與強制戒治：林老師認為，現行實務作法與監禁管理相近而難以提供治療，且有污名化的現象。資源上，專職心理師與社工師人力資源不足，亦無良好的課程設計，沒辦法提供有效的治療服務。評估上，依照禁戒處遇成效評估辦法，各階段戒治成效評估是根據生活規律性、各階段課程參與計算，與監獄累進處遇措施相去不

遠，使得管理與教化如同監禁，無法反映其改善程度，也造成戒癮需求與成效評估與個案成癮狀況脫鉤的結果。觀感上，甚至產生入勒戒所與戒治所等同入監的污名化現象。這與隸屬法務體系，使得「病患型犯人」的犯人身分吞噬病人身分有關。

四、毒品法庭的省思與建議：

（一）強化處遇的自願性：

1. 林老師認為，為了盡量回歸自願性的本質，有必要從自願性的內涵著手，將進入毒品法庭的同意還原為「醫療行為的告知後同意」、「替代監禁措施的同意」及「刑事訴訟法理的同意」，分別充實「醫療決定資訊」、「非拘禁措施執行資訊」及「刑事訴訟權益變動資訊」，踐行告知後同意原則、告知以非拘禁措施執行的內容及其相異的程序、針對其開啟程序給予該相應的程序保障（例如：認罪協商的自願性要求）並告知所涉及的權益變動（例如：放棄律師權的利弊得失），以提升作成進入毒品法庭的決定品質，同時也有益於提升參與者的治療動機，而這是影響戒癮治療成效的關鍵。
2. 依照我國刑事訴訟法第 253 條之 2 第 2 項規定，戒癮治療固然需要獲得被告同意；然而，作業流程上卻僅要求「宜告知」，且告知內僅包含「法律規定及撤銷之法律效果」與「自費至醫療機構接受處遇」，有所不足。林老師認為，建議將告知程度修改為「應告知」並對於違反告知義務設有一定法律效果，且在告知範圍上兼及「醫療行為的內容」、「處遇執行的狀況」，俾藉由充實資訊以避免進入決定處遇的自願性更形惡化。同時，除書記官記明筆錄之外，也建議透過書面資訊輔以口頭說明，使被告更能有效理解資訊。

（二）再施用與再犯罪的脫鉤：

1. 毒品法庭的發軔，來自戒癮治療過程與刑事司法的齟齬，導致從懲罰

到治療的轉變，其中又以「再施用」被認定為「再犯罪」最為重要。就醫療觀點而言，「再施用」毒品本來就是戒癮治療過程中無法避免的情況，且「再施用」的意義從不同角度觀察將有不同的解釋，甚至可以認為「再施用」是治療的重要契機。基此，毒品法庭並不直接將「再施用」與「再犯罪」畫上等號，將考量治療狀況予以較寬鬆的認定。

2. 於我國，由於撤銷緩起訴處分乃由檢察官自行裁量，同樣缺乏明確標準以及支撐其標準的理念。這時候便須劃定明確標準，其標準不僅應以治療效益為念，更得以醫療人權為核心（例如：要求須經檢察官、觀護人、戒癮治療團體、醫師均同意方能撤銷），透過具有處遇及醫療專業的第三方監督來落實醫療人權。

（三）以醫療需求作為進入標準：

於我國，進入戒癮治療並未設定有一般處遇標準，使得緩起訴附命完成戒癮治療完全由檢察官決定，也導致了適用比率始終維持在一成。林老師認為，對此應重新建立標準，且該標準必須在考量醫療人權的保障上盡量寬鬆，否則即應該要透過衛生醫療部門提供自外於刑事司法的治療服務，以全面性確保其醫療人權。

（四）以減害理念作為畢業標準

1. 美國毒品法庭處遇理念偏向「完全戒癮」，並不若澳洲毒品法庭偏好於「減害」的理念，因此往往因為窄化治療成功的定義、限縮戒癮治療視野而飽受批評。對此，從根本性地質疑治療成效作為型塑毒品法庭的畢業標準，不再要求參與者承擔起其無法控制的治療成果，是在學理上較為正確的作法。
2. 對照台灣，緩起訴附命完成戒癮治療並未明確將畢業標準形諸規範之中，只要完成各自參與者所參與的戒癮治療期程即可謂完成，而該戒

癮治療的內容及其要求則視各地法院地檢署所合作的戒癮治療團體及醫療院所而定，較難以一概而論。林老師指出，未來應進一步研究各戒癮治療團體及醫療院所的具體作法，確認其處遇理念及其畢業標準為何，以期建立起多元認定標準，並使「非參與者所能控制的治療成效」與「是否能夠自處遇方案畢業」得以脫鉤。

（五）建構多元細緻的處遇內容：

1. 毒品法庭另一特色在於其多元細緻的處遇內容，根據參與者的表現構成階段性處遇，並根據當事人的需求提供合適的處遇服務，而這些制度設計則建立在制裁、誘因及治療調整的工具之上。雖然等級制裁制度的引進多有疑義，但其他處遇內容則具有相當高的參考價值。
2. 對照台灣，毒品戒癮治療實施辦法及完成治療認定標準第 3 條規定「戒癮治療之方式如下：一、藥物治療。二、心理治療。三、社會復健治療（第一項）。前項各款之治療方式應符合醫學實證，具有相當療效或被普遍採行者（第二項）」，在名義上設有三種不同的治療方式，並且要求該治療方式必須有醫療實證，但在緩起訴附命完成戒癮治療的實務運作，仍然偏重門診領取替代療法藥物，欠缺如毒品法庭般多元而細緻的處遇內容。至於緩刑附命完成戒癮治療，其具體的治療內容則更顯單調貧乏，甚至可以說是付之闕如，仍有相當大的改進空間。

（六）打造符合尊嚴的處遇制度：

林老師認為，參與者不僅是一名接受毒品施用者處遇的毒品施用者，同時也如你我一般是社會的一份子，既不應給予其無履行可能的要求，也不應對之施加不合理、甚至是有辱尊嚴的處遇，而這除了有賴明確的規範與落實，更需要藉由公正且中立的第三方作為監督，以確保一個有尊嚴的處遇制度得以落實。

捌、修復式司法與少年法

一、修復式司法³³

（一）定義及背景：

1. 定義與特徵：

- (1) 所謂的修復式司法，是指處理犯罪的方法並不是由國家來處罰加害人，而是透過被害人、加害人及社區的參與，將犯罪的實際影響明確化，並在社區的協助下要求加害人予以修復。
- (2) 重視犯罪對於具體被害人及社區的實際影響，並給予加害人一個機會讓他可以去挽救自己造成的過錯，更重要的是讓社區民眾也能正視自己的社會責任並共同解決犯罪問題。
- (3) 不只是一種解決糾紛的新技巧，更提出了一種新的價值觀，挑戰向來不受懷疑的罪與罰之間的連結，主張以積極的修負責任取代懲罰，並認為如此才能真正地實現正義。
- (4) 在理解犯罪方面，傳統的刑罰制度認為犯罪是違反刑罰法規的行為，所侵害的是抽象的法益。而修復式司法認為，犯罪不只是侵害了刑罰法規，更重要的是它侵害了具體的被害人，使原本的人際關係無法再保持平衡，對於被害人、加害人本身，以及他們的社區均造成傷害。
- (5) 在處理犯罪方面，依據修復式司法的主張，對於這些傷害，若以傳統的刑罰制度懲罰行為人，無疑是在既有的傷害上再增添傷害，無法充分修補犯罪所帶來的影響。而應該著重於修補惡害，強調透過被害人、加害人以及社區作為一個主體，積極參與對

³³ 謝如媛，少年修復式司法的批判性考察——從少年的最佳利益到利益衡平？，政大法學評論 152 期，2018 年 3 月，頁 125-186；謝如媛，夢想或現實？由紐西蘭經驗看修復式司法之可能性——由法院轉介之修復式司法方案為中心，成大法學 14 期，2007 年 12 月，頁 121-166；謝如媛，修復式司法的現狀與未來，月旦法學雜誌 118 期，2005 年 2 月，頁 41-51。謝如媛，刑事政策研究成果回顧，刑事法：10. 刑事政策研究成果回顧，法律研究成果回顧與社會影響性 2001-2020，2024 年 11 月（下期），頁 8-10。

話，使三方的需要與責任得以透過對話而明確呈現。這樣的對話與了解的過程，將有助於加害人的社會復歸，同時也能減輕被害人與社區的恐懼感，有助於回復被害人的創傷與社區的和平。

(6) 謝如媛老師認為，多數研究中所指出的修復式司法，具有以下共通要素：

- A. 強調被害人在傳統司法程序中的（負面）經驗、及其在修復式程序中應該並能夠享有的核心地位。
- B. 相關當事人（包括被害人、加害人、及其支援者）參與並討論犯罪相關事實和犯罪所造成的衝擊、以及為了修復被害所應採取的行動。
- C. 由非專業者和司法相關人士共同作成意思決定。

2. 背景：

- (1) 對於刑罰制度的不滿
- (2) 非正式司法的主張
- (3) 被害者學的發展以及被害者運動：存在兩種不同的立場
 - A. 針對具體被害人之被害人救濟運動，希望藉此緩和因被害所遭受之痛苦。
 - B. 追求「法與秩序」的保守運動，以「保護潛在的被害人」為名而主張嚴刑峻罰。

（二）模式：

- 1. 概說：修復式司法的定義會如此不明確，是因為其產生的背景蘊含各種社會上的力量和理念，以及大家對於正義各有其關心的重點與不同觀念。以下將介紹修復式司法主要的兩種理論模式，並就學說上對其內涵的理解有所歧異之處加以說明。
- 2. 純粹模式：與該犯罪有關之所有當事人匯聚一堂，由所有參與者共同

商討如何修復犯罪已經帶來的影響並展望未來的因應之道，這整個過程就稱為修復式司法。著重的是所有關係人（被害人、加害人以及可給予他們支持的社區成員）都能共同參與對話並充分討論的過程，而透過對話，來增加對於彼此及犯罪之前因後果的了解，並且嘗試尋求最佳的解決方法來修復被害人的傷害，以及協助加害人避免再犯。其常見之型態例如：被害人與加害人的調解方案、家庭協商會議、量刑圈等。

3. 最大化模式：透過修復犯罪所帶來的惡害使正義得以實現的一切活動，著重的是能否達成修復的效果，當事人等的參與並非必要條件。只要某措施或制度是以修復犯罪之損害為目的，而且實際上也達成修復損害之效果（所修復之損害可能是具體被害人所受的損害，也可能是指違背法律所造成的抽象損害），即可稱為修復式司法。其常見之型態，除了上述的被害人與加害人的調解方案、家庭協商會議、量刑圈以外，更包含賠償命令及社區服務命令等由司法機關所為的強制命令。
4. 爭點：是否應承認由司法機關科處的賠償命令與社區服務命令為修復式司法的一環？
 - (1) 有認為，現行的緩起訴制度中向被害人為損害賠償或命為社區勞動服務係修復式司法的實踐，而此說似乎較接近最大化模式的觀點³⁴。採最大化模式之觀點者認為，由法官所科予之強制性的制裁，只要法官係基於修復的目的而科處，且實際上亦能達到修復效果的話，均屬修復式司法的一環。其目的是希望盡可能把所有跟修復式司法之損害有關的活動都網羅到修復式司法的範疇內，以加速擴大修復式司法的影響力。

³⁴ 許春金、柯雨瑞等從修復式正義觀點探討緩起訴受處分人修復性影響因素研究（緩起訴罪犯恢復原狀的因素研究—來自恢復性司法的視角），犯罪與刑事司法研究 7 期，頁 182-185。

(2) 而純粹模式採取反對見解，因為賠償命令將修復被害限定於金錢賠償，將忽略被害人心理上的、金錢以外的其他實際需要，同時也無法使加害人真正認識到自己行為的後果予責任；至於社區服務命令則更須斟酌，由於其服務命令之內容與實際被害的修復可能完全無關，且通常是象徵性的透過勞動對社會負責，亦即象徵性的修復抽象的被害，具體被害人與社區反而隱而不見，其邏輯反而予刑罰制度更加接近。故純粹模式之論者認為，若承認其為修復式司法的型態之一，可能使修復式司法與傳統刑罰制度間的區別變得模糊。

5. 謝如媛老師則認為，應以純粹模式的定義為宜，理由如下：

- (1) 純粹模式強調參與的程序，可以確保當事人與社區在犯罪處理上的主體性，並明白顯示與刑罰的區別，如此才能突顯修復式司法作為一種新的思考典範的意義。
- (2) 必須重視因犯罪而受影響的具體的被害人、加害人以及與他們密切相關的社區成員，以他們為主體來釐清犯罪所造成的實際損傷、重視他們的需要（包括心理、經濟與文化層面），同時以修復（而非懲罰）為目標，來設計不同於刑事訴訟制度的犯罪處理程序。此外，尊重所有的人（包括加害人）誠實的對話、虛心的傾聽、相互關係的回復、責任的承擔、賦予當事人力量、以及帶來希望等，都是修復式司法非常重視的價值，並且與傳統司法制度中兩造對立甚至仇視的結構極為不同。
- (3) 若排除被害人與加害人之積極參與，而逕由司法機關決定加害人的責任，則此責任的內涵將脫離實際的被害而成為一個抽象的、強制的責任，加害人因履行此項責任所修復的對象也是抽象的法秩序，而非被害人實際上所受的傷害。如此修復式司法之內涵將

被掏空，徒留修復之名而無修復之實。

(三) 現行法制度：我國與修復式司法之精神有關的法律明文規定，散見於各部法律當中：

1. 刑事訴訟法：

- (1) 第 248 條之 2：「檢察官於偵查中得將案件移付調解；或依被告及被害人之聲請，轉介適當機關、機構或團體進行修復。（第一項）前項修復之聲請，被害人無行為能力、限制行為能力或死亡者，得由其法定代理人、直系血親或配偶為之。（第二項）」
- (2) 第 271 條之 4：「法院於言詞辯論終結前，得將案件移付調解；或依被告及被害人之聲請，於聽取檢察官、代理人、辯護人及輔佐人之意見後，轉介適當機關、機構或團體進行修復。（第一項）前項修復之聲請，被害人無行為能力、限制行為能力或死亡者，得由其法定代理人、直系血親或配偶為之。（第二項）」

2. 羈押法：

第 37 條：「看守所應辦理修復式司法相關宣導課程，並配合進行被告與被害人間之調解及修復事宜。」

3. 監獄行刑法：

第 42 條：「監獄得安排專人或轉介機關（構）、法人、團體協助受刑人與被害人進行調解及修復事宜。」

4. 犯罪被害人權益保障法：第四章為修復式司法專章

- (1) 第 44 條：「檢察官或法院依犯罪被害人及被告之聲請，轉介適當機關（構）或團體進行修復前，應說明轉介修復之性質，告知相關程序及得行使之權利。（第一項）參與修復之犯罪被害人及被告，得不附理由隨時退出程序。（第二項）」
- (2) 第 45 條：「檢察官或法院依被告轉介修復之聲請而詢問犯罪被害

人意見時，應注意其可能之情緒反應；必要時，得委由適當之人為之。(第一項) 犯罪被害人為無行為能力、限制行為能力、受監護或輔助宣告之人或死亡者，前項詢問應向其法定代理人、監護人、輔助人或家屬為之。(第二項) 修復程序之進行，應注意犯罪被害人之人身安全，並提供安全之環境及措施。(第三項)」

(3) 第 46 條：「檢察官或法院轉介修復時，應注意下列事項：一、保持中立，公平對待任何一方。二、尊重任何一方之自我決定意願。三、避免指導或勸導之口氣，亦不對任何一方之行為進行批判。四、保護參與者之隱私。」

(4) 第 47 條：「修復促進者或其所屬機關（構）或團體之人員，對於修復程序中所獲得之資訊，除犯罪被害人及被告同意外，不得無故洩漏。(第一項) 犯罪被害人及被告於非公開修復程序中所為之陳述，不得採為本案偵查或裁判基礎。但雙方同意或法律另有規定者，不在此限。(第二項)」

(5) 第 48 條：「修復促進者應具性別平權意識，尊重多元文化觀念，秉持專業、中立之原則，協助雙方當事人進行修復，並避免造成二度傷害。」

(6) 第 49 條：「相關機關辦理修復式司法業務時，得準用前五條規定。」

5. 少年事件處理法：

第 29 條第三項：「少年法院為第一項裁定（不付審理）前，得斟酌情形，經少年、少年之法定代理人及被害人之同意，**轉介適當機關、機構、團體或個人進行修復**，或使少年為下列各款事項：一、向被害人道歉。二、立悔過書。三、對被害人之損害負賠償責任。」

(四) 我國實務對修復式司法之理解：由下述我國實務所制定的實施計畫與應行注意事項，可知係以「純粹模式」為依歸：

1. 法務部推動「修復式司法方案」實施計畫³⁵：於第壹點即說明其目的係「為協助被害人、加害人、雙方家庭及受到犯罪事件影響的個人或社區成員，有機會陳述、表達需求及感受，提問與對話，進而自主決定是否討論及處理由於犯罪事件所造成的問題。」
2. 檢察機關辦理偵查中轉介修復式司法應行注意事項³⁶：其於第一點說明中提及：「修復式司法目的旨在協助被害人、行為人、雙方家庭及受到犯罪事件影響之個人或社區成員，有機會陳述、表達需求及感受，提問與對話，進而自主決定是否討論及處理由於犯罪事件所造成之問題，並藉由修復程序之進行，尊重個人尊嚴與平等，促進社會和諧與預防犯罪。」
3. 法院辦理審判中轉介修復式司法應行注意事項³⁷：其於第一點說明中提及：「修復式司法制度，旨在修復被害人與被告因犯罪而破裂或受犯罪影響之關係，雙方於修復過程中，經由專業中立之修復促進者協助，在和善、自願、安全、尊重、平等及不受干擾之情境下坦誠對話溝通，了解犯罪事件緣由、結果及影響，尋求修補犯罪所造成傷害之方式。受影響之社區或他人亦可參與其中面對犯罪問題，支持被害人及被告重新融入社會，進而避免再犯及促進和諧，以為傳統刑事司法制度之替代或補充。」
4. 實務判決

- (1) 近期有部分實務判決於論述中提及修復式司法之概念，例如最高法院 114 年度台上字第 5244 號刑事判決提及³⁸：「……被告是否

³⁵ 法務部 107/10/22 法保字第 10705509930 號函。

³⁶ 法務部 112/06/30 法檢字第 11204520950 號函。

³⁷ 司法院 110/07/29 院台廳刑一字第 1100021752 號函。

³⁸ 臺灣高等法院 107 年度交上訴字第 177 號刑事判決、臺灣高等法院 106 年度上訴字 2519 號

適宜宣告緩刑，係屬實體法賦予法院得自由裁量之職權，法院於裁量時，不惟應視其犯行之輕重而定，同應觀察犯罪行為人以如何之刑罰處之、行之，最有助於其復歸社會、回復法之和平；且相較於宣告刑之諭知，緩刑既係給予個案被告暫不執行刑罰之觀察期間，自更著重於犯罪行為人是否適於緩刑，亦即以『特別預防』為最重要之考量，此觀刑法於民國 94 年修正時，以修復式司法之思惟，著重於社區、人際等關係被破壞之修復，與犯罪行為人應負擔之行為責任方式之轉換，命受緩刑宣告之被告應受一定之負擔，更堪認定。」

- (2) 由上開判決要旨可推知，實務判決似乎是將非以懲罰為目的之處分，視為是修復式司法的範疇（似採最大化模式？），實務雖援用修復式司法的名義，但實際運作上似乎與導入此概念前無異，並無提供雙方對話之機會。若將此種由國家強制力要求加害人受一定負擔之處分，視為修復式司法的一環，可能導致修復式司法的概念流於空洞，削弱其理念精神。

【試題演練】

於修復式司法的立法模式中，主要有「純粹模式」與「最大化模式」二者。試問二者之內涵為何？於制度選擇上，又應以何者為佳？（30%）

自擬

【擬答】

一、純粹模式與最大化模式之內涵：

- （一）純粹模式：本模式之基本理念，在與該犯罪有關之所有當事人匯聚一堂，由所有參與者共同商討如何修復犯罪已經帶來的影響並展望未來的

因應之道。換言之，純粹模式著重的是所有關係人（被害人、加害人以及可給予他們支持的社區成員）都能共同參與對話並充分討論的過程，而透過對話，來增加對於彼此及犯罪之前因後果的了解，並且嘗試尋求最佳的解決方法來修復被害人的傷害，以及協助加害人避免再犯。其常見之型態例如：被害人與加害人的調解方案、家庭協商會議、量刑圈等。

- （二）最大化模式：本模式則著重於透過修復犯罪所帶來的惡害使正義得以實現的一切活動。換言之，最大化模式著重的是能否達成修復的效果，當事人等的參與並非必要條件。只要某措施或制度是以修復犯罪之損害為目的，而且實際上也達成修復損害之效果，即可稱為修復式司法。其常見之型態，除了上述的被害人與加害人的調解方案、家庭協商會議、量刑圈以外，更包含賠償命令及社區服務命令等由司法機關所為的強制命令。

二、於制度選擇上，似應以純粹模式為佳：

- （一）修復式司法，既然強調「與傳統刑罰不同」，並作為一種新的思考典範；那麼，於其參與程序上，自然需要重視因犯罪而受影響的具體的被害人、加害人以及與他們密切相關的社區成員，以他們為主體來釐清犯罪所造成的實際損傷、重視他們的需要（包括心理、經濟與文化層面），同時以修復（而非懲罰）為目標，來設計不同於刑事訴訟制度的犯罪處理程序。這與傳統司法制度中兩造對立甚至仇視的結構極為不同。
- （二）據此，若於修復式司法中排除被害人與加害人之積極參與，而逕由司法機關決定加害人的責任，則此責任的內涵將成為一個抽象的、強制的責任，加害人因履行此項責任所修復的對象也是抽象的法秩序，而非被害人實際上所受的傷害。如此修復式司法之內涵將被掏空，徒留修復之名而無修復之實。

(三) 據此，本文認為，於制度選擇上宜採取純粹模式，以確保確保當事人與社區在犯罪處理上的主體性，並明白顯示與刑罰的區別。

二、少年修復式司法³⁹

(一) 理論（少年事件與修復式司法的親和性）：相較於成人刑事案件，少年事件的理念與處理似乎更容易讓人連結到修復式司法的理念與作法。理由如下：

1. 少年事件的處理以促進少年的健全成長為目的，在程序上（尤其是保護事件的審理）較具彈性。例如：審理不公開或得不公開（少年刑事案件）、協商式審理、少年法官須以懇切態度進行審理等，均帶來較為柔性溫暖的印象。
2. 少年事件重視對少年的教育與處遇功能，與修復式司法所強調的尊重當事人需求、修復被害、修復人際關係、重視表達與溝通等非正式、非懲罰性的特徵比較相容。
3. 少年司法的重點始終在於「人」而不是「行為」或「非行事實」，而少年法官處理少年事件的目的，也不是審理非行事實，而是處理潛藏在非行事實底下的人格及環境問題。
4. 少年事件實務上（尤其是保護事件程序）也發展出許多有價值的觀念，例如以少年為中心、少年的改變可能性、家庭修復、社區修復、成長發展權、協商式審理、團體醫療模式等，這些觀念與作法，使得少年司法制度無論在理論上或實踐上都有更大的空間來發展修復式司法。因此，可以看出少年司法與修復式司法可能都傾向

³⁹ 謝如媛，少年修復式司法的批判性考察——從少年的最佳利益到利益衡平？，政大法學評論 152 期，2018 年 3 月，頁 125-186；謝如媛，夢想或現實？由紐西蘭經驗看修復式司法之可能性——由法院轉介之修復式司法方案為中心，成大法學 14 期，2007 年 12 月，頁 121-166；謝如媛，修復式司法的現狀與未來，月旦法學雜誌 118 期，2005 年 2 月，頁 41-51。謝如媛，刑事政策研究成果回顧，刑事法：10. 刑事政策研究成果回顧，法律研究成果回顧與社會影響性 2001-2020，2024 年 11 月（下期），頁 8-10。

於強調社會福利的色彩、重視社會復歸、強調少年的家族與社區的角色等特徵。

5. 少年的可塑性較高。有論者認為，少年經過修復式司法取向的措施可減低其再犯率，可能是因為少年涉世未深，動之以情均能觸動內心良知；且少年犯罪情節與動機通常較單純，比較容易處理之故。
6. 少年事件被害人的需求有別於成人刑事案件的被害人，而被害人權利越受到重視，則向來以少年利益為核心考量、被害人權利更為受限的少年司法程序就越容易受到關注或挑戰，這點或許也是少年法制採納修復式司法的重要因素。也就是說，在被害人相關因素滲透並強化的趨勢下，修復式司法成為少年法制可能採取的一種回應。

（二）嚴罰化之趨勢以及被害人權利運動的影響

1. 控制文化以及要求少年負責的思想對於少年法制的影響
 - (1) 1970 年代以後，出現重新倚賴應報、嚇阻以及監禁無害化（incapacitation）的現象，也被稱為「刑罰惡害運動」（penal harm movement）。
 - (2) 至 1990 年代，在歐美因「控制的文化」的蔓延，以福利思想為基礎的少年事件處理程序或判決受到許多批評，認為這種福利取向的司法程序容易造成裁量上的濫用，使得少年遭遇雙重不利益，限於受到過多的懲罰或欠缺充分的保護的雙重危機；「正當應報」的觀念又再度占據少年司法的重要地位，主張削減司法裁量空間以「回歸正義」。進而影響許多西方國家少年法制度修法，強調少年的行為責任更甚於少年的需求、強調懲罰更甚於福利。
 - (3) 此種趨勢實際上反映在降低少年刑事責任年齡、擴大少年事件劃歸成人刑事法院的管轄範圍、增加監禁對象等措施上。制度上對少年越來越不寬容，也採取某些懲罰性措施來取代傳統對於兒童

的保護與福利。

2. 被害人權利運動對少年法制的影響：被害人的地位逐漸受到重視，認為以往的少年司法往往為了保護少年而過度限制被害人參與司法程序、被害人難以獲得有關案件與行為人的充分資訊、被害人在少年司法程序中的處境比刑事司法程序更為不利等，使得各國開始修法增加被害人獲取少年審判的資訊或參與少年審判的機會，因而對一些少年法的基本原則造成衝擊。例如：被害人可在法官決定處遇內容之前，進行口頭或書面的被害影響陳述。
3. 少年修復式司法的產生：在上述的背景之下，因而有各種見解基於不同的觀點，認為可將修復式司法的概念導入少年法制當中，以下將分別介紹：

(1) 認為修復式司法可以兼顧少年與被害人之利益：

- A. 此說的出發點在於少年的真心道歉、被害人與社區對少年的接納、各方關係的修復等方面。例如，主張若非行少年真心向被害人謝罪、被害人及社區因此接納少年，這應該與少年法本來的目的相一致；反過來說，如果將被害人隔離在少年事件審理程序之外，甚至在少年處遇結束之後，被害人都沒有充分的資訊或參與的機會，則被害人當然會感到憤怒，社會對於少年司法也會有所質疑。
- B. 修復式司法對少年的更生具有重要性。因為即使是造成死亡結果的重大事實，對於少年而言，都只能抽象地加以想像，完全無法體會死亡是什麼意思，而這個無法挽回的悲劇又對被害人的遺族造成什麼樣的傷害。若能讓少年瞭解被害人的處境，可以促進其反省自己的行為，並且改善其性格。
- C. 少年很容易遺忘「自己案件的被害人」，在矯正輔導階段，若

在看不見被害人的情況下進行輔導，由於缺乏實際的感受，效果將會大打折扣，原因在於少年在事件發生之後，一直沒有實際上面對被害人，隨著時間的流逝，少年再回想自己的非行行為時，容易產生過輕的評價，而減輕自己的責任感，因此有必要使少年面對被害人或向其道歉。

D. 若在充分的規劃與協助下，透過與被害人的對話或其他接觸方式，使少年能夠瞭解自己的行為所造成的影響，並且自然產生修復或彌補被害的責任感，對於少年的更生將發揮重要的作用，並兼顧被害人的利益。同時，在這樣的過程中，若能鼓勵義工的參與協助，長期來看，也可促進社會對於少年的瞭解與對被害人的支持，有助於少年與被害人復歸社會。

E. 綜上，採此見解之論者認為，使被害人與少年面對面，並未違反少年法的理念，反而對於少年的健全成長來說是很重要的。此觀點基本上認為修復式司法是一種調和少年利益與被害人利益的途徑，使雙方利益得以兼顧、平衡，而不會極端地偏向少年。

(2) 認為修復式司法可緩和嚴罰化趨勢：反對治亂世用重典之論者則主張將修復式司法作為嚴罰化氛圍中的新途徑，用來轉換舊觀念與懲罰的方式；在修復式司法中，實務工作者可以利用調解等機制，一方面使非行少年修補其行為所造成的傷害，並藉由對於被害者的道歉及賠償等方式，教育少年如何彌補過錯、避免再犯；另一方面，透過少年親權人的全程參與，亦可改善親子關係並強化親職功能；而被害之一方則可進而瞭解少年非行之背景因素、平復傷痛並獲得補償，社會亦得以伸張正義並加強防衛。

（三）以被害人為中心的修復式司法能否促進少年的最佳利益？

少年的健全成長是我國少年事件處理法（下稱少事法）的立法目的，也是社會對少年司法制度的共識；已內國法化的兒童權利公約亦強調少年事件的處理應該以少年的最佳利益為優先考量。

1. 少年最佳利益之內涵：

(1) 少年事件處理法（下稱少事法）第 1 條之目的規定：「為保障少年健全之自我成長，調整其成長環境，並矯治其性格，特制定本法。」並基於此目的，透過少事法來保障少年的自我成長權、創造出一個特殊的少年期——一個容忍個人的生存價值的法空間，以維護少年的最佳利益；另一方面也賦予成人協助的義務，要求國家、成人社會透過成長環境的調整與性格的矯治來確保少年實現自我的機會。

(2) 兒童權利公約第 3 條第 1 項：「所有關係兒童之事務，無論是由公私社會福利機構、法院、行政機關或立法機關作為，均應以兒童最佳利益為優先考量。」且依照該公約第 1 條之規定，兒童係指未滿十八歲之人。

2. 少年的更生：修復式司法的實踐中，強調少年必須認識自己的錯誤、能夠自發地道歉，並且負起修復被害的責任，以促進少年的更生。並且可能認為少年的利益與被害人的利益（甚至與社會的利益）是相一致的，也就是說，促進少年對於被害（人）的理解，並進而負起責任，可以使雙方（甚至包括社區在內的三方）皆大歡喜。然而，謝老師指出，此種方法是否確實能兼顧各方利益，仍有以下疑慮：

(1) 使少年認識自己所造成的損害未必有助於少年的更生。

(2) 少年的身體及心理承受能力可能使其無法在犯罪後立即展現出悔意：要求犯罪人在犯罪後就感到懊悔自責，其實是與心理上

的自然反應相違背的。因為懊悔自責是一種極度深刻的痛苦，而人性使人容易趨向於啟動心理防衛機制以避免承受令人痛苦的真相；而由於少年所能忍受痛苦的期間較短，使得他們既害怕懊悔並且也難以持續地顯示出懊悔或抱歉的心情，這些因素使他們在犯罪後的表現往往無法符合司法制度的期待。當我們把認識被害當作更生的必要條件，就更容易期待或要求少年儘速面對自己行為的後果，而輕視了深入探求少年個別需求與成長進程的必要性。

- (3) 過於強調責任的傾向：在犯罪控制文化下，強調個人的管理與責任，犯罪容易被建構在犯罪人（少年）個人的態度、舉止、道德認知及交友關係方面的缺陷上。在這種情況下，容易忽略（少年）犯罪的社會脈絡，不再重視社會經濟的不利益對犯罪人（少年）參與重要的社會活動究竟造成何種阻礙。而在修復式司法的實踐中，也可以看到這種強調責任的傾向。有一部分原因來自於修復式司法的相關論述往往過於依賴一個簡化的被害人與加害人的概念，用二元對立的方式加強了此種互斥的分類，而忽略其複雜性。

（四）少年最佳利益及少年修復式司法：

謝如媛老師認為，如上所述過於強調少年應承擔修復責任的見解，可能帶來不良後果。由於修復的目標都是以少年能夠主動、正面地行動、並且有能力參與道德上、情感上的活動為前提，而這些前提代表著我們已將少年看作是一個可以負責任的、完整的或是幾近完整的道德主體，然而，由於少年未成熟的特性，這種前提或對少年的期待，其實與現實有距離，少年事件的處理應該著重教育的功能，在逐步而充分的支援過程中才能達成上述目標。少年事件往往涉及許多利益的衝突，著重於考量少年的最佳利

益，也就意味著某些情況下將受到來自輿論或被害人的質疑。而修復式司法若欲促進少年的更生，並同時兼顧被害人權益，需要具備以下條件：

1. 認識少年的特性：由於少年的某些特性，使得現實上少年向被害人道歉或進行賠償的情況不如成人頻繁：
 - (1) 非行少年在精神上尚未成熟。
 - (2) 無法單獨進行金錢賠償。
 - (3) 欠缺律師的支援，難以獲得專業的建議。
 - (4) 過於簡化父母的角色。
 - (5) 少年的加害者性與被害者性。
2. 在可落實少年最佳利益的情況下兼顧被害人的權益：少年司法制度的核心在於保障少年的成長機會並且提供相關資源來調整環境，當少年司法制度在納入其他措施或要素時，也必須堅守這個目的。即使採納了修復式司法的理念與作法，少年司法制度仍然會以少年為中心，而不是以被害人為中心。換言之，修復式司法於司法中的角色，必須在符合少年健全成長的目的下採用，並且需要優先考慮少年的最佳利益來開啟程序。而在考量少年最佳利益的情況下進行的修復式司法，被害人或許無法成為發動修復式程序的主導者，但程序的進行仍應絕對尊重被害人的自主意願。
3. 少年的再統合與社會融入：如何讓非行少年能夠再統合於社會、重返社會，不僅是少年法的目的，也是修復式司法的重要目的。並且，政府應重視其提升少年福利的責任，著重於理解少年的成長歷程與造成犯罪的動機，對於少年提供有利其建立社會連結的資源與機會，使其能夠再融入社會。

玖、被害人參與與少年法

一、被害人參與⁴⁰

(一) 被害人保護運動的興起：

1. 1970 年代，世界各地的被害人運動有如風起雲湧。被害人運動強調被害人是被遺忘的一方，指出無辜的被害人向來被忽略，他們個人的、情感上的、經濟上的損害也沒有受到回復。
2. 1980 年代，各國先後提出被害人權利法案，在國際上也有聯合國及歐洲議會提出被害人權宣言。被害人議題受到重視，其權益也獲得大幅提升。臺灣對被害人權益的論述也日漸增加。
3. 1985 年聯合國「犯罪被害人及權利濫用被害人司法基本原則宣言」(Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power)來看，促進被害人在司法程序上權益的可能途徑，至少包括了三個方向：
 - (1) **對被害人提供必要的資訊**：包括案件發生之後，犯罪偵查單位定期或不定期向被害人及其家屬報告偵查結果，使其能在偵查不公開的限制底下，也能適當地瞭解案件發展情形。
 - (2) **刑事程序中對被害人的保護**：含有防止被害人受到二次傷害的用意，例如我國性侵害犯罪防治法中的被害人資料保密、得遠距隔離訊問、禁止新聞揭露被害人身分等。
 - (3) **提供被害人參與刑事訴訟程序的機會**：指在不侵害犯罪嫌疑人或被告之權利、且與該國刑事司法制度不相矛盾的限度內，允許被害人在司法程序的適當階段，就其有利害關係之事項提出

⁴⁰ 謝如媛，犯罪被害人參與少年司法程序之研究，司法院，2011 年 7 月；謝如媛，犯罪被害人陳述制度之成效－從英國實證研究成果出發，法學新論 30 期，2011 年 6 月，頁 13-34；黃士軒，初探日本少年保護事件審判程序中的被害人參與—以卷證之閱覽抄寫、陳述意見與旁聽為中心，法官協會雜誌 26 卷，頁 49-69；許恒達，析論犯罪被害人參與少年司法程序之爭議—借鏡德國少年刑事程序法制，法律扶助與社會 5 期，2020 年 9 月，頁 29-56。

意見與關切，並考量其意見與關切事項。

4. 各國政府或非政府組織也日漸重視被害人在刑事程序中應有的地位，甚至實際推動立法，使被害人得以獲得相關資訊、在訴訟程序中得到應有的保護，進而在起訴、量刑、假釋審查階段都有表達意見的機會，甚至要求法官將被害人的意見作為量刑的參考，或允許被害人表達所期待的具體量刑內容等。

（二）現行制度：刑事訴訟法

1. 第 248 條之 1：「被害人於偵查中受訊問或詢問時，其法定代理人、配偶、直系或三親等內旁系血親、家長、家屬、醫師、心理師、輔導人員、社工人員或其信賴之人，經被害人同意後，得陪同在場，並得陳述意見。（第一項）前項規定，於得陪同在場之人為被告，或檢察官、檢察事務官、司法警察官或司法警察認其在場，有礙偵查程序之進行時，不適用之。（第二項）」
2. 第 248 條之 2：「檢察官於偵查中得將案件移付調解；或依被告及被害人之聲請，轉介適當機關、機構或團體進行修復。（第一項）前項修復之聲請，被害人無行為能力、限制行為能力或死亡者，得由其法定代理人、直系血親或配偶為之。（第二項）」
3. 第 248 條之 3：「檢察官於偵查中應注意被害人及其家屬隱私之保護。（第一項）被害人於偵查中受訊問時，檢察官依被害人之聲請或依職權，審酌案件情節及被害人之身心狀況後，得利用遮蔽設備，將被害人與被告、第三人適當隔離。（第二項）前二項規定，於檢察事務官、司法警察官或司法警察調查時，準用之。（第三項）」
4. 第 271 條第二項：「審判期日，應傳喚被害人或其家屬並予陳述意見之機會。但經合法傳喚無正當理由不到場，或陳明不願到場，或法院認為不必要或不適宜者，不在此限。」

5. 第 271 條之 1 第一項：「告訴人得於審判中委任代理人到場陳述意見。但法院認為必要時，得命本人到場。」
6. 第 271 條之 2：「法院於審判中應注意被害人及其家屬隱私之保護（第一項）被害人依第二百七十一條第二項之規定到場者，法院依被害人之聲請或依職權，審酌案件情節及被害人之身心狀況，並聽取當事人及辯護人之意見後，得利用遮蔽設備，將被害人與被告、旁聽人適當隔離。（第二項）」
7. 第 271 條之 3：「被害人之法定代理人、配偶、直系或三親等內旁系血親、家長、家屬、醫師、心理師、輔導人員、社工人員或其信賴之人，經被害人同意後，得於審判中陪同被害人在場。（第一項）前項規定，於得陪同在場之人為被告時，不適用之。（第二項）」
8. 第 271 條之 4：「法院於言詞辯論終結前，得將案件移付調解；或依被告及被害人之聲請，於聽取檢察官、代理人、辯護人及輔佐人之意見後，轉介適當機關、機構或團體進行修復。（第一項）前項修復之聲請，被害人無行為能力、限制行為能力或死亡者，得由其法定代理人、直系血親或配偶為之。（第二項）」
9. 第 455 條之 38：事實審程序中，被害人得於第二審言詞辯論終結前，向法院聲請參與訴訟。
10. 第 455 條之 41：訴訟參與人得隨時選任代理人。
11. 第 455 條之 42：訴訟參與人之代理人得於審判中檢閱卷宗，訴訟參與人未選定代理人時，得預納費用請求交付影本，但得予限制。
12. 第 455 條之 46：訴訟參與人及代理人得對證據之調查表示意見。
13. 第 455 條之 47：訴訟參與人及代理人得對科刑範圍表示意見。

（三）謝如媛老師認為，被害人議題當中最具爭議的是被害人陳述制度，其中學者們見解的差異如下：

1. 肯定說之論者認為被害人陳述制度具有以下優點：
 - (1) 允許被害人陳述其所遭受的侵害，可使司法機關瞭解犯罪的實際衝擊，而這是以往容易被忽略的部分。
 - (2) 審判者必須瞭解被害的情形以作成適當的判決。犯罪的侵害愈嚴重，懲罰也就應該愈重，而被害人陳述可以提供詳細的被害狀況。也有學者進而主張，讓被害人參與量刑，可以促進公平的審判。
 - (3) 賦予被害人在法庭上陳述的機會，使其被害可以在一個公開、正式的情況下直接讓相關人士理解，這象徵了社會承認被害人的痛苦，以及被害人對刑事程序的重要性。同時，它可能帶來療癒的效果，因為被害人透過陳述，得以整理自己的心情來面對接下來的人生，也可能因為法官的瞭解或話語而得到安慰。
 - (4) 被害人可以選擇在法官及被告面前陳述，透過這樣的方式，被害人可以當面告訴被告，該犯罪所帶來的實質傷害。而這樣的方式可以促使被告瞭解自己的行為並同情被害人，因而有助於被告的更生。
2. 由於被害人陳述制度的推進過程中，遭受法律專家強烈的反對，因此支持被害人陳述制度的理由一度從強調其對被害人的療癒效果，逐漸轉移重心到強調被害人陳述的工具性目的，亦即是否能夠符合法院（量刑）的需求、或其對於量刑的影響等問題。其轉變的背景在於：
 - (1) 在犯罪學的相關研究上，刑罰執行的社會復歸效果受到質疑，正當應報（just deserts）理論則逐漸抬頭，因而使得刑罰的基礎更加著重在加害人的責任與犯罪的被害程度。
 - (2) 透過被害者學眾多有關「二次被害」的研究，被害人在司法

程序上的疏離與挫折漸為人所認知，而被害人參與程序的問題也日漸受到重視。

3. 然而，由於被害人陳述制度始終無法解除其有可能損害被告正當程序保障之疑慮，而且實證研究發現，該制度對於改善量刑並沒有發揮明顯的作用。因此，學者對於被害人陳述制度的討論，又轉而重視被害人陳述的原始目的，亦即是否有助於促進被害人的福利、是否發揮療癒效果等層面上。
4. 反對說之論者認為被害人陳述制度具有以下缺點：
 - (1) 被害人的主觀陳述在未經交互詰問的情形下，可能不當地影響判決，並因此侵害被告的權利。
 - (2) 若未清楚界定被害人陳述的目的，可能會使被害人有不切實際的期待，誤以為自己的意見可以左右判決的內容，導致被害人的期待與實際判決結果之間容易有差距，進而使被害人對司法程序產生更大的失落感。如此一來，這個程序很可能徒然增加了被害人受到傷害的可能性。詳言之：
 - A. 因為被害人對於法律或法院量刑實務並不熟悉，往往誤以為法院有廣泛的裁量權，可以任意決定對個案懲罰的嚴厲程度，很少被害人能夠正確瞭解量刑準則或判決先例對法院的實際拘束力。
 - B. 被害人大多從自己的感受來進行陳述，但司法機構則會從更多面向來考慮加害人的責任、有無前科、復歸社會的可能性（如穩定的家庭或工作），以決定判決的內容。
 - (3) 未必有助於加害人的更生：因為實際上被害人陳述的內容未必皆能充分傳遞給加害人，特別是在該制度若只允許書面陳述的話，法官未必讓加害人或其辯護人閱覽，使得這種傳遞訊息的

功能無法發揮。就算能夠傳遞陳述的內容，其實際上是否能發揮鼓勵被告更生的效果，仍有待進一步檢驗。

（四）小結（謝老師見解）：

1. 調查各國就被害人陳述制度之實施成果，具有以下共通點：
 - (1) 被害人參與的比例不高
 - (2) 對量刑無顯著影響
 - (3) 被害人對該制度滿意與否仍有爭議
2. 雖然支持被害人陳述制度的學說主張，由於研究結果中感覺好轉的被害人還是比情況惡化的被害人來得多，而且，正因為被害人陳述制度對於量刑結果沒有產生實際影響，這表示量刑不受被害人個人主觀情況的影響，仍然能維持公平，所以才應該繼續進行。然而，謝如媛老師則認為，上開見解實有可議之處，理由如下：
 - (1) 雖然有一部分的被害人感覺好轉，但不表示這個制度就是協助被害人的最佳制度。如果其效果並不明顯，甚至使不少被害人的情形更加惡化，就應該思考如何加以改善，甚至思考陳述制度以外有無其他更好的方式，以促進更大多數被害人的利益。
 - (2) 被害人陳述制度的設立，是希望改善被害人因為犯罪而導致的創傷、無力感。尤其是因為以往的刑事司法程序往往使問題更嚴重，因為司法機關很容易只把被害人當工具（證人），以達成司法程序的目的。被害人認為重要的、相關的事項，往往未獲司法機關重視，並且難以即時獲得訴訟相關進度（或決定）的訊息，以及有關該進度（或決定）的充分說明，導致被害人很容易對司法機關以及判決的結果不滿。如果今天被害人陳述之後，發現對判決（量刑）沒有任何影響，對此種結果又沒有獲得充分的事前或事後說明，很可能增加而不是減少被害人的創

傷，也難以減輕其無力感。正如各國研究成果顯示，被害人對陳述制度的滿意度，在審判之後反而下降，不滿意的比例隨之上升，其理由也與此密切相關。

3. 被害人在法庭上之意見陳述，並不是以證人身分就待證事實而陳述，同時為了避免法官或被告的詰問對被害人造成傷害，因此採用這種制度者通常並不賦予被告就該意見進行反對詰問的權利。然而實際上，被害人之意見陳述若對於被告之判決有影響之可能性，同時，賦予被害人意見陳述之機會卻又不受反對詰問之檢驗，是否無損被告正當程序之保障，實為可疑。
4. 被害人陳述之性質並非屬權利：若選擇陳述係被害人之「權利」，被害人應該可以主動要求陳述，且法院原則上不得拒絕；然而觀諸我國刑事訴訟法第二七一條第二項之規定，雖然明定審判期日應傳喚被害人或其家屬，並予陳述意見之機會，但同條項亦在但書中規定，法院認為不必要或不適宜時不在此限。況且，就算法院未給予被害人或其家屬陳述之機會，也不成為得上訴或另為異議之事由，此亦與一般對「權利」的定義並不相符。即使考慮現行少年事件處理法第 62 條對於實體裁定的抗告規定，並考慮被害人也可以在對於實體裁定抗告時主張未陳述意見的程序上瑕疵，仍應認為，在我國少年事件處理法規定下，被害人仍尚未被賦予單獨向法院請求到庭陳述意見的權利。其理由在於，(1)除了在條文上其所規定的主體顯然是法院，並非被害人；(2)在對於實體裁定的抗告的審理中，即使是程序上的瑕疵也僅是被抗告審法院審查的諸多事項之一，且即使有這樣的瑕疵，抗告審法院若認為不影響結論，理論上仍可以對結論不生影響為由將抗告駁回，無法認為可充分體現被害人有這樣的

程序上權利⁴¹。

5. 實不能再僅以過於簡化的「權利」觀念來思考，而單純地認為「被害人在訴訟上的權益愈多愈好」，或者「參與的機會愈多愈好」，而應注重被害人實質上之權益保障。
6. 被害人很可能對陳述的效果抱持過高的期待，或者未能具體想像可能的負面影響。因此，制度上是否提供被害人充分的訊息來選擇參不参加，當然是一個重要的前提要件。而所謂的資訊，不僅包括在何時、如何進行被害陳述，以及被害陳述主要應提供的內容，也應包括法官實際上可能斟酌被害陳述的程度與範圍。這些相關資訊，在我國幾乎沒有在被害人選擇陳述與否之前，就加以提供並給予充分的時間衡量、思考。
7. 縱使選擇陳述的被害人有一部分獲得一定程度的滿足，但制度運作的結果是否因此波及未參加或未能參加的被害人，使未參加或未能參加者蒙受不利益（例如法官是否因此認為被害情形並不十分嚴重，所以被害人才不陳述），這些應該都是制度運作時必須加以調查檢討的要點。
8. 被害人得否因為在法庭上陳述就獲得回復，從各國研究成果所顯示之陳述滿意度下降甚至被害感情惡化的情形來看，恐怕難以積極肯定。
9. 被害人的陳述若成為量刑工具，反而無法落實保護被害人的理想：不論是在訴訟程序或是與被害人接觸的司法人員，都會將焦點從被害人保護移到量刑上；且被害人陳述會激化被害人與犯罪者的對立。
10. 況且「量刑」所需之參考資料（主要是指刑法第五七條第九款所規

⁴¹ 黃士軒，初探日本少年保護事件審判程序中的被害人參與——以卷證之閱覽抄寫、陳述意見與旁聽為中心，法官協會雜誌 26 卷，頁 68。

定之「犯罪所生之危險與損害」)，應可由卷證中獲得，不必然要從被害人陳述中取得。且從研究成果來看，事實上也對量刑影響不大，相較於將被害人陳述作為量刑根據所可能帶來的弊病，謝老師認為被害人陳述的目的不宜作如此界定。

二、少年事件中的被害人參與⁴²

（一）被害人運動對少年保護事件的衝擊：

逕以「被害人保護」之理由讓被害人參與程序，可能有違少年之最佳利益，並對其健全成長造成負面影響。例如，有學者指出，由於少年原本就比較欠缺完整表達的能力，若有被害人出席，會使得少年更難充分表達自己的想法與意見。也就是說，在某些情況下，被害人的參與有可能使少年封閉自己，也可能對法官做成最有利於少年之處遇決定的目標造成障礙，甚至可能過度影響法官做成處遇決定，導致過於嚴厲的判斷。

（二）釋字第 805 號解釋的影響：

1. 釋字第 805 號解釋主文：「少年事件處理法第 36 條規定：『審理期日訊問少年時，應予少年之法定代理人或現在保護少年之人及輔佐人陳述意見之機會。』及其他少年保護事件之相關條文，整體觀察，均未明文規範被害人（及其法定代理人）於少年保護事件處理程序中得到庭陳述意見，於此範圍內，不符憲法正當法律程序原則之要求，有違憲法保障被害人程序參與權之意旨。有關機關應自本解釋公布之日起 2 年內，依本解釋意旨及少年事件處理法保障少年健全自我成長之立法目的，妥適修正少年事件處理法。於完成修法前，少年法院於少年保護事件處理程序進行中，除有正當事由而認不適

⁴² 謝如媛，犯罪被害人參與少年司法程序之研究，司法院，2011 年 7 月；謝如媛，犯罪被害人陳述制度之成效－從英國實證研究成果出發，法學新論 30 期，2011 年 6 月，頁 13-34；黃士軒，初探日本少年保護事件審判程序中的被害人參與—以卷證之閱覽抄寫、陳述意見與旁聽為中心，法官協會雜誌 26 卷，頁 49-69；許恒達，析論犯罪被害人參與少年司法程序之爭議—借鏡德國少年刑事程序法制，法律扶助與社會 5 期，2020 年 9 月，頁 29-56。

宜者外，應傳喚被害人（及其法定代理人）到庭並予陳述意見之機會。」

2. 解釋理由（節錄）：

- (1) 憲法第 16 條保障人民有訴訟之權，旨在確保人民於其權利或法律上利益遭受侵害時，有權依法請求法院救濟；法院並應依憲法正當法律程序原則公平審判。犯罪被害人（含少年事件被害人）到庭陳述意見之權利，乃被害人程序參與權所保障之基本內涵，為法院應遵循之正當法律程序之一環，自應受憲法之保障。
- (2) 少年保護事件之程序與刑事訴訟程序性質上固然有別，然其被害人於不牴觸少年保護事件立法目的之範圍內，仍應享有一定之到場陳述意見之權利。
- (3) 有關少年保護事件之處理程序，尤為保護與矯治偏差或非行少年而設。就少年保護事件處理程序而言，被害人到庭就其受害情節，以及對少年未來環境之調整或性格之矯治所持意見之陳述，除有助於法院釐清與認定相關事實外，亦有助於法院綜合考量相關因素而對少年採取適當之保護措施，以促成其未來之健全成長。
- (4) 少事法第 36 條明定：「審理期日訊問少年時，應予少年之法定代理人或現在保護少年之人及輔佐人陳述意見之機會。」乃少年法院於審理少年保護事件所應遵循之程序性規定。其規定之立法目的，除為確保少年不致因心智、表達能力未臻成熟，而未能於受訊問時為適當之陳述外，亦在使少年之法定代理人或現在保護少年之人及輔佐人得藉此表達相關意見，以協助少年法院促成少年之健全成長，其目的固屬正當而有必要。惟系爭

規定並未納入被害人或其法定代理人；至少事法其他有關少年保護事件處理程序之條文，於法院作成裁定前斟酌情形而欲推動修復等程序時，為徵求被害人之同意，雖有可能使其得到庭陳述意見，但均非被害人於少年保護事件處理程序進行之常態性權利。

(5) 從而，被害人或其法定代理人就其受害情節，以及對非行少年未來環境之調整或性格之矯治必要性所持意見，可能即無從為適當之表述，除無法以被害人之觀點就少年之行為提供法院認定與評價之參考外，亦無法從被害人之角度協助法院對少年採取適當之保護措施，以促成其未來之健全成長。

3. 由於釋字第 805 號解釋之意旨，我國於 **2023 年修正少事法，增訂第 36 條之 1 規定，使法院於少年事件中亦應傳喚被害人及其法定代理人或現在保護被害人之人到庭陳述意見。**

(三) 我國少年事件處理法中與被害人參與相關的規定：

1. 被害人閱覽、抄寫卷證：

(1) 第 73 條之 1 第一項、第二項：「少年刑事案件之審判中，被害人得選任律師為代理人。但被害人無行為能力或限制行為能力或死亡者，得由其法定代理人、直系血親或配偶選任之。(第一項)代理人得向少年法院就少年被告之犯罪事實，檢閱相關卷宗及證物，並得抄錄、重製或攝影。但卷宗及證物之內容與被告被訴事實無關或足以妨害另案之偵查，或涉及當事人或第三人之隱私或業務秘密，或有礙少年健全之自我成長之虞者，少年法院得限制之。(第二項)」

2. 被害人陳述意見：

第 36 條之 1 第一項至第三項：「審理期日，應傳喚被害人及其法定

代理人或現在保護被害人之人到庭陳述意見。但經合法傳喚無正當理由不到場，或陳明不願到場，或少年法院認為不必要或有礙少年健全之自我成長者，不在此限。(第一項)前項被害人及其法定代理人或現在保護被害人之人之意見陳述，少年法院得於調查時為之。

(第二項)被害人依前二項之規定到場者，其配偶、直系或三親等內旁系血親、家長、家屬、醫師、心理師、輔導人員、社工人員或其信賴之人，經被害人同意後，得陪同在場，並得陳述意見。但少年法院認有礙程序進行或少年健全之自我成長者，不適用之。(第三項)」

3. 被害人旁聽：

第 34 條：「調查及審理不公開。但少年法院得許少年之親屬、學校教師、從事少年保護事業之人或其他認為相當之人在場旁聽；必要時得聽取其意見。」黃士軒老師認為，在此一規定的解釋上，應可包含使被害人作為「其他相當之人」而於程序進行時旁聽的情形。並且，立法者於立法理由中說明法院於判斷是否准許旁聽時，應考慮少年的「年齡、身心狀況、審理情形，以及在場旁聽無礙於少年健全之自我成長」。

(四) 針對我國少事法中被害人參與之規定的檢討：

1. 黃士軒老師認為：

(1) 在我國現行法的規定下，在關於少年保護事件的部分，並沒有被害人或其代理人申請閱卷的規定，僅在少年刑事案件當中才有此規定。而我國立法者在少年事件處理法第 73 條之 1 的立法理由中，對於為何僅在少年刑事案件的章節設有被害人聲請閱覽抄寫卷宗等之規定，並無特別說明。但是，若是考慮到在少年事件處理法的體系上，少年刑事事件有準用少年保護事件調

查及審理的規定，但是並無少年保護事件準用少年刑事案件的規定，則應認為立法者應是有意地就少年保護事件仍不允許被害人聲請閱覽抄寫卷證。我國少年保護事件程序中，被害人陳述意見部分的規定，以及被害人旁聽部分的規定，均未賦予被害人聲請之權限，而是由法院依職權為之。依照我國少年事件處理法的規定，關於被害人透過同法第 34 條之規定於審判時旁聽的部分，是由法院依職權裁量；而關於被害人透過同法第 36 條之 1 第 1 項或第 2 項規定陳述意見的部分，法院在個案中原則上均必須依職權給予被害人等陳述意見的機會。

- (2) 在我國少年事件處理法第 36 條之 1 的規定下，僅規定得使被害人陳述意見之主體，但是對於聽取被害人陳述意見之主體，則未有特別規定。若是依照目前的規定文字，應可推測立法者欲以法院（法官）作為聽取被害人陳述意見之主體。但是，若考慮到依照同條第 2 項規定，被害人亦可於調查程序時陳述意見，那麼若是能如同日本少年法的規定，將調查官也納入聽取被害人陳述意見的主體範圍，似乎較有彈性。

- (3) 我國目前應無較為完整的被害人於審判期日旁聽的制度。將來的立法論上，若有可能討論旁聽制度引進的可能性時，日本法上關於是否限制得旁聽的事件限於發生重大侵害結果的事件，以及旁聽的要件或實務上的準備工作，亦可作為參考。

2. 謝如媛老師則認為：

- (1) 提供更多的司法程序上的參與機會，包括旁聽、閱卷、陳述意見等，未必一定對被害人有幫助。而准許被害人更積極地參與程序，並無限制地知悉有關少年個人及關係人的資訊，也有可能反而深化兩者之間的對立。

- (2) 對被害人的協助，不宜過度強調參與司法程序的機能，而應該要多方面地從社會支援及福利的角度予以思考。例如應加強各地犯罪被害人保護協會之功能、提供心理諮商、充分的犯罪補償機制、社工後續定期訪視等項目，使各方面的支援體制能夠齊備。並且，及時提供被害人所需要的各項訊息，包括司法程序的進展及各種相關支援措施的說明。
- (3) 我國少事法第 48 條規定，少年法院所為裁定應以正本送達被害人，與日本須待被害人主動申請之規定不同，固然對被害人來說較為便利，但是顧慮到每個被害人面對被害的態度或方式皆不相同，實際上可能有被害人不願意再收到與該事件相關的訊息者（例如不願再勾起傷心回憶），則日本作法有其優點。
- (4) 我國應可適度採用日本少年法之說明審理狀況制度，使得被害人無法旁聽審理時，可以選擇向法院申請相關說明，以便瞭解審理狀況。該類制度並不至於產生少年與被害人當面接觸衝突的情形，並且在說明審理狀況時，也比較有可能斟酌說明的內容避免侵害少年及關係人的隱私。
- (5) 針對是否應准許被害人閱卷與複印：被害人固然有瞭解案件狀況的需求，但若已有裁定書之送達，及前開「說明審理狀況」制度之建立，應足以使被害人瞭解案件的大致進行狀況。尤其卷宗內資料多有與少年隱私有關之資料，例如少年的童年史、喜好等，則讓被害人閱卷複印將有使少年隱私外洩，進而妨礙少年健全培育的危險。因此，謝老師認為不宜採行。
- (6) 我國少事法雖沒有明文規定被害人等得申請旁聽少年事件之審理，但實務上仍會視案件情節或審理狀況通知被害人審理期日得出庭旁聽。其運用情形則端視法官之判斷與裁量。而謝老師

認為，第 34 條之「其他認為相當之人」在解釋上難以成為被害人旁聽少年事件審理之依據。蓋從條文解釋上來看，應係與少年之親屬、學校教師、從事少年保護事業之人相類似，而不違背本條立法目的係為保護少年之立法意旨之人。且若明文規定被害人得旁聽，法院將面臨許多挑戰，必須兼顧最適於少年的處遇以及尊重被害人之心境與期待間之平衡，因此不宜明定被害人旁聽之規定。

- (7) 被害人旁聽、被害人陳述意見等規定，不宜作為被害人的「權利」予以明訂，而應讓法院得按個案情形，以有助於促進少年之健全成長為前提，來進行個案裁量。

【試題演練】

我國少年事件中，被害人有無旁聽之權利？若無，應否加以明定？（30%）

自擬

【擬答】

一、現行法下，少年事件中之被害人應無明文之旁聽權：

（一）按少年事件處理法第 34 條規定：「調查及審理不公開。但少年法院得許少年之親屬、學校教師、從事少年保護事業之人或其他認為相當之人在場旁聽；必要時得聽取其意見。」據此，少年事件原則均採不公開審理，僅允許特定之人旁聽。惟，該條文中所稱之「相當之人」是否包括案件之被害人，學理上則有不同見解：

1. 有認為，解釋上應可包含使被害人作為「其他相當之人」而於程序進行時旁聽的情形；蓋因立法者於立法理由中說明法院於判斷是否准許旁聽時，應考慮少年的「年齡、身心狀況、審理情形，以及在場旁聽無礙於少年健全之自我成長」。

2. 亦有認為，該條所稱「其他相當之人」，在解釋上難以成為被害人旁聽少年事件審理之依據。蓋從條文解釋上來看，應係與少年之親屬、學校教師、從事少年保護事業之人相類似，而不違背本條立法目的係為保護少年之立法意旨之人。

(二) 本文認為，自立法目的以觀，本條規定之目的乃係為保障少年之健全成長；則就本條所允許旁聽之人，亦應以其在場得協助確保少年健全發展者為限。而犯罪之被害人在場，將導致法院需面臨兼顧最適於少年的處遇以及尊重被害人之心境與期待間平衡之挑戰，更可能加深被害人與少年間的對立，故應以否定說為當。據此，現行法下，少年事件之被害人應無明文之旁聽權。

二、少年事件被害人旁聽權，不應加以明定：

- (一) 允許被害人於少年案件中參與旁聽，固然得使被害人對於案件審理狀況有更充分的掌握；然而，此些程序上的參與機會，並不一定能達到被害人參與目的。反之，若允許被害人無限制的知悉少年個人及關係人之資訊，不僅對於被害人自身毫無幫助，更可能加深二者間的對立。據此，於少年事件中，對被害人提供之協助似不應過度強調參與司法程序的機能，而應該要多方面地從社會支援及福利的角度予以思考；例如應加強各地犯罪被害人保護協會之功能、提供心理諮商、充分的犯罪補償機制、社工後續定期訪視等項目等。
- (二) 至於案件進度之了解，或可參考日本少年法之「說明審理狀況制度」，使被害人得選擇向法院申請相關說明，以便瞭解審理狀況。該類制度並不至於產生少年與被害人當面接觸衝突的情形，並且在說明審理狀況時，也比較有可能斟酌說明的內容避免侵害少年及關係人的隱私。
- (三) 據此，本文認為，不應於少年法中明文規定被害人旁聽之權利；縱實務運作上或有准許被害人旁聽之情形，惟其仍應交由法官進行個案裁量，僅在

個案中允許旁聽並不牴觸促進少年成長之前提下，方得允許之。